

绪 论

一、简答题

1. 简述商法学的研究对象和功能。

【答案】商法学是以商法的一般理论与制度及商事部门法理论与制度为研究对象的部门法理论与学科，是法学理论体系与学科体系的重要组成部分。

（1）商法学的研究对象

首先以商法基础理论为研究对象，通过对基础理论的研究回答商法实践中的一般理论问题，如如何构建统一的商事主体制度、行为制度、权利体系制度和权利保障制度。其次，以商事部门法为研究对象，回答商法实践中具体的部门法理论问题。

（2）商法学的功能

①有助于建构和发展中国特色社会主义商法。商法学围绕中国社会主义市场经济实践，结合世界各国的商事经验，以凝练、总结和发展中国特色社会主义商法的基本内容和特点为己任，为构建中国特色社会主义商法奠定了理论基石。

②有助于完善中国特色社会主义商事制度，维护社会主义市场经济秩序。我国缺乏统领性的《商法典》或《商事通则》，现行商事法律规范之间在一定程度上出现缺乏协调乃至冲突对立的局面，商法学正是以商法一般理论和商事部门法为研究对象的学科，有助于构建系统完备的商法制度。

③将推动当代中国法制文化观念的变革。能够培育商法思维，转变人们民商不分的观念、促使社会对商法形成正确的认识。

④是树立社会商业道德，推动社会主义精神文明建设的助力。我国社会长期存在民商不分、营利与非营利不分、商业伦理与社会伦理不分的理念，通过商法学的理论发展，有助于形成社会正确的商法思维和伦理观念，树立社会商业道德。

⑤是我国实现国际经济战略的重要法制理论依托。以现代商人制度、现代商事行为制度以及现代社会商法基本特征的研究为重点的商法学是我国推行国际经济战略的重大理论基础。

第一章 商法的一般原理

一、概念题

1. 商事自治规则

【答案】

商事自治规则是指商主体就其组织、运作、成员的权利义务、相对人权利义务等内容自主制定的，不与国家法律和行政法规相冲突的规则。其具体形式主要有：①公司章程；②交易所业务规则；③一些商主体预先制作的定型合同条款。

2. 商法的渊源

【答案】商法的渊源是指商法规范借以表现和存在的形式。它是对商事行为具有约束力的法律规范效力的重要来源，是商事经营活动的重要法律依据。

在传统商法中，商法的渊源主要为商制定法、商判例法、商习惯法和商法学说。20世纪以来，随着社会经济的进步和经济规模的扩大，尤其伴随着社会经济组织形态和结构的完善、经济组织内部制度的日益健全以及经济组织对外交易手段的发达和多样化，商事自治法亦随之发展成为商法的一个重要法律渊源。

在我国，商法的渊源主要包括法律、行政法规、地方性法规、国际条约和国际惯例、立法解释、司法解释和商事自治规则等。

二、简答题

1. 商法的基本原则。

【答案】商法的基本原则是指集中体现商法的性质和宗旨，调整商事法律关系必须遵守的基本准则。它是制定商法典的根本出发点，更是适用商法的指导原则。商法的基本原则包括：

（1）商主体严格法定原则

①商主体类型法定。即可以进行经营活动的商主体在组织形式上由法律予以明确设定，非经法律设定者不得享有商主体资格；当事人不得创设法定类型之外的商事组织形式。

②商主体内容法定。即可以进行经营活动的商主体的财产关系和

组织关系由法律予以明确规定，当事人不得创设非规范性的财产关系和组织关系。

③商主体公示法定。即商主体的成立必须按照法定程序予以公示，以便交易第三人及时知晓；未经法定公示者，不得用以对抗善意第三人。

（2）公平交易原则

公平交易原则，是指商主体应本着公平的观念从事商行为，正当行使权利和履行义务，在商事交易中兼顾他人利益和社会公共利益。主要包括以下两点：

①商事交易主体的地位平等。

②诚实信用。

（3）交易简便、迅捷原则

主要体现在三个方面：①交易简便；②短期时效；③定型化交易规则。

（4）鼓励交易原则

①通过确立商法的其他基本原则，在合法前提下最大限度地尊重当事人的交易意愿等，促进交易。

②最大可能维护交易的有效性。

③对于有过错或失误的交易行为，最大可能地为交易行为人提供补救机会。

（5）交易明确、安全原则

①在商事交易活动中，交易各方负有义务充分提示交易内容，并将交易活动的进展和变更情况及时通知对方，以使相对人或第三人完全、及时地知晓交易实情。

②禁止欺诈和不正当竞争行为。

③通过对商事交易条件采取强制主义、公示主义、外观主义、严格责任主义等法律规制，通过法律的积极干预确保交易的安全。

2. 简述商事交易便捷原则在我国商事立法中的体现。

【答案】传统商法源于商人习惯法，强调商业活动的效率价值。近代和现代商法主要采用制定法的形式，但仍然强调交易的效率价值。交易便捷原则的核心是减少烦琐的交易手续、降低交易成本。商事交易便捷原则在我国商事立法中的体现有：

（1）形式自由

商法重视效率价值，在法律行为形式要件上的要求较低。在商人或企业的缔约中，采用自由主义原则，认可口头合同的存在，接受证

人证明的合同形式，有限度地认可沉默产生缔约效果。正因如此，商法又被称为“最自由的法律”。

（2）权利外观

权利外观也称信赖保护。由于权利外观表象与权利最终归属之间，在现实生活中常常存在相互分离的状态。故商法承认权利外观表象在权利认定上的优先效力，即在企业设立上遵循登记或注册主义，在商业权利上采用登记或注册等方式，进而有助于促进商事交易，减少确权带来的交易成本，减少商事交易中的违约情势。

（3）短期时效

国外商法通常规定了较短的诉讼时效期间，以促使商人或企业尽早行使权利，稳定商事关系。在我国，处理商事纠纷应当适用《民法典》关于诉讼时效的一般规定。如果商人或企业约定了较短的质量检验期限，应当按照意思自治原则予以认可。

3. 简述商法的渊源。

相关试题：商法的渊源及其适用。]

【答案】商法的渊源，即商法规范的存在或表现形式，具体而言，是指具有法的效力的商法规范借以表现的形式。我国商法主要采用成文法形式。商法渊源是对商主体和商行为具有约束力的法律规范，也是商事活动和商事司法的重要法律依据。商法渊源主要包含以下内容：

（1）我国商法的国内法渊源

①我国商法的正式渊源

正式渊源，是指国家立法机关依照法定立法程序制定的法律文件，也包括立法机关认可的有权机关依照法定程序制定的规范。我国商法的正式渊源包括：a. 宪法；b. 民商事法律；c. 行政法规；d. 地方性法规；e. 自治条例和单行条例；f. 部门规章；g. 地方政府规章；h. 最高人民法院具体应用法律的解释（司法解释）。

②我国商法的非正式渊源

非正式渊源，是指立法机关及其认定的有权机关以外的其他组织制定的、不违反法律规定并发生实质约束效力的规范。从我国商法实践来看，非正式渊源主要包括：a. 最高人民法院公告的案例；b. 最高人民法院发布的指导案例；c. 交易习惯。

（2）我国商法的国际法渊源

我国商法的国际法渊源，主要分为国际商事条约、行政协定和国际商事惯例。

①国际商事条约，是指以国家名义缔结、参加、承认的单边或者

双边国际商事条约、协定和具有条约性质的文件。

②行政协定，是指两个或者两个以上的政府之间签订的有关政治、贸易、法律、文件等方面的协议。

③国际商务惯例，是指在商业或贸易基础上发展起来的、用于解决国际商事问题的实体法性质的惯例

4. 简述商法与经济法的区别。

【答案】商法与经济法的区别主要表现在以下几个方面：

(1) 在调整对象上，商法主要调整平等主体之间的交易活动，经济法则不仅调整经营主体的行为，而且调整国家及其代表机构运用国家权力干预经济活动的行为。

(2) 在调整方法上，商法注重维持私法中传统的“意思自治原则”，经济法则信守“国家干预原则”。

(3) 在法律属性上，商法是以维护私权主体利益为本位的私法，以任意性规范为主。经济法本质上是以维护国家或社会整体利益为本位的公法，以强制性规范为主。

(4) 在体系构成上，商法以商主体一般规范、商行为一般规范、公司法、合伙企业法、个人独资企业法、证券法、破产法、保险法、票据法、信托法等为内容。经济法则以价格法、金融监管法、税收法、投资法、公平交易法、反垄断法、贸易管制法等为内容。

5. 简述经营自由的内涵及其边界。

【答案】(1) 经营自由的内涵

经营自由，是指民商事主体享有自主决定从事经营活动的自由权，国家不得设置不当障碍。经营自由的价值主要表现为对民商事主体从事经营活动不当障碍的排除，至于民商事主体对其权利义务予以自主安排的自由权则应属于私法自治的范畴。商法中的私法自治理念主要适用于民商事主体获准从事经营活动过程中，而经营自由则主要适用于经营活动开展前的市场准入。不过，在某些领域，存在私法自治与经营自由理念的适用相互重叠的现象，此时应结合两种不同的商法理念进行制度设计与司法裁量。

(2) 经营自由的边界

经营自由当然也需受到一定限制，这种限制主要表现为法律关于从事特定经营行为的准入条件与审批程序的规定。若要从属于国家设置了前置审批条件与程序的经营行为，则必须依法办理相关审批手续才能获准经营。但除非确实需要设置特定准入“门槛”，法律与政府

均不对经营自由作过度限制，否则将构成对宪法所规定的基本自由权的侵害。

6. 简述加重责任的内涵及其主要表现形式。

【答案】加重责任的内涵及其主要表现形式如下：

（1）加重责任的内涵

①商法一般都对商行为的实施者设定更为严格的责任制度，这一责任设定宗旨称为商法的严格责任理念。

②之所以对商行为的实施者规定加重责任，主要有两大原因：a. 商行为的实施者理应具备较高的经营能力，应在行为过程中承担较高的注意义务；b. 商行为具有营利性，商法在保护营利的同时，基于公平原则，也应赋予商行为的实施主体以严格的法律义务与责任。

（2）加重责任的主要表现形式

①保证的连带责任。

②要约是否承诺的通知义务。

③对要约附送货物的保管义务。

④商主体的严格注意义务。

7. 简述企业维持原则的内涵及其主要表现形式。

【答案】企业维持原则的内涵及其主要表现形式为：

（1）企业维持原则的内涵

企业维持原则，是指现代商法通过各种法律制度确保企业组织得以稳定、协调和健康发展，尤其是通过各种制度安排尽力维持其存续的原则。

（2）企业维持原则的主要表现形式

在公司法中，公司设立瑕疵的法律后果及公司解散请求权等制度中，都充分体现了企业维持原则的立法精神。各国大都通过相应补救措施，允许存在设立瑕疵的公司继续保留其法律人格，而不是简单地使其消灭。在现代破产法上普遍设立的破产重整制度与破产和解制度，除了其自身所具有的破产法上特殊价值外，也体现了企业维持原则的立法精神。

8. 简述商法体系的研究价值。

【答案】商法的体系是指商法作为一个独立的法律部门，其内部具有逻辑联系的各项商事法律制度所组成的系统结构。商法体系有广义与

狭义之分。广义的商法体系包括商法法规体系即商法渊源意义上的商法体系与商法学体系即商法学说意义上的商法体系；狭义的商法体系则仅指商法法规体系。一般所指商法体系，是指狭义的。研究商法体系的价值在于：

（1）从整体上把握并优化商法的体系结构，对于商事立法、司法与商法学研究都具有非常重要的意义。尽管在绝大多数国家商法均未形成民法体系那样的高度抽象的逻辑体系，但商法规范本身则随着市场经济的发展事实上形成了较为完备的体系。

（2）对于商法建设还远不完备的我国而言，加强商法体系研究具有更加重要的意义。尽管在法律体系中，商法因其调整的商事交易关系所具有的共性而具有明显的国际趋同性，但是由于各国受特定的地理、历史、经济发展水平以及文化状况的制约，其对商法体系的认识存在较大差异。因此，对于商法建设还远不完备的我国而言，一方面，我们应通过对各国商法体系的实证考察，揭示商法体系的内在规律性，为我国商法体系的构建提供参考；另一方面，我们应当对我国法律体系尤其是私法体系的考察，寻求一个适合于我国市场经济建设实践并与我国法律体系相协调的商法体系。

（3）以商法法规体系为中心的商法体系研究，处于商法研究的基础地位，对于我国总纲性商法规范乃至形式商法的制定将起着极为重要的作用。尤其是现存的各国商法体系由于特定的历史原因并不尽合理，并且与此相适应商法体系研究较为落后，对于我国现代商法建设难以提供有力的理论支持。

9. 简述我国现行商法体系的缺陷。

【答案】我国现行商法体系存在以下缺陷：

（1）在民事立法中为体现商事关系法律调整的特别要求，设置了大量具有商法规范性质的规范，甚至使民法规范体系呈现出商化过度的现象。但即便如此，民法规范体系中的商法规范毕竟不是基于商事立法理念设置，仍不可避免地呈现出商化不足的问题。

（2）我国虽颁布了较为完整的商事单行法，使其能够基本满足市场经济的法律调整需求，但这些商事单行法都是在民法框架下制定，缺乏总纲性商法规范，也未确定商法理念与原则，从而难以在商事审判与仲裁中产生有效的弥补成文法漏洞的作用。

（3）在《公司法》《证券法》《企业破产法》等商事部门法中虽分别针对各种法律部门规定了部分一般性规范，但总纲性商法规范因

缺乏立法载体仍基本上处于空白状态，使各商事部门法缺乏必要的上位法指引和支持。

10. 简述英美法系商法与大陆法系商法的区别。

【答案】英美法系与大陆法系是按照法系对商法的一个分类。若就狭义的商法而言，可认为英美法系国家并不存在商法。但若就广义上的商法而言，则可认为英美法系国家也存在实质意义上的商法。其二者的区别主要如下：

（1）英美法系

传统上，英美法系商法大多表现为判例法与习惯法形式，同时也颁布了一些属于现代商法的单行商事制定法。

一般认为，除公司法外，英国商法还包括以下法律分支：代理与合伙，货物买卖与分期付款，垄断与限制性贸易做法，流通票据，商业证券，保险，陆上、海上和航空运输，破产，仲裁。美国则除同样存在大量商事判例法外，各州都制定了为数众多的商事单行制定法，联邦立法机关则制定了州际商法、破产法等。此外，美国法学会与美国统一州法委员会还共同编纂了《美国统一商法典》。虽然该“商法典”并不直接具有法律效力，但目前美国各州已经全部采纳了该法典的内容，只是在接受程度上有所差异，即有的州稍加修改后即全部采纳，有的州则仅采纳了其中部分章节。与此相似的《商事公司示范法》等商事示范法也在美国商事实践中发挥了积极作用。不过，严格来说，英美法系商法确实与采民商分立立法例国家的商法不可同日而语。

（2）大陆法系

在大陆法系国家，商法还可进一步划分为商事普通法、商事特别法和商事习惯法。

商事普通法是指调整商事基本关系的一般规则的总称，其内容包括有关商法的原则、商主体、商行为、商业登记、商业账簿以及对商行为的一般控制制度等。商事普通法在民商分立国家表现为统一的商法典，而在民商合一国家则多表现为民法中的特别规则或单行法，但不管采取何种形式，它们均对各种类型的商事法律关系具有普遍的拘束力。商事特别法又称商事部门法，它是指调整某一特定范围的商事关系的商法规范的总称。例如，大陆法系国家普遍存在的公司法、保险法、破产法、票据法、海商法、仲裁法等都属于商事特别法。商事特别法是对特定商事关系的专门调整，一定的商事特别法对于特定的商法关系，对其他的商事关系则不具有拘束力。按照特别法优先于普

通法的法律适用原则，商事特别法调整特定的商事关系应优先于商事普通法而适用，只有在商事特别法未予规定的情况下，才能适用商事普通法的普遍性规定。商事习惯法则是指在商事实践中自发形成并经国家认可的，调整商事关系的习惯规则，通常具有非成文性和行业性规则形式。

三、论述题

1. 试述商事关系的特点、类型及其商法调整。

【答案】商事关系是商事主体基于商事行为而产生的权利义务关系。

（1）商事关系的特点

①商事关系是基于商主体的自由意志产生的，是商主体自主自愿行为的结果。

②商事关系中的双方一般皆为公民、法人或其他经济组织。

③商事关系具有平等性，是一种平权关系。

④商事关系中主体的权利与主体的个人意志及利益相联系，并可由主体依照自己的意志合法处置。

（2）商事关系的类型

①商事财产关系，包括内部商事财产经营法律关系（如合伙经营法律关系、投资股份法律关系）和外部财产交易法律关系（如商事买卖合同法律关系、股票交易法律关系）。

②商事人身关系，包括商事营业主体内部组织管理法律关系（如公司内部的组织管理法律关系，分支机构与本公司的法律关系）和商事营业主体之间的人身权法律关系（如商业名称法律关系、商誉权法律关系）。

（3）商法的调整

①对于商事财产关系的商法调整。一般认为商法是民法的特别法，特别法优于一般法。因此，在各商事单行法有特别规定时适用商事特别法的规定；而在商法无特别规定时适用民法的一般规则，如《民法典》关于合同权利义务与违约责任的规定。

②对于商事人身关系的商法调整。商事人身关系不同于民法中的人身关系，对该部分内容不存在适用民法一般规则的问题，因此，商法针对商事营业主体内部组织管理法律关系和商事营业主体之间的人身权法律关系作出了不同的制度安排。对于前者，商法主要通过《公司法》予以调整，而对后者主要通过各商事行政法规及知识产权法的相关规定予以调整。

2. 试述商法的意义。

相关试题：试述商法的特点及其意义。

【答案】商法的意义主要是通过商法规则的具体设计来实现的，这些商法规则的设计并不表现为直接指导人们如何营利，而在于以法律制度构建起一个自身营利的统一有机体或以法律制度来规范营利性的行为。各国商法规范主要从以下几方面体现着商法的效益价值：

（1）确认商事主体的地位和自由的规则

商事主体是商事交易的中心，商事法律关系的内容——商事权利和商事义务，要靠商事主体来享有和履行，商事法律关系的客体——商事行为，也必须从属于特定的商事主体。故对商事主体地位的确认并给其商事自由是实现效益的前提。商法以具体的商法条文确认了商事主体的法律地位。如在我国特殊的国情下，商法规范对“国有独资公司”的法律地位进行了确认；2006年公司法的修订，又顺应经济发展需要、借鉴国外先进立法经验，新增了对“一人公司”的法律地位的确认。商事主体的法律地位的确认还只是一个前提，要实现商事效益，关键还要赋予商事主体充足的商事活动自由。我国原来实行的是计划经济，商事主体的活动自由极其有限。通过多年的改革、完善，商事主体的自由空间越来越大，商事自由又为效益创造提供可能。商法所维护的商事自由包括财产自由、缔约自由、经营自由和联合自由等。当然，商事主体的这种自由也不是绝对的，在某些方面要受到必要的限制，比如缔约自由的缔约人虽然可以选择缔约的对象和种类，但订立契约的内容和形式都不能违反国家的强制性规定等。

（2）促进商事交易便捷

商法的各项规则都在围绕着如何促进交易便捷而努力。对商事交易技术手段的规定即交易方式的定型化是常见的方式，即商法通常将交易的方式预先规定为若干类型，使任何商事主体在任何时候都可以获得同等的效果。其包含两种方式，即对交易客体的商品化和证券化：若交易的客体是有形的物品，则使之商品化，予以划一的规格或特定的商标；若交易的客体是无形的权利，则使之证券化，如股票、公司债券、支票等。这种方式使得烦琐的交易程序简捷化，极大地提高了商事交易的速度。

短期时效制度即使交易行为所生请求权的时效期间缩短而从速确定其行为效力的制度。也是促进商事交易便捷的一种有效制度。在我国，商事交易中采用短期时效主义的较多。如我国票据法规定了严格的票据权利期限；保险法中规定了对保险金请求权的时效限制；海商法中还以专章的篇幅规定了短期时效的内容等。

（3）保障交易秩序

秩序和安全是效益持续实现的有效保障，尤其是在大力主张“可持续发展”的今天，商事效益的实现更需要交易的秩序化和安全性。商事登记、保险制度等都以此为目的。商业登记制度强制要求商事主体申报自身信息。商事登记制度所坚持的公示主义有助于维护未来交易的安全，其对于各种违法行为赋予的严格的责任同样也达到了维护交易秩序和安全的目地；同时，商事登记制度还有效维护了商事主体的信誉，使商事主体获得了一种无形的资产，为其取得商事效益打好了基础。保险法律规范作为商法中不可缺少的一部分，其制度的设计使商事主体间的信任感加强、不安全感减少，使交易秩序稳定持续，这样就使得那些可能面临风险的商事主体敢于知难而进，发挥社会资源的最大可利用的效率。因为保险制度的存在使他们相信，即使遇到了风险、遭受了损失，也会得到补偿。正因为此，我国的企事业单位和其他一些商事主体在遭受财产毁灭时，及时得到了补偿，从而带来整个商事领域的效益。

3. 试述商法与民法的区别。

相关试题：商法与民法的区别之一在于商法更崇尚公平，而民法更崇尚效率。

【答案】商法与民法的联系十分密切，区别也颇为明显。一般说来，二者的区别主要包括以下几个方面：

（1）民法是普通法或基本法，商法是特别法；民法是抽象化的法律表现，商法是具体化的法律表现。例如，民事所有权制度是商事交易财产的一般规定；商事物权制度是商事交易财产的特别规定。票据权利、企业所有权、股权等都是不同于一般民事物权，涉及商事物权的特别规定。又如，民事主体制度是商主体的一般规定，商主体制度则是民事主体制度的特别规定。公司的权利能力和行为能力、公司的经营范围等都是不同于一般民事主体，涉及商主体的特别规定。

（2）民法是纯私法，调整的是平权关系；商法则以私法为主体，兼具公法性内容，调整的是平权与不平权兼有的关系，如商事登记、商事账簿、商事破产程序、证券发行与管理等都兼有很强的调整不平权关系的公法色彩。因此，民法是私法规范体系；商法是以私法规范为主体，私法规范与公法规范相结合的法律规范体系。

（3）民法作为基本法或普通法，调整的范围广泛，它适用于各类民事主体所实施的民事行为。商法调整范围有限，它仅仅适用于民事主体中从事商事经营活动那一部分，或仅仅适用于民事行为中与营利

相关的那一部分行为，即商人所从事的商行为。民商法并行但不完全兼容，民法的内容并不全部在商法之中，商法的内容很大一部分民法中未涉及。

4. 试析中国形式商法的立法难点。

【答案】形式的商法，是指独立于民法典之外的商法典。我国形式商法的立法难点主要体现在以下几个方面：

（1）从立法经验来看，大陆法国家的商法，包括德国商法典的制定都有不成功之处，因此，在进入21世纪的时候，我们很难再继续依照以德国商法为代表的大陆法国家商法典的立法经验来制定中国的形式商法。

（2）《美国统一商法典》是建立在英美法基础之上的一部商法典，其立法基础、立法方式都远不同于大陆法系。因为法系方面的巨大差异，加之中国现有的商法基础格局，中国目前同样很难完全依照美国的经验制定一部统一的形式商法。

（3）由于中国自身的历史原因，制定统一商法典的呼声在中国法学界一直处于极弱的状态。

（4）当代商事交易方式的日趋复杂和多变，增加了制定统一形式商法的难度。

（5）中国法学界对私法的研究，尤其是对民商法的研究仍然处于一种半成熟的状态，也加大了对统一形式商法制定可行性认识的难度。

（6）中国的市场经济体制还处于起步阶段，对市场经济法制的认识还处于不成熟时期，对制定统一形式商法的认识还不能统一起来。

第二章 商事主体

一、单项选择题

1. 下列各项中，一般不属于商事登记的限制内容的是（ ）。

- A. 主体的限制
- B. 行为符合法律规定的一般要求
- C. 行为符合法律规定的具体要求
- D. 商主体住所的限制

【答案】D

【解析】

商事登记的限制可为主体之限制和行为之限制两方面把握。前者包括主体职务上的限制和主体能力上的限制；后者主要包括行为符合法律规定的一般要求和特殊要求。

2. 下列不属于民事主体与商主体区别的是（ ）。

- A. 商主体必须同时具有权利能力和行为能力，而民事主体却未必如此
- B. 民事主体的权利能力和行为能力可以不同时产生，商主体则必须同时产生
- C. 公法上的主体如政府部门等可以成为商主体，但不能成为民事主体
- D. 商主体的构成，一般必须是行为人积极法律行为的结果

【答案】C

【解析】

C项，公法上的主体既可以成为商主体，也能成为民事主体。

3. 有关商法人的表述错误的是（ ）。

- A. 商法人指依照法定构成要件和程序设立、拥有法人资格而参与商事法律关系的组织
- B. 商法人是一种拟制的法律主体，不是自然形成的
- C. 商法人有自己的意思机关，具有财产独立性与责任的独立性特征
- D. 商法人是法人的一种，但更是一个组织体，所以其成立时只要符合实体要件即可，程序上没有要求

【答案】D

【解析】

D项，商法人是按照法定构成要件和程序设立的，拥有法人资格，参与商事法律关系，依法独立享有权利和承担义务的组织。可见商法人的设立需要同时符合法律关于实体要件和程序要件。

二、概念题

1. 商主体

【答案】

商主体又称商事法律关系的主体，是指依照法律规定参与商事法律关系，能够以自己的名义从事商行为，享受权利和承担义务的人，包括个人和组织。商主体具有不同于一般民事主体的法律特征：①从本质上说，商主体是一种法律拟制的主体，它所享有的权利能力和行为能力具有特殊性。②商主体是从事以营利为目的的经营性活动的主体。③商主体是商事法律关系中的当事人，即在商法上享有权利并承担义务的人。

2. 商合伙与民事合伙]

【答案】（1）商合伙，是指两个或两个以上的合伙人按照法律和合伙协议的规定共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，普通合伙人对合伙经营所产生的债务承担无限连带责任，有限合伙人对合伙债务承担有限责任的商事组织。商合伙是一个拟制的法律主体，是介于商个人和商法人之间的一种商事主体，它以自己的名义实施商行为。商

合伙的设立必须履行工商登记。

(2) 民事合伙是指按照我国《民法典》和有关工商登记法规的规定，两个以上的自然人，按照合伙协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动；投入的财产属个人所有，由合伙人共同使用；合伙经营积累的财产归合伙人共有；发生亏损应由合伙人负连带清偿责任的组织。

(3) 商合伙与民事合伙均为合伙的组织形式，是法律拟制的主体。二者的区别主要在于商合伙一般有固定的经营场所，必须进行工商登记；民事合伙一般为自然人直接的结合，具有一定的松散性，且一般不需要进行工商登记。

3. 商号与商标

【答案】(1) 商号，又称商事名称、商业名称，是指商主体在从事商行为时所使用的名称，即商主体在商事交易中，用以署名或其代理人与他人进行商事交往时使用的名称。

(2) 商标是指生产经营者或者服务者在其商品或服务上使用的，由文字、图形、字母、数字、颜色组合及其他要素的组合构成的区别商品或服务来源的标记。

(3) 商号与商标都是一定对象的标识，都具有一定的区别功能。有时商业名称中的字号本身就是商标。但二者明显的区别有：

①商号用于区分不同的商事主体，而商标则用来区分不同的商品。

②一个商事主体只能有一个商号，但可以有多多个商标。

③商号只能以文字形态存在，而商标可以文字、图形、数字、字母、颜色及其组合的形态来表示。

④一个商事主体可以没有商标，但是必须有自己商号。

⑤商号的空间效力范围以核准机关辖区为限，而商标的专用权在全国范围内有效。

4. 商事主体严格法定原则

【答案】商事主体严格法定原则是指商事主体的类型、内容、程序由法律予以明确规定的原则。主要包括三个方面：

(1) 商事主体类型法定，是指商法对于商事主体的类型作出明文规定，当事人只能在法定类型的范围内选择所要采用的类型，而不能任意创设法律中未规定的类型。

(2) 商事主体内容法定，是指商法对各类主体的组织关系和财产

关系在法律中予以明确规定，当事人不得擅自变更其组织关系和财产关系。

（3）商事主体程序法定，是指设立、变更和终止商事主体，必须遵守商事法律规定的程序。

5. 商事能力与民事能力]

【答案】（1）商事能力包括商事权利能力和商事行为能力。

商事权利能力是指商法所赋予的、商事主体能够参加商事法律关系，并在其中享有商事权利和承担商事义务的资格或能力。

商事行为能力是指在法律规定的范围内，通过自己的行为或意志独立进行商事活动，并取得商事权利和承担商事义务的一种资格或能力。

（2）民事能力是指民事主体享有权利、承担义务的资格和能力，包括民事权利能力和民事行为能力。

（3）商主体具有不同于一般民事主体的能力，从而形成了商事能力与一般民事能力的区别。这种区别主要表现在：

①商事能力是商主体依法从事商行为，并由此而承担法律上的权利义务的民事行为能力，表明了商主体在商法上的特殊资格和地位。而一般民事主体不享有法律上的这种特权，未经法律授权，一般民事主体不得从事商事经营活动。

②商事能力是一种附加于民事能力之上的能力，即具备商事能力者一般应以具备民事能力为前提。但具备一般民事能力并不必然具备商事能力。从这个意义上说，商事能力是一种特殊的民事能力。

③商事能力以法律授权为前提，商事权利能力和商事行为能力皆以法律授权范围为限，并以授权起止为权利存续期限。而一般民事能力，更多的是与自然人的生命延续和意思成熟程度密切相关。

6. 商业账簿

【答案】

商业账簿是指商主体为了表明其财产状况和经营状况而依法制作的账簿。现代商业账簿包括书面形式和电子形式两种。形式意义的商业账簿是指商主体依照法律的规定而制作的账簿，即法定账簿；实质意义上的账簿是商主体所备置的所有账簿。

三、简答题

1. 简述商事能力的含义及特征。

【答案】（1）商事能力是商主体依据商业登记所核定的经营范围，独立地从事特定的商行为，享有商法上的权利并承担商法上的义务的资格和能力。包括商事权利能力和行为能力。法律对商事能力有严格规定。

（2）商事能力具有以下特点：

①商事能力的取得须经法律授权且存续期限由法律明确规定。商事能力是商主体依法取得的从事商行为的法律资格，一般民事主体不允许从事商事经营活动。在我国，商事能力一般始于登记机关核准登记并颁发营业执照之日，终于注销登记之日。且商事主体的商事权利能力和商事行为能力同时产生，同时消灭，两者具有统一性。

②商事能力的范围有限，由法律明确授权。商主体的商事能力应以法律授权的营业范围为准，经商事登记公示，商主体只允许在登记范围内从事商事经营活动。而且，商事主体因为经营范围不同而享有不同的商事权利能力和商事行为能力。

2. 简述我国的商法人制度。

【答案】（1）商法人是一个法理概念，是法人的一个组成部分。商法人是商法赋予一定社会组织以法律上的人格，这种人格，使商法人成为商业法律关系的主体，使它具有了主体所有的权利能力和行为能力。

具体地讲，商法人与一般法人相比，具有以下特点：

①依照法律不同，商法人是依照商法规定而成立的社会组织。

②依据法定程序不同，商法人是依据商业登记而成立的活动的的内容不同。在中国因没有公布商法典，现实中没有对商法人与一般法人加以区别。

（2）按照大陆法各国的民商法，商法人须具备以下条件：

①有自己的名称、人员机构和场所。

②有独立的财产或规定数额资金，能够独立承担经营责任。

③以营利为目的，依法取得特定的经营行为能力。

④依商事登记法而成立，具有商法上的资格。

（3）商法人作为法人的最基本形式，应具有以下几个特征：

①它具有独立的人格。商法人经特殊登记程序而取得拟制主体资格，它具有登记核准的特殊权利能力，能够以自己的名义从事生产经营活动和诉讼活动。

②它具有独立的财产和财产权。

③它具有统一的组织机构。商法人作为拟制主体，对外具有统一的法律资格；对内应具有统一的代表机构、执行机构和其他组织机构。

(4) 根据有关法律的规定，商法人从所有制性质上可以作如下分类：

①国有商法人。根据中国民法和企业法的规定，国家所有权和企业经营权分离，国有商业企业作为法人，具有商法上的权利能力和行为能力，经过国家工商行政管理部门核准登记注册，在经营范围内，可以依法从事各种商行为，是中国现阶段最重要的商主体，在国民经济发展中发挥着重要的作用。

②集体商法人。指由公民或集体单位组合而成的集体商业组织。

③合营商法人。指由两个以上的法人组织共同出资经工商登记注册而成立的商业企业组织。

④私营商法人。指由私人投资经营而取得法人资格并以其出资额为限承担债务责任的商业企业。

⑤外商投资商法人。即由外商投资并取得法人资格的商业企业组织，在中国现阶段，就是指中外合资经营企业。

3. 简述商号与其他商事标记的区别。

【答案】(1) 商号与商事经营者的姓名

商号仅仅是商主体的名称，商主体在从事商行为时，应该使用商号。在一般情况下，商号与商事经营者的姓名不一致。但在特殊情况下，它们可以相互一致，于此情形，则需确定使用者是否在从事商行为时使用了这一名称，否则，这一名称的使用只能视为使用者个人的行为。

(2) 商号与商店招牌

商店招牌，包括厂牌，是指商主体挂在营业所门前作为标志的牌子。它只是商主体住所地告示，起一个营业场所的广告作用。多数情况下，商店招牌与商号相一致，但有时，商主体不用商号作为招牌，而使用其他的文字、图案、符号作招牌。

(3) 商号与行号

行号是大陆法系国家商法中的一个概念，它是指商事营业所的名称。大陆法系国家的商法学家认为，行号与商号的最大区别在于，行号指明的仅仅是企业；商号指明的则是企业的承担者，即商主体。^[22]大陆法系国家商号与行号的区分，近似于我国商号与商店招牌的区

别。

（4）商号与商号缩写

西方国家商法中规定，商号缩写由商号缩略而成，它通常可以被作为电报上的地址来使用。如果商人使用的商号缩写与流行的商号缩略规则相一致，那么，这种商号缩写在法律上享有与商号同等的效力。

（5）商号与注册商标

①从性质上看，商号权属于商事人格权；商标权属于知识产权。

②从存续期限看，商号权没有存续期限限制；商标权则在理论上存在存续期限。

③从效力来看，商号权的效力只限于一定的地域内，超出了其获准注册的特定地域则不受商法保护；商标权的法律效力以一定的法域为限，可超出商号权的特定地域限制而及于全国。

④从表现形式看，商号只能用文字表示；商标则可用文字、图形或文字与图形的结合及三维图形等表示。

⑤从注册标准看，商号一般实行强制注册；商标注册则既有强制性又有自愿性，同一个商事企业可拥有多个注册商标。

（6）商号与服务商标

从性质上来讲，服务商标应属于商标范畴，只不过一般商标乃商品之商标，而服务商标乃服务之商标而已。就商品商标来说，往往一个企业因其有多种商品而拥有多个商标，而服务商标则由于是用来区分不同服务行业的标记，往往一个企业只有一个服务商标，甚至同一个行业只有一个服务商标。因此，服务商标往往对一个企业具有明显的人格标识意义，与商号较为相似。但相对而言，商号的人格标识意义，要比服务商标更为明显。

（7）商号与原产地标记

原产地标记是区分一地产品与另一地同类产品的标记。由于特定的地域，往往对特定的产品的质量具有十分重要的影响，因此一般来说不宜允许某一企业将某个原产地名称作为商标或商号使用。但对同一地区的企业来说，原产地标记则往往与其商号有着密切的联系，能够共同起到对企业的人格标识作用。不过，原产地标记毕竟不能由某一企业专有，而商号则为某一企业专有，因此两者具有十分明显的区别。

4. 简述商事登记对企业本身的法律效力。

【答案】（1）商事登记是否为企业成立之必要条件，各国立法存在颇大差异。主要有以下两种做法：

①商事登记为企业成立之必要条件，未经登记企业不能成立。在绝大多数国家法律中，对股份公司和有限责任公司以及其他商法人，都规定商事登记为其主体资格取得之要件。这种做法在理论上可称为企业成立要件主义。这样商事登记就被作为一种企业成立要件而加以确认，使其具有创设效力。

②将企业设立登记视为企业成立后依法需进行的行为，奉行先设立后登记原则，即在履行公证和其他一些手续后，企业被视为自动成立，其后再将企业设立文件提交登记机关注册登记。这种做法在理论上可为企业成立非要件主义，其法律效力则表现为商事登记的公示性。

（2）我国大陆的做法较为特殊，难以归入上述两种立法原则之中。依照我国商事登记的相关规定，商事登记是各类企业成立的必要条件；未经商事登记程序，行为人即使以企业名义实施了商事经营活动，也不得享有企业的权利，同时也不必履行企业的义务，该行为可认定为无效行为。在我国，根据工商登记法规的规定，商事登记不仅是企业法人取得法人资格的前提条件，也是非法人企业取得商事经营活动资格的前提条件。我国法律严禁未经登记的无证照经营行为。

5. 如何理解我国现行商号制度的缺陷？

【答案】我国现行商号制度存在的缺陷主要有以下两方面：

（1）在我国，商号权制度被企业名称制度取代。按照现行企业注册登记制度，除了商号以外，企业名称还包括行政区划、行业特点和组织形式等要素。但其中只有商号才是企业真正的标记，其余三个因素则往往是在一定行政区划内与其他众多的企业所共同使用的因素，它们既不为其中任何一个企业所拥有，也不为这些相关的企业所共有。这种分级登记的制度，使共同存在于同一城市或同一行政辖区内的不同企业大量使用了足以使人产生误解的相同或相似的商号。

（2）在我国经济生活实践中，存在大量的恶意利用他人尤其是知名企业商号的行为，使公众在不知情的情况下，误认为该利用他人商号的企业与知名企业之间存在隶属关系或其他关联关系，从而基于对知名企业的信任而产生对该企业的信任。这种行为对于我国公平竞争的健康的市场环境的建设极其有害，对于被冒用的知名企业来说，更是会造成严重的经济损失，更为严重的还会造成其良好信誉的损失。因此，法律必须对这种侵权行为加以制裁，使侵权人受到相应

法律制裁的同时，使受害人得到合理的经济补偿，并借此维护市场竞争秩序。

（3）恶意利用其他企业商号的侵权案件一再发生，说明我国的商号登记制度确实存在一些问题，需要有关方面积极努力予以完善。但问题是，在相关法律制度完善之前，行政执法部门尤其是作为行使最后裁决权的司法机关——人民法院，还是应当争取在现有的法律与制度框架内使问题得到合理的解决，维护公平有序的市场竞争秩序及当事人的合法权益。因此，在现有制度下，迫切需要对知名商号加以切实保护，需要创造性地类推适用关于知名商标保护制度予以处理。

6. 简述商事登记的特征。

【答案】尽管各国商事登记立法并不完全统一，但根据各主要国家商事登记立法的规定，可以认为，商事登记主要有以下法律特征：

（1）商事登记是导致商主体设立、变更或终止的法律行为，其目的在于获得商主体的资格与能力得以确立或使其发生变化的法律效果。在绝大多数国家，对一般生产经营者来说，商事登记都是其取得合法主体资格的必要和唯一的途径。登记行为是创设、确立与变更商事法律关系的基本要素，属于商法体系中不可缺少的组成部分。

（2）商事登记是一种要式法律行为，必须按照法定要求将法定事项在法定主管机关办理，其行为的内容与方式都必须符合法定要求。商事登记注册的内容与事项往往由商事特别法以强制性条款的形式规定并具体列明。由于商事活动涉及社会生产的各个领域，必须对其严格监控，因此需要一定的登记程序以维持国家的监管。这样，商事登记就必须严格按照法律规定的有关条件与程序办理，否则不能产生相应法律效力。在具体形式上，商事登记必须采取规范的书面形式，登记机关不会受理单纯的口头登记申请。商事登记的申请人则必须依照法定程序并采取法定的格式，向法定商事登记主管机关提出申请。

（3）商事登记在本质上是一种带有公法性质的行为。与一般私法乃以平等主体之间的财产关系和人身关系为其调整对象不同，商事登记法的多数规范并不以平等主体间的权利义务关系为其调整对象。

①从商事登记主管机关的表现形式看，绝大多数国家的商事登记主管机关都属于国家机关。

②从商事登记申请人角度来看，其权利和义务并不以平等当事人为相对人，而是以作为国家机关的登记机关作为相对人。此时国家机关与商事登记申请人办理登记行为时，也不是以民法之机关法人这种民事主体身份出现，而是行使国家权力。

7. 简述商事账簿的种类及其效力。

【答案】（1）商事账簿的种类

商事账簿的种类主要包括：

①会计凭证

会计凭证是指记录商主体日常经营活动情况并作为依据的书面证明，是登记商事账簿的依据。根据法律的规定，商主体在经营活动中所作出的货币收付、款项结算、货物进出、财产增减等都必须由经办人员取得或填制会计凭证，并在会计凭证上签字盖章，以此作为结算的依据。没有会计凭证不得收付款项、不得进出财物、不得进行财产处理。会计凭证所记载的事项必须真实、客观、可靠，商主体不得作出虚假会计凭证。

会计凭证分为原始凭证和记账凭证两类：

a. 原始凭证又称单据，是指在商事交易时取得或填制的用以记录或证明交易发生和完成状况的原始书面证明。它是进行会计核算的原始资料。

b. 记账凭证又称分录凭证、记账凭单，是指根据审核后的原始凭证或原始凭证汇总表，按照交易业务内容予以分类而填制的，可以直接作为记账依据的凭证。

②会计账簿

会计账簿是按照一定的程序和方法，全面、系统、连续和分类记载并反映商主体经营业务活动的簿册。它通常由主管部门按一定的格式统一印制，由具有专门格式并互有联系的账册组成。

会计账簿种类很多，按其性质和用途可分为序时账簿、分类账簿和备查账簿。

a. 序时账簿又称日记账簿，是指按照交易活动发生的时间先后逐项记载交易活动内容的账簿。序时账簿又可分为普通日记账和特种日记账两种。

b. 分类账簿是指按照会计科目分类记载全部交易活动内容的账簿。

c. 备查账簿是指对一些日记账簿或分类账簿未能记载或记载不全的交易内容或项目予以补充记载的账簿。

③财务会计报告

财务会计报告是指商主体依法向政府提供或向社会披露的反映其财务状况和经营成果的书面文件。财务报告按服务对象不同可分为对内报告和对外报告；按编制和报送时间不同可分为月份报告、季度报告和年度报告。

根据我国会计法的规定，财务报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三项内容组成：

a. 会计报表，又称会计表册，它是指用货币形式综合反映商主体在一定时期内，即一定的会计期间内的生产经营活动和财务状况的一种书面报告文件。它一般是根据会计账簿的记载，按照主管部门统一印制的格式、内容和方法要求编制而成。

b. 会计报表是由商主体所提供的，证明其经营和财产状况的、具有法律效力的书面文件。它通过有重点地、简明地、全面地反映商主体的财务状况和经营状况，从而向商主体的经营管理机关、商主体的交易相对人以及政府有关部门等会计报表使用人提供必要的财务资料和会计信息。根据法律规定，会计报告主要包括资产负债表、损益表、财务状况变动表以及其他附表。会计报表附注，是指为帮助理解会计报表内容而对报表记载的相关事项作出的解释。

c. 财务情况说明书，是指为了方便会计报表的使用者而对商主体的财务情况作出成果的具体说明。

（2）商事账簿的效力

①对于商事交易各方，它是进行财务清点核算的重要依据。

②对于商事主管部门，它是进行稽查审计、计算税率、资产评估等的重要依据。

③在法律诉讼中，它具有重要的证据效力。

8. 简述商事名称的特点及构成要素。

【答案】商事名称，是指各种商事主体在营业活动中所使用的，与同类主体相互区别的独特文字标志，是商人制度的重要组成部分。

（1）商事名称的特点

①商事名称仅仅是一个名称，这个名称不是法律上权利义务的承担者，不等于承担权利、义务的行为人。因此商号不等于商主体。

②商事名称是商主体用于代表自己的名称，它依附于商主体，是商主体之间相互区别的重要外在标志。

③商事名称是商主体的商事名称，也即，只有商主体在从事商行为时才可以使用这一名称。这一特征的意义在于，在一些国家中，商主体的商事名称可以与自然人的名称相竞合。

（2）商事名称的构成要素

在我国，商事名称的构成一般采用四段式结构：第一部分是主体所在地行政区域的名称；第二部分是主体的具体字号；第三部分是依

照国家的行业分类标准划分的主体行业或经营特点；第四部分是主体的组织结构或责任形式。

四、论述题

1. 试论商事主体及其构成要素。

【答案】商事主体，又称商事法律关系主体、商主体，是指依照商法的规定具有商事权利能力和商事行为能力，能够以自己的名义独立从事商事行为，在商事法律关系中享有权利和承担义务的个人和组织。

商事主体具有以下基本法律特征：

（1）商事主体由商法定

商事主体是不同于一般民事主体的特殊主体，具有特殊的权利能力和行为能力，何种组织和个人能够作为商事主体参加商事活动，并在其中享有权利、承担义务，是由商事法律、法规直接确认和赋予的。商法是个人和组织具有商事主体资格的法律依据。早期商事主体主要以行业习惯法为行为依据，有很大的行业自律性；现代商事主体已成为市场经济的主要主体，具有重要的经济和社会意义，因而各国均以商法典或单行法的方式对商事主体资格的取得与丧失、权利与义务、主体的名称及类别、行为的范围及效果等做出详细而严格的规定。

（2）商事主体依法具有商事能力

①商事主体的商事能力包括商事权利能力和商事行为能力：**a.** 商事权利能力是指商法所赋予的、商事主体能够参加商事法律关系，并在其中享有商事权利和承担商事义务的资格或能力。**b.** 商事行为能力则指在法律规定的范围内，商事主体通过自己的行为或意志独立进行商事活动，并取得商事权利和承担商事义务的一种资格或能力。

②商事主体既有商事权利能力，也有商事行为能力。不具有此种能力的个人和组织不能成为商事主体。商事能力是商事主体人格的具体内容，而商业名称或商号则是商事主体人格的表现形式，商事主体以自己的名义从事商事行为就是以其商业名称或商号从事商事行为。

③商事主体的商事能力不同于一般民事能力：**a.** 商事能力特指从事商事行为的能力；**b.** 商事能力是在一般民事能力基础上附加的能力，具有商事能力应以具有民事能力为前提，但具有民事能力，不一定具有商事能力；**c.** 商事能力的范围具有特定性和限定性，取决于商法规范的限定和商事主体设立的目的，不同的商事主体具有不同的商事能力。而民事能力中，自然人的民事能力具有普遍性和统一性，自

然人都具有相同的权利能力，行为能力的差别只因其智力发育和精神状态而有所区别。

（3）商事主体的身份或资格经商事登记而取得

商事主体本质上属于法律的拟制，是因法律赋予其权利能力和行为能力而成为商事主体的，与此同时，在程序上，这种主体身份或资格的取得必须经过商事登记。商事登记制度是商法制度的重要组成部分，商事登记最主要的内容便是商事主体登记。依据各国商事法律规定，商事主体的成立必须向注册登记机构提交规定的申请文件，办理商事登记手续，同时，从事金融、证券等特殊行业经营的商事主体的成立还必须获得特许审批。按照我国现行工商登记法规，除法律、行政法规另有规定外，任何个人或组织要从事营利性经营活动，都必须经登记取得企业法人营业执照或其他营业执照，否则即为依法应予查处的无证经营或非法经营。

（4）商事主体以从事营利性活动为其常业

商事主体的商事行为通常以营业的方式进行，即以获取利益为目的，连续、稳定地从事范围确定的经营活动。此一特点使商事主体与偶尔从事商事行为者相区别。商事主体从事商事活动，但从事商事活动的不一定都是商事主体，只有以商事活动为业者才是商事主体。商事主体资格通常是通过商事注册登记取得，并在登记的范围内从事营业活动。

2. 试述商事登记制度的立法原则。

【答案】从立法内容上看，由于立法基点不同，各国商事登记制度所奉行的立法原则不尽相同。具体来说，商事登记制度的立法原则可分为以下五种：

（1）自由设立原则，又称放任设立原则。依此原则，法律对商主体不规定任何条件和形式要求，对当事人设立企业的自由选择不予任何干涉和限制。这一原则流行于欧洲中世纪后期商业兴盛时期。由于这一制度完全否定政府对商事登记管理的必要性，具有明显的弊端，现在已基本不被采用。

（2）特许原则。依此原则，商主体的设立须经国家专门立法或国家元首的特别许可。早期欧洲国家将商人视为一种特权阶层，商人须获特许状方可经营，因此实际上实行的是特许原则。尤其是公司设立更是明显地奉行这一原则。由于这一原则对企业设立采取遏制甚至禁止的态度，干涉、限制过多，严重影响了商事交易的发展，现代立法也鲜有采用者。

(3) 行政核准原则。依此原则，企业的设立不仅应符合法律规定的条件，还需经行政机关许可，行政机关可以根据实际需要作出自由裁量的决定。应当说，这一原则以行政特许权取代君主特许权，因其限制较之特许原则相对宽松，从而大大促进了企业的设立，但其限制仍然过于严格，程序上也过于烦琐。现代国家只在少数需要特殊控制的领域仍然采用这一原则。

(4) 准则原则，又称登记原则。在这一原则下，法律对于企业的设立预先规定一定的必要条件，只要符合这些条件，无须经过行政机关的核准即可获得企业资格。这一原则大大简化了企业的设立条件与程序，适应了现代企业大量存在并经常变更的现实需要。但这一原则也有弊端，如果法律对企业设立的必要条件及责任规定不够详细与严谨，则极易产生法律漏洞，不利于交易安全的维护。

(5) 严格准则原则。与准则原则相同，根据这一原则，法律预先规定企业设立的必要条件，只要符合这些条件，无须经过行政机关的核准即可获得商主体资格。但为了维护交易安全与保障社会公共利益，法律同时规定了企业及其设立人的严格责任，使之承担因不法设立的企业而产生的责任。由于该原则既保留了准则原则的优点，又有效地克服了准则原则的缺陷，已在绝大多数国家与地区得到采行。

3. 试析商主体制度的变革取向。

【答案】商主体制度的变革取向，即从商人到企业的变革。

(1) 随着市场经济及与之相伴随的企业，商人的性质发生了根本性变化。早期的商人是指从事直接媒介财货交易行为的人，后来逐渐扩展到间接媒介财货交易行为的人，如居间商、行纪商、代理商等，再后来从事所有经营活动的人都可成为商人。变化过程中，商人的性质已从单纯从事贸易行为的人发展为从事各种经营行为的人，包括从事贸易行为、生产行为、服务行为等各种行业的经营人。

(2) 与营业性质的变化相适应，商人的结构也逐渐发生了变化，以公司为代表的各类企业不仅取得了商人资格，并且逐渐成为主导形式。企业制度在漫长的演进过程中，不断将市场交易活动内化，从而企业规模从小到大发展；从企业制度来看，各种基本生产要素的所有权不断外化，从而使企业资本从私人到社会化变化。随着生产力和商品经济的发展，各个历史时期占主导地位的企业组织形式相应地发生变化。某一企业组织形式本身也随着生产力和商品经济的发展而发展变化，其内涵往往处于变动不居的状态之中。

(3) 现代社会实施商行为基本上都要凭借一定的组织形式，通过

注册登记等方式获得相应的经营资格。由此，商法的任务就是调整企业在一定社会中的经营活动，即以企业的形态、企业的成立与消灭、企业的运营与管理、企业的资金筹措、企业的会计与决算、企业的交易等为调整内容。因此，传统商法中的商人概念，由于难以适应新的市场经济实践中市场主体的真实状况与现实需要而应当被企业概念所替代。事实上，在许多国家或地区的立法上，企业也已经部分地甚至完全取代了商人的概念。以商自然人或从事商事营业的商人（仍然是自然人）为商法体系基础的传统认识与制度设计，也已经让位于以属于人的集合体性质的企业为体系构建基础的现代认识了。

（4）在企业与商人的关系上，仍有不少西方学者认为，虽然企业是当代商法的重要调整对象，但它不等同于商人，也不能完全取代商人，相反，它仅是大大充实并丰富了商人的内容，使商人体系更加丰满、完备。

五、案例分析题

1. 2021年初，某市一家有限公司开业，公司登记名称为“××市红都时装有限责任公司”（以下简称甲公司）。同年11月，与该公司地理位置仅隔100米远的另外一条马路上，又有一家有限责任公司登记注册，名称为“××市红都制衣有限责任公司”（以下简称乙公司）。这两家虽然相隔很近，但行政区划上却不属于同一个区，因此，均分别向各自所在的区企业登记机关办理了公司名称注册登记。为此，甲公司与乙公司打起了名称权官司。

甲公司主张，该公司自2021年初经工商局批准开业以来，就一直以“红都时装公司”名称营业至今；而乙公司在此之后却用“红都制衣公司”名称，与它的名称相似而且乙公司也兼营时装，而两公司相距不远在社会上造成了一定的影响。甲公司据此认为乙公司侵犯了甲公司的名称专用权，因此请求法院判令乙公司停止使用“红都制衣公司”这一名称，并承担赔礼道歉及消除影响的民事责任。乙公司主张，本公司名称与甲公司名称不相同，登记机关也不相同，并且行业不同。根据国家有关法规规定，公司名称登记有行业之分，我方属服装加工业，而甲公司属于商品零售业，行业不同，字号可以使用同一名称，因而不存在侵权问题。

问：乙公司是否侵犯甲公司名称专用权？为什么？

【答案】

乙公司没有侵犯甲公司名称专用权。按照我国《企业名称登记管理规

定》对企业名称作出的限制规定，企业只能登记一个企业名称，企业名称受法律保护。在同一企业登记机关，申请人拟定的企业名称中的字号不得与已经登记或者在保留期内的企业名称，或者不使用行业、经营特点表述的企业名称中的字号相同，有投资关系的除外。

2. 2021年6月，A、B、C三家公司达成协议，共同投资，在人民大学附近成立一家有限责任公司——东东零售超市。三家公司共同草拟并一致通过了公司章程，章程规定新的公司注册资本90万，每家公司出资30万，出资方式有：货币、土地使用权和超市营业需要的设备等。货币出资已于7月划入东东超市的临时账户，设备和土地使用权也于8月份办理了相关的手续。8月底，东东有限责任公司委托会计师事务所验资，后该会计师事务所出具了验资证明。9月初，东东有限责任公司向工商行政管理部门申请登记，提交了公司登记的申请书、公司章程、验资证明等文件。工商局审查后，认为东东有限责任公司的法定资本和生产经营条件合格，但人大附近类似的超市已有数家，为了防止超市之间的恶性竞争和促进该地区经济有序的发展，工商局决定不予登记。后经A、B、C三家公司的共同努力，工商局同意登记。2021年底，东东超市看到代订火车票的业务十分赚钱，擅自增加代订火车票业务。2022年初，东东有限责任公司的生意滑坡剧烈，三家公司决定为该公司更名，以转换商运。

请对以上案例进行分析。

【答案】商事登记是指当事人依照法律规定向主管机关提出的，旨在设立、变更或终止商事主体资格的申请，主管机关予以注册登记的一系列法律行为。在世界范围内，不同国家对不同类型的公司设立条件有不同的规定，但总体上要求：公司设立的人数要求、资本要求和组织要求。

我国《公司法》第23条对有限责任公司的设立条件作了规定，工商部门确认了东东有限责任公司的设立条件符合法律的要求，而且该公司不属于政府进行市场准入控制的领域，因此，工商局应该给予无条件的注册，不应以公司法之外的理由对设立申请予以驳回。

依据《公司登记管理条例》第26条的规定，市场主体变更经营范围，属于依法须经批准的项目的，应当自批准之日起30日内申请变更登记。在增加代订火车票业务问题上，东东超市应向登记机关申请变更经营范围而不应擅自变更。

依据《公司登记管理条例》第8条的规定，名称属于市场主体的一般登记事项；依据《公司登记管理条例》第24条的规定，市场主体变

更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关申请变更登记。东东超市需要变更名称时也需要申请变更登记。

第三章 商事行为

一、单项选择题

1. 下列不属于特殊商行为的是（ ）。

- A. 商事代理、商事行纪、商事居间、商事信托
- B. 商事货运、商合伙、商委托
- C. 融资租赁、商事仓储、商事货运
- D. 商事行纪、商事买卖

【答案】B

【解析】

特殊商行为是指在商事交易中具有个性的，并受商法中的特别法或特别规则调整的行为。特殊商行为包括商事买卖、商事代理、商事行纪、商事居间、商事信托、商事信用、商事期货交易、商事仓储、商事货运融资租赁。

二、概念题

1. 商行为

【答案】

商行为是指商主体所从事的以营利为目的的经营行为。这个概念包含三个层次的含义：①商行为是一种行为，该行为同一定的法律规范相联系、受法律规范调整，其性质由法律所确定，它是法律行为之一种。②商行为是商主体所为的行为，与商主体这一特定身份相关，非商主体不得从事商行为。③商行为是商主体在商事经营中所为的行为，它具有商事经营这一特定的经营属性，非商事经营的行为，即使由商主体所为，也不属于商行为。

2. 基本商行为与辅助商行为

【答案】依据商事行为在同一经营活动中引起商事关系成立的作用不同，将商事行为分为：

（1）基本商行为是指直接从事营利性经营活动的商行为，如买卖商行为。基本商行为包括绝对商行为和相对商行为。

（2）辅助商行为是指其行为本身并不直接达到商主体所要达到的经营目的，但却可以对以营利为目的的商行为的实现起辅助作用，如广告行为、代理行为等。辅助商行为作为一种从属性商行为，它是相对于主商行为而言的。其实，从事辅助商行为的主体本身也是为了实现一定的营利目的而实施此行为的。

3. 绝对商行为与相对商行为

【答案】（1）绝对商行为和相对商行为是按照商行为确定的标准和条件划分的。

绝对商行为，又称为客观商行为，是指依照行为的客观性和法律的规定，无条件地属于商行为的行为。

相对商行为，又称为主观商行为，是指依照行为人的主观性和行为自身性质而认定的商行为。

（2）二者的区别主要包括：

①绝对商行为是典型的商行为，不论行为人是否以其为业，其行为都属于商行为，它是确立商人概念的基础。相对商行为是非典型的商行为，它是以行为主体是否为商人以及行为是否具有营利性为认定要件，其可能构成商行为也可能构成一般的民事行为。比如票据行为、商业证券行为、保险行为和海商行为等都属于绝对商行为。

②绝对商行为适用商法的有关规范，而相对商行为在其构成商行为时适用商法规范，其不构成商行为时适用民事法律的相关规范。

三、简答题

1. 外观主义一般被视为商法的原则之一，试举若干具体制度说明外观主义之意义。

【答案】作为商法的原则之一，外观主义是指以交易当事人行为的外观为标准，而确定其行为所产生的法律效果。根据这一主义，公示于外表的事实，纵与真实的情形不符时，对于依该外表事实所进行的商行为，亦需加以保护，以维持交易的安全。对此。法国学者称其为外

观法理，英美法系则称其为禁反言。

外观主义在商法中的具体体现如下：公司法规定，公司设立登记后有应登记之事项而未登记或已登记之事项有变更而不为变更登记者，不得以其事项对抗第三人；隐名合伙人如参与合伙事务的执行或为参与执行的表示，纵有相反的约定。对于第三人仍应负出名营业人的责任。票据上所载的出票地和出票日，即使和真实的出票地和出票日不符时，也不影响票据行为的效力。同样，对于有价证券，法律强调的是该证券的文义而非取得该证券的非文义的原因。另外，如各国商事法上关于不实登记的责任、表见经理人、表见代表董事、自称股东和类似股东者责任，票据的文义性和要式性、背书连续的证明力等规定，都体现了外观主义的要求，均赋予行为外观之优越效果，以确保交易之安全。

2. 简述商行为的商法学分类及其意义

【答案】（1）商行为的商法学的分类

①绝对商行为与相对商行为

a. 绝对商行为是指依照行为的客观性和法律的规定而必然认定的商行为。它不以行为主体是否为商人和行为本身是否具有营利性为认定要件，仅仅以行为的形式为认定要件。在许多国家，票据行为、证券交易行为、融资租赁行为、保险行为、海商行为等均为绝对商行为。绝对商行为通常由法律限定列举，不得作推定解释。

b. 相对商行为是指依行为的主观性和行为自身的性质而认定的商行为。它以行为主体是否为商主体和行为是否具有营利特性为认定要件。凡由商人所从事的营利行为即商行为。

②单方商行为与双方商行为

a. 单方商行为是指行为人一方是商主体而另一方不是商主体所从事的行为。对于单方商行为的法律适用，各国商法的规定不尽相同。大陆法系国家商法通常规定，只要行为人中有一方为商人，其交易双方都应适用商法。但英美法系国家商法则规定，当行为人中只有一方为商人，该商人适用商法，作为另一方的非商人不适用商法。

b. 双方商行为是指当事人双方都为商主体所实施的营利性经营行为。双方商行为适用商法。

③基本商行为与辅助商行为

a. 基本商行为是指直接从事营利性经营活动的商行为，如买卖商行为。辅助商行为是指其行为本身并不直接达到商主体所要达到的经营目的，但却可以对以营利为目的的商行为的实现起辅助作用，如广

告行为、代理行为等。

b. 辅助商行为作为一种从属性商行为，它是相对于主商行为而言的。其实，从事辅助商行为的主体本身也是为了实现一定的营利目的而实施此行为的。

④固有商行为与推定商行为

a. 固有商行为是指商主体所实施的营利行为或商法典所确定的商行为。

b. 推定商行为是指拟制商主体所实施的经营性商行为。这种商行为常常不能根据法律的规定来确认商行为的性质，而需要根据该行为本身的性质来推定其商行为性质，如非商主体所实施的信息咨询等。

(2) 商行为的商法学分类的意义

①明确散存商行为的法律归属

在我国现行法律体系中，由于不存在形式意义上的商法，在立法上也未确立商行为概念。但存在着实质意义上的商法，实质意义上的商行为也在《证券法》《保险法》《票据法》及《民法典》等法律中大量存在。因此，商行为的商法学分类有利于对这些散存的商行为进行系统的理论界分，从而明确其法律属性的归属。

②明确商行为的法律适用

商行为的商法学分类，有利于对具有不同特征的商行为分别予以调整，针对其法律属性上的特殊性制定特殊规则，明确各种类型商行为的法律适用，确定商事法律关系主体之间的权利义务关系，妥善处理商事活动中的经济纠纷，促进商事交易活动的顺利开展。

③完善民商法立法模式与立法体系

不论我国最终是否会制定形式商法，对商行为的商法学分类问题进行深入研究，对于我国民商法的立法模式与立法体系都具有重要意义。

我国商法学界在商行为外延方面的认识虽不尽一致，但基本上都是综合大陆法系商法典关于商行为的规定而加以界定，而大多未就我国商行为的外延作理论上的设计并予以论证。从学理上对我国商行为外延予以分析，并基于该分析而对我国商法体系之商行为外延提出理论上的构建，最终形成我国商行为的类型体系。

3. 简述具体商行为制度的主要内容。

【答案】现代商法中的具体特殊商行为，在传统种类的基础之上又有了新的发展，它已经不仅仅包括传统的内容，而且还包括商事信托、商事期货、融资租赁、证券交易、银行交易、投资基金运作以及咨询

服务等内容。主要涉及以下方面：

（1）商事买卖

商事买卖是商法中最重要、最常见的特殊商行为之一，是一种特殊而专门的商事交易形式。在各国商法中，商事买卖以民事买卖为基础和出发点，但有所不同。它一般是从商事交易的迅速、明确、安全角度出发所提出的，主要涉及商事买卖中的迟延履行、商事买卖中给付标的物瑕疵责任的特殊性问题。

（2）商事代理

商事代理是指在商事交易中，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施法律行为，其结果由被代理人承担的一种商行为，商事代理是最基本的商行为之一。

（3）商事行纪

商事行纪，是指商主体以自己的名义为他人（委托人）购买或销售货物、有价证券，由此获取报酬，并以此作为职业性经营的行为。从行为角度考察，行纪行为是大陆法系国家商法中的一种典型商行为。与代理和居间不同，在民商分立的国家，只有商法典才规定有行纪商或行纪商行为；民法典中没有关于行纪的规定。因此，它是相对独立于民法典的典型商行为。

（4）商事居间

商事居间，是指商主体为获取一定的报酬（佣金）而从事的为委托人与第三人订立合同提供缔约机会或者进行介绍，以促成合同订立的行为。与代理一样，商事居间以民事居间法律关系为其构成和存在的基础，但两者在主体、客体和内容方面都存在着颇为重要的差异。这种差异产生的根本原因在于，作为商行为，商事居间的营利性特征导致其行为的构成、行为的有效性以及行为之后果等方面有别于民事居间的特殊性。

（5）商事信托

商事信托，是指为筹集有效资本，并基于此创造出适用于个人、企业和其他组织的共同参与的资本经营模式，将信托适用于商事领域，是以获取商业利益为目的的商事法律行为。信托最初是英美法系中的一个概念，现已被大陆法系国家商法广泛接受。信托又称为信任委托，它是指委托人将其财产移转到受托人，受托人以自己的名义依照委托人的指定，为受益人的利益或特定目的，管理或者处理财产的行为。

商事信托种类繁多，它已经涉及现实经济生活的许多方面。常见的商事信托主要有投资基金信托、附担保的公司债信托、贷款信托、设备买卖融资担保信托、公司股东表决权信托、雇员受益信托等。

（6）商事信用

商事信用，是指在商事活动中，商品销售、提供服务、提供贷款等交易中取得商品，接受服务或贷款的一方，同意在将来规定的日期支付货款、服务报酬、贷款本息的承诺。这种承诺代表了一种保证，实际上体现了信守诺言的行为。西方社会流行的记账买卖就是一种简单的商事信用。不过，为了更好地维护商人的利益，目前的商事信用更多地与信用担保联系在一起。

（7）证券交易

证券交易，是指当事人之间在法定交易场所，按照特定交易规则，对依法发行并交付的证券进行买卖的行为。证券交易一般发生于投资者之间，但并不以投资者为要素。在特殊情况下，证券发行人亦可充当特殊的交易主体。参与证券交易的证券投资者包括个人投资者和机构投资者。在证券交易中，买入证券的人向卖出证券的人支付价金并获得证券，卖出证券的人向买入证券的人交付证券并收取价金，从而在双方当事人之间形成证券交易法律关系。

证券交易作为特殊的交易，因其在交易主体、交易对象、交易规则、交易方式、交易场所等方面均存在特殊性。因此，虽然仍有不少大陆法系国家尚未颁布调整证券发行关系的专门法律，但现代各国已大多颁布了调整证券交易关系的专门法律。

（8）期货交易

期货交易是商事买卖的一种特殊形态，它是指按照期货交易所的规定，由期货买卖双方商主体在交易所内预先签订产品买卖合同，而期货的支付和货物的交割要在约定的远期进行的一种买卖商行为。由于期货买卖具有一定的投机性，它常常从物的交易变成了期货合约的交易。与一般买卖商行为相比，其最大的差异在于：前者交易的标的是货物，而后者交易的标的更多的是合约本身；后者比前者具有更大的投机性和风险性。

（9）融资租赁

融资租赁，是指融租人和承租人双方商主体约定，融租人根据承租人的决定，向承租人选定的第三人（供货方）购买承租人选定的物件，然后将其租给承租人长期使用，以承租人支付租金的方式来收回投资的一种商行为。其实质上是传统民法中的买卖行为、租赁行为、金融信贷行为三者结合一体而创造出的一种新的商行为。它在一定程度上代表着特殊商行为在当代的发展。

（10）商事仓储

商事仓储，是指由商主体所从事的仓库经营，即货物储存和保管之商行为。在大陆法系国家商法典中，商事仓储是一种典型的商行

为。但这一商行为是以民法中寄托行为理论为基础的。

（11）商事货运

商事货运是以特定的标的物为运输对象的特殊运输商行为，是运输交易中的基本行为方式。这种商行为是一般运输商行为的基础，并与其他运输商行为保持着密切的联系。但其与旅客运输不同，前者是典型的商行为，是商法调整的对象；后者由于涉及人身问题，因此在许多国家，它不仅仅由商法调整，更多地涉及民法、旅客运输法、交通法等法律法规的调整。

四、论述题

1. 论述商事代理的概念及特征。

【答案】（1）商事代理是最基本的商行为之一。从行为角度考察，商事代理是指在商事交易中，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施法律行为，其结果由被代理人承担的一种商行为。即商代理是指商事代理人代理商事主体实施商业行为的一种商业行为。

无论大陆法系还是英美法系，商法中对商事代理都有专门规定。不过，在英美法系国家，由于没有民法传统，因此，其代理法主要是指商事代理法。而在大陆法系国家，民法是商法的基本法，代理行为在立法上分为民事代理与商事代理，并且分别规定于民法典和商法典之中。商事代理以民事代理关系为其法律关系的构成基础，但在主体、客体和内容上都存在着一定的差异。

在我国，立法上至今没有严格区分民事代理与商事代理。《民法典》对民事代理作了专门规定，而商事代理，至今还没有专门立法，司法实践中的商事代理行为通常主要参照适用《民法典》中的规定。

（2）商事代理上的法律特征：

①商事代理行为只能来源于被代理人的委托。

由于民事代理有委托代理、法定代理和指定代理三种类型，因此民事代理既可以来源于被代理人的委托，也可以来源于法律的直接规定，甚至也可以来源于人民法院或有关部门的指定；而商事代理仅系

委托代理，所以商事代理只能来源于被代理人的委托，否则商事代理就无从产生。

②商事代理行为的被代理人只能是商人。

民事代理的被代理人依法是民事主体，即公民或法人；而商事代理的被代理人只能是商人，包括商自然人、商合伙、商法人。非商人可以成为民事代理的被代理人，但依法却不能成为商事代理的被代理人。

③商事代理行为的代理人必须是依法成立的代理商。

民事代理的代理人既可以是公民，也可以是法人，只要具有民事行为能力即可；而商事代理行为是一种营业性行为，故须是经过商事登记成立的代理商。对从事银行、运输、专利、商标、证券、广告、外贸等业务的代理商，往往有较为严格的专业技术人员的资格要求。

④商事代理行为均属有偿代理。

民事代理行为既可以是有偿的，也可以是无偿的，但商事代理行为均属有偿代理。因为商事代理行为是代理人的经营性行为，代理本身就是实施商行为，必须以营利为目的。营利始终是商事代理的动因和归宿。因此，各国商法一般规定，代理商得依合同请求报酬或请求偿还其费用。

⑤商事代理行为不以“显名”为必要。

民事代理行为只有以被代理人的名义进行，才能为被代理人取得权利、设定义务。如果以自己的名义进行，就不称其为民事代理行为，而是自己的行为。这即民事代理的“显名主义”原则。商事代理行为既可以被代理人的名义进行，也可以代理人自己的名义进行。此即商事代理的“非显名主义”原则。这是商事代理行为同民事代理行为的主要区别。

（3）理论和实践意义

①在大陆法系国家商法典中，一般是从主体角度规制商事代理，称之为代理商。然而，从商事行为的角度看，商事代理是一种特殊的商事法律制度而具有区别于民事代理的特征。商事代理制度在商法理论上具有完善商事主体制度与商事行为制度的重要意义，是商法体系化、科学化的必然要求。

②《民法典》对民事代理作了专门规定，而商事代理，至今还没有专门立法，司法实践中的商事代理行为主要参照适用《民法典》中的规定，这无疑是我国目前立法上的缺失。规定和完善商事代理制度，有利于理清实践中的法律关系，针对民事代理与商事代理各自的特征予以特别规制，有利于法律制度的健全与完善。

第四章 公司法

一、单项选择题

1. 张某、林某共同出资注册一家公司，张某认缴40万元，林某认缴60万元，出资期限为2024年，林某为公司的执行董事。2年后因为项目需要，林某催促张某尽快实缴出资，张某问林某需要多少资金，林某回复需要1000万元，张某即向林某的账户汇款了400万元，林某以公司的名义向张某出具了股款收据。后林某将400万元全部投入公司的项目运营，全部亏损。下列哪项说法正确？（ ）

- A. 林某未完全履行出资义务
- B. 张某未完全履行出资义务
- C. 林某应当向张某返还400万元
- D. 张某转款中的360万元是公司资产

【答案】A

【解析】A项，林某认缴60万元且未实缴出资，因此未实际履行对公司的出资义务。

B项，张某认缴40万元且实际汇款100万元，完全履行了出资义务。

CD两项，本案的关键问题是张某向林某转款400万元的性质确认，根据案情所述，张某向林某转款的意思表示基于公司项目需要而提前履行出资义务，且公司出具了股款收据，该笔款项后续用于公司的项目运营，并非林某私用，所以应认定该400万元为张某与公司之间的资金往来，而非张某与林某个人之间的关系。至于此400万元的属性，如果公司没有进行增资的法定程序，可以分解为40万元和360万元两部分，其中40万元为张某向公司履行的实缴出资，张某完全履行了出资义务，另外360万元算作张某对公司的借款，而无论出资还是借款，此400万元货币均应认定为公司的资产。既然并非林某和张某个人间的借款，所以林某无须承担返还责任。

2. 2017年甲与乙出资设立了格罗姆公司，甲的持股比例是75%，担任公司的法定代表人。公司章程约定两股东应于2039年前缴足出资，后格罗姆公司欲吸纳丙入股，并与丙签订入股协议，约定：甲和乙应于2019年前缴足出资，此条件是丙入股格罗姆公司的必要条件。双方签字盖章，丙履行了出资义务，但格罗姆公司未修改公司章程。甲、乙应于什么时间缴足出资？（ ）

- A. 甲、乙应于2039年前缴足出资
- B. 甲应于2019年前缴足出资，乙于2039年前缴足出资
- C. 甲应于2039年前缴足出资，乙于2019年前缴足出资
- D. 甲、乙应于2019年前缴足出资

【答案】B

【解析】

丙和格罗姆公司签署的入股协议为甲和乙附加了提前履行出资的义务，根据合同相对性原则，未经甲乙同意，该负担的义务对甲和乙不能生效。但是，甲作为格罗姆公司的控股股东和法定代表人，如果对提前履行出资的事宜不同意，他不会违心地代表公司签署此协议，所以甲代表格罗姆公司签署此协议应认定甲对此义务的设定是知情且同意的，所以甲应按此约定于2019年前完成出资。《公司法》第28条第1款规定，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。格罗姆公司未经法定程序修订公司章程，没有改变股东依据原章程履行出资的责任，所以乙应按原公司章程中约定的2039年完成出资。

3. 甲、乙、丙、丁四人共同出资成立翰林公司，协商制定公司章程时甲未出席，乙、丙、丁一致同意且于章程中签字，乙伪造了甲的签字。公司成立后，四股东协商一致共同签署一协议，就股东之间的权利义务等事宜进行了约定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 四股东签署的协议是公司章程的一部分
- B. 公司章程经过四分之三的股东通过，已经生效

- C. 四股东协商一致签署的协议具有与公司章程相同的法律效力
- D. 公司章程未经工商登记不能对抗第三人

【答案】D

【解析】AC两项，股东协议与公司章程是彼此独立的两份契约，其性质、适用范围、效力等有所区别，并非包含或相同的法律关系。

B项，《公司法》第11条规定，设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。因此，发起设立公司，公司章程需经全体股东协商一致才能生效，不能部分决议。

D项，工商登记产生商事外观的效力，故未经登记不能对抗第三人。

4. 甲公司于2018年3月设立登记，工商登记中载明吴太是甲公司股东之一。但因为甲公司财务人员的疏忽，公司章程中未记载吴太，且甲公司没有制备股东名册。据查，吴太履行了出资义务，且甲公司向其出具了股款收据。下列说法正确的是（ ）。

- A. 应该综合各种要素来判断吴太是否具有股东资格
- B. 只需工商登记即能证明吴太具有股东资格
- C. 没有股东名册记载，吴太没有股东资格
- D. 没有公司章程记载，吴太没有股东资格

【答案】A

【解析】A项，《公司法》第32条规定，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。但是，股东名册是证明股东资格存在的直接证据，但并非唯一的证据，股东资格的取得应综合考虑股东与公司建立法律关系的意思表示、出资行为、权利享有、义务承担等多种因素而确定。

B项，工商登记具有公示公信效力，但被登记的股东如果存在类似非法或错误登记的情形时，未必能具有股东资格。

CD两项，股东名册、公司章程的记载属于证明股东资格的因素之

一，但并非绝对或唯一因素，即使没有股东名册或公司章程的记载，通过其他因素综合判定股东也可取得身份。

5. 安云公司是由蓝月公司和张三、李四共同出资设立的有限公司，蓝月公司派赵祥和王琳担任安云公司的董事。在安云公司运营期间，赵祥以王琳在安云公司决策时总不为蓝月公司的利益着想为由，向蓝月公司报告。蓝月公司未经安云公司其他董事同意，将王琳召回，派驻胡丽作为安云公司的董事，下列说法正确的是（ ）。

- A. 王琳一经召回就丧失了安云公司的董事身份
- B. 胡丽取得了安云公司的董事身份
- C. 赵祥和王琳应对蓝月公司尽忠实、勤勉义务
- D. 赵祥和王琳应对安云公司尽忠实、勤勉义务

【答案】D

【解析】AB两项，根据《公司法》第37条规定，股东会行使的职权之一是：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。本案中，王琳作为股东蓝月公司的代表出任安云公司的董事，其选举或更换都应该由安云公司的股东会决议，未经法定流程王琳的董事身份不会因蓝月公司召回而丧失，同样，胡丽也不能因蓝月公司的单方意思表示而取得安云公司董事身份。

CD两项，赵祥、王琳经蓝月公司指派作为股东代表，出任安云公司的董事，作为安云公司的董事，自然应该对安云公司尽到忠实和勤勉义务。

6. 成顺公司的股东胡某是公司的大股东和法定代表人，2018年12月，胡某召集股东会商议收购力耀公司的股权事宜，此次股东会没有通知持有公司百分之一股权的小股东郑某。胡某提议转让成顺公司的一块土地使用权给力耀公司作为受让股权的对价，在胡某操作下，股东会通过该决议并让秘书代替郑某签字，郑某知道后坚决不同意，诉至法院，该股东会决议效力如何？（ ）

- A. 该股东会决议无效

B. 该股东会决议可撤销

C. 该股东会决议有效

D. 该股东会决议不成立

【答案】B

【解析】《公司法》第22条第1、2款规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（四）》（以下简称《公司法司法解释（四）》）第5条规定，股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：①公司未召开会议的，但依据公司法第37条第2款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；②会议未对决议事项进行表决的；③出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；④会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；⑤导致决议不成立的其他情形。

本案中，股东会召集时应该通知而未通知小股东郑某，导致郑某没机会参会表决，且决议中郑某签字被秘书代签，此签字对郑某不生效。此情形应认定为股东会召集程序违法，属于可撤销的理由。决议效力瑕疵具有排他性，一份决议只会认定一种瑕疵状态，通过上述分析已经确认为可撤销的瑕疵状态，而不是无效或不成立的状态。

7. 零盛公司的两个股东是甲公司和乙公司。甲公司持股70%并派员担任董事长，乙公司持股30%。后甲公司将零盛公司的资产全部用于甲公司的一个大型投资项目，待债权人丙公司要求零盛公司偿还货款时，发现零盛公司的资产不足以清偿。关于本案，下列哪一选项是正确的？（ ）

A. 甲公司对丙公司应承担清偿责任

B. 甲公司和乙公司按出资比例对丙公司承担清偿责任

- C. 甲公司和乙公司对丙公司承担连带清偿责任
- D. 丙公司只能通过零盛公司的破产程序来受偿

【答案】A

【解析】

《公司法》第20条第3款规定，公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。本题中，零盛公司控股股东甲公司将零盛公司的资产全部用于甲公司的其他项目，事实上将零盛公司资产掏空，使其空壳化，构成否定零盛公司法人资格的理由，甲公司应当对零盛公司的债务承担连带责任，而零盛公司的股东乙公司并不存在滥用公司法人资格以损害债权人利益的行为，故对零盛公司的债务不承担责任。

8. 杨某持有甲有限责任公司10%的股权。该公司未设立董事会和监事会。杨某发现公司执行董事何某（持有该公司90%股权）将公司产品低价出售给其妻开办的公司，遂书面向公司监事姜某反映。姜某出于私情未予过问。杨某应当如何保护公司和自己的合法权益？（ ）

- A. 提请召开临时股东会，解除何某的执行董事职务
- B. 请求公司以合理的价格收回自己的股份
- C. 以公司的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿损失
- D. 以自己的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿损失

【答案】D

【解析】A项，虽然《公司法》第100条第3项规定持有公司10%以上股份的股东可以要求召开临时股东大会，但实际上甲公司只有杨某和何某两个股东，即使召开股东大会，股东何某也不可能投票反对自己。

B项，《公司法》第74条第1款规定，有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：①公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，并且

符合本法规定的分配利润条件的；②公司合并、分立、转让主要财产的；③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。题干所述不符合该条规定的情形，杨某不能请求公司回购其股权。

CD两项，《公司法》第149条规定，董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第151条第1、2款规定，董事、高级管理人员有本法第149条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼；监事有本法第149条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

9. 金发、牧田、杜青三人出资设立苍黄古月文化有限责任公司，后公司因经营不善倒闭。下列与清算有关的法律责任，下列选项错误的是（ ）。

- A. 如未在法定期限内成立清算组开始清算，导致公司财产贬值，债权人林庚有权主张金发、牧田、杜青对公司债务承担全部赔偿责任
- B. 如该公司未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，债权人宝华有权主张金发、牧田、杜青对公司债务承担清偿责任
- C. 如公司解散时金发尚有10万元出资未缴纳，应作为清算财产
- D. 如公司财产不足以清偿债务，债权人冯志有权主张金发、牧田、杜青在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任

【答案】A

【解析】A项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》（以下简称《公司法司法解释（二）》）第18条第1款规定，有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股

东未在法定期限内成立清算组开始清算，导致公司财产贬值、流失、毁损或者灭失，债权人主张其在造成损失范围内对公司债务承担赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。并非对公司债务承担全部赔偿责任，而是在造成损失范围内对公司债务承担赔偿责任。

B项，《公司法司法解释（二）》第20条第1款规定，公司解散应当在依法清算完毕后，申请办理注销登记。公司未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，债权人主张有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担清偿责任的，人民法院应依法予以支持。

CD两项，《公司法司法解释（二）》第22条规定，公司解散时，股东尚未缴纳的出资均应作为清算财产。股东尚未缴纳的出资，包括到期应缴未缴的出资，以及依照公司法第26条和第80条的规定分期缴纳尚未届满缴纳期限的出资。公司财产不足以清偿债务时，债权人主张未缴出资股东，以及公司设立时的其他股东或者发起人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。

10. 2017年12月阿里久久公司发起人春花以自己的名义与万达广场签订了800平方米房屋租赁合同，阿里久久公司于2018年3月8日成立并在该场地办公。现万达广场以阿里久久公司欠付租赁费为由，要求该公司支付租赁费。关于本案，下列选项正确的是（ ）。

- A. 万达广场只能要求春花支付租赁费
- B. 万达广场只能要求阿里久久公司支付租赁费
- C. 万达广场有权要求阿里久久公司支付租赁费
- D. 万达广场有权要求春花与阿里久久公司承担连带责任

【答案】C

【解析】

发起人是指为设立公司而签署公司章程、向公司认购出资或者股份并履行公司设立职责的人。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（以下简称《公司法司法解释

（三）》）第2条规定，发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人请求该发起人承担合同责任的，人民法院应予支持。公司

成立后合同相对人请求公司承担合同责任的，人民法院应予支持。本题中，阿里久久公司发起人春花以自己的名义签订合同，阿里久久公司已经成立并在该场地办公，实际享有合同权利，因此万达广场有权要求春花和阿里久久公司支付租赁费。

二、多项选择题

1. 泰旭公司经营良好，但近几年没有给股东分配利润，小股东张某非常不满。现查明：泰旭公司董事长郭某和与泰旭公司有重要且经常生意往来的幻景公司董事长黄某是夫妻，泰旭公司与幻景公司存在巨额的业务往来，对幻景公司存在利益输送。张某要求监事会维护公司权益，监事会不置可否。关于张某的维权事宜下列说法正确的有（ ）。

- A. 张某的维权诉讼，泰旭公司应为第三人
- B. 张某的维权诉讼，应以郭某和监事会为共同被告
- C. 张某的维权诉讼，应以公司为被告
- D. 张某的维权诉讼中，公司其他股东以相同诉讼请求申请参加诉讼的，应列为共同原告

【答案】A|D

【解析】

《公司法司法解释（四）》第24条规定，符合公司法第151条第1款规定条件的股东，依据公司法第151条第2款、第3款规定，直接对董事、监事、高级管理人员或者他人提起诉讼的，应当列公司为第三人参加诉讼。一审法庭辩论终结前，符合公司法第151条第1款规定条件的其他股东，以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告。董事长郭某通过关联交易，损害公司利益，小股东可穷尽内部救济流程后，以自己的名义提起代位诉讼，在此诉讼中，原告为股东，被告为侵权人郭某，公司是第三人，有相同请求的其他股东列为共同原告。

2. 甲、乙是某有限责任公司股东，甲、乙分别持有公司51%和49%的股权，公司章程约定公司外部的人如果加入公司需内部股东一致同意。2018年10月甲想把持有的公司51%的股权转让给外部的第三人

丙，但乙不同意，于是，甲提出只转让0.1%的股权给丙，乙便同意了甲的请求。在丙成为公司的股东后，甲于2018年12月把自己持有的剩下50.9%的公司股权也转给了丙，并且办理了股权登记证明，这时候乙出来反对。关于两次股权转让是否有效，下列说法正确的是？
()

- A. 甲的第一次股权转让有效
- B. 甲的第一次股权转让无效
- C. 甲的第二次股权转让有效
- D. 甲的第二次股权转让无效

【答案】A|C

【解析】AB两项，《公司法》第71条第2款规定，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。本题中，该有限公司章程规定，股权对外转让必须经所有股东一致同意方有效，并不是禁止股权对外转让，体现了股东的意思自治，该章程约定合法有效。在第一次股权转让中，甲向丙转让0.1%的股权，经过了乙的同意，并且办理了股权变更登记手续，所以该次股权转让行为有效。

CD两项，《公司法》第71条第1款规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。由于没有新的股东加入进来，有限公司的人合性并没有受到破坏，因此有限公司中，股权在内部转让无须通知其他股东，也无须其他股东同意，除非公司章程另有约定。本题中，在丙已经成为公司的股东后，甲再次向丙转让股权就属于股东之间的内部股权转让，故甲无须通知乙，也无须征得乙的同意，该次股权转让行为有效。

3. 2016年，由陈某和周某共同创办了逐月有限公司，其中陈某持有公司67%的股权，并担任董事长、法定代表人。公司章程规定，只要公司可分配利润超过10万元，即向周某分配10万元，剩余部分向陈某分配。2017年公司业务不佳，税后利润提取公积金后，公司可分配利润

仅为11万元。当年股东会会议中，陈某以周某业务能力差、对公司贡献少为由，主张将可分配利润全部分配给自己，不向周某分配。该决议两股东均签字，但周某注明了反对意见。据此，当年全部利润均分配给了陈某。对此，下列说法正确的是？（ ）

- A. 周某可以主张该决议无效
- B. 周某可以主张撤销该决议
- C. 周某可以主张公司赔偿其损失
- D. 周某可以主张陈某赔偿其损失

【答案】BD

【解析】AB两项，《公司法》第22条第1款、第2款规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。本题中，公司章程规定了利润分配的条件，公司2017年可分配利润为11万元，超过10万元，应当按照章程规定向周某分配10万元，剩余1万元向陈某分配。但股东会会议决议违反该章程规定，把当年全部利润分配给了陈某，属于股东会决议内容违反公司章程，系可撤销之诉的情形，并不是决议内容违法的无效之诉的情形，故周某可请求法院撤销该决议。

CD两项，《公司法》第20条第1款、第2款规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。本题中，陈某作为公司大股东，滥用股东权利，违反公司章程，损害了小股东权利，周某可以要求陈某赔偿其损失。公司对周某并没有损害行为，因此周某无权要求公司赔偿其损失。

4. 顺昌有限公司等五家公司作为发起人，拟以募集方式设立一家股份有限公司。关于公开募集程序，下列哪些表述是正确的？（ ）

- A. 发起人应与依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销公开募集的股份
- B. 证券公司应与银行签订协议，由该银行代收所发行股份的股款
- C. 发行股份的股款缴足后，须经依法设立的验资机构验资并出具证明
- D. 由发起人主持召开公司创立大会，选举董事会成员、监事会成员与公司总经理

【答案】A|C

【解析】A项，《公司法》第87条规定，发起人向社会公开募集股份，应当由依法设立的证券公司承销，签订承销协议。

C项，《公司法》第89条第1款规定，发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。发起人应当自股款缴足之日起30日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

B项，《公司法》第88条第1款规定，发起人向社会公开募集股份，应当同银行签订代收股款协议。据此，应当由发起人而不是证券公司与银行签订股款代收协议。

D项，《公司法》第113条第1款规定，股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。因此，选举公司总经理的职权归属于董事会而非创立大会。

5. 如梦公司成立于2015年，股东是常记公司以及张溪亭、王日暮。章程规定公司的注册资本是1000万元，三个股东的持股比例是5:3:2；各股东应当在公司成立时一次性缴清全部出资。常记公司将之前归其所有的某公司的净资产经会计师事务所评估后作价500万元用于出资，这部分资产实际交付给如梦公司使用；张溪亭和王日暮以货币出资，公司成立时张溪亭实际支付了100万元，王日暮实际支付了50万元。关于各位股东的出资，下列说法正确的是（ ）。

- A. 常记公司履行了自己的出资义务
- B. 张溪亭和王日暮没有完全履行自己的出资义务

- C. 张溪亭和王日暮应当承担继续履行出资义务及违约责任
- D. 如张溪亭和王日暮没有完全履行自己的出资义务，常记公司无须承担连带责任

【答案】A|B|C

【解析】

《公司法司法解释（三）》第13条第3款规定，股东在公司设立时未履行或者未全面履行出资义务，依照本条第一款或者第二款提起诉讼的原告，请求公司的发起人与被告股东承担连带责任的，人民法院应予支持；公司的发起人承担责任后，可以向被告股东追偿。

6. 南方有限公司有9个股东，2019年5月，公司经股东会决议，决定变更为南方股份公司。下列选项错误的是（ ）。

- A. 该股东会决议应由6个以上股东同意
- B. 该股东会决议应由出席会议2/3以上表决权的股东同意
- C. 南方股份公司董事长由全体董事的过半数选举产生
- D. 南方股份公司副董事长由出席董事的过半数选举产生

【答案】A|B|D

【解析】AB两项，根据《公司法》第43条规定，股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。代表2/3以上表决权的股东不一定是6名以上。

CD两项，根据《公司法》第109条规定，董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

7. 泰瑞有限公司于2017年3月成立，章程规定公司对外投资比例不得超过公司注册资本的60%。2018年2月，在未召开股东会的情况下，以全体股东在决定文件上签名、盖章的形式通过了与鸿盛公司合并的1号决议。2018年9月，泰瑞公司召开股东会，准备对外投资新能源汽车业

务，投资额达到公司注册资本的80%，全体股东一致同意并通过该2号决议。关于这两个决议，下列说法错误的是（ ）。

A. 1号决议不成立

B. 2号决议无效

C. 如股东对2号决议提起撤销之诉，法院应当要求股东提供相应担保

D. 如2号决议无效，则泰瑞公司对外投资新能源汽车业务，与善意第三人形成的合作研发协议无效

【答案】A|B|C|D

【解析】A项，《公司法》第37条规定，股东会行使的职权是对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。虽然泰瑞有限公司在作出与鸿盛公司合并的1号决议没有召开股东会，但全体股东在决定文件上签名、盖章，则1号决议成立且有效。

B项，《公司法》第22条规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。2号决议违反了章程的规定，其决议没有违反法律和行政法规的规定，则2号决议为可撤销决议，而不是无效。

C项，《公司法》第22条规定，股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。股东对公司决议提出撤销之诉，人民法院可以要求股东提供担保，而不是应当。

D项，《公司法司法解释（四）》第6条规定，股东会或者股东大会、董事会决议被人民法院判决确认无效或者撤销的，公司依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。2号决议为可撤销决议，当法院判决确认无效或撤销时，泰瑞公司对外投资新能源汽车业务，与善意第三人形成的合作研发协议不受决议效力的影响。

8. 甲、乙、丙、丁4人共同出资设立华光有限公司，出资比例分别为60%、20%、15%、5%。因产品质量好、价格优惠，自开始经营起持

续盈利。但甲、乙不和，公司已连续3年未召开股东会。下列选项错误的是（ ）。

- A. 即使乙尚未完全履行出资义务，乙仍可申请法院解散公司
- B. 丁可单独申请法院解散公司
- C. 华光有限公司持续盈利，因此公司经营管理不存在严重困难
- D. 若公司解散，应由董事组成清算组进行清算

【答案】B|C|D

【解析】A项，《公司法》第182条规定，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。因此，构成公司解散诉讼的原告仅要求属于“持有公司全部股东表决权10%以上”记载于股东名册上的股东，而不要求出资完毕。

B项，由于丁的持股比例仅为5%，达不到提起公司解散诉讼要求的10%，故丁不得单独提起公司解散诉讼。

CD两项，《公司法司法解释（二）》第1条规定，单独或者合计持有公司全部股东表决权10%以上的股东，以下列事由之一提起解散公司诉讼，并符合公司法第182条规定的，人民法院应予受理：①公司持续2年以上无法召开股东会或者股东大会，公司经营管理发生严重困难的；②股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续2年以上不能做出有效的股东会或者股东大会决议，公司经营管理发生严重困难的；③公司董事长期冲突，且无法通过股东会或者股东大会解决，公司经营管理发生严重困难的；④经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形。公司的盈利或亏损状态不是判断公司是否应当解散的主要原因，即使公司持续盈利，若股东会表决机制失灵，仍可认定为经营管理发生了重大困难。

D项，由于该公司的形式为有限责任公司，因此解散后的清算组应由股东组成。

9. 西南公司经决议分立为西云公司和南树公司，西云公司与西南公司的债权人彭某达成书面协议，西云公司承担50%的债务。后南树公司决定减资80万元，账务处理为偿还季某对公司的债权80万元，以满足

其之前提出的退股要求。对此，下列说法正确的是（ ）。

- A. 西南公司应当变更登记为西云公司与南树公司
- B. 西云公司与彭某的书面协议对南树公司有约束力
- C. 彭某在南树公司减资时有权要求南树公司提前清偿债务
- D. 彭某有权要求季某在80万元本息范围内对南树公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任

【答案】CD

【解析】A项，《公司法》第179条规定，公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。西南公司分立为西云公司和南树公司，属于新设分立，西南公司办理注销登记，西云公司和南树公司办理设立登记。

B项，《公司法》第176条规定，公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。公司可以在分立前与债权人达成书面约定，但分立后其中一个公司与债权人达成的约定并不能对另一个公司产生约束力，分立后的两个公司仍需对公司分立前的债务承担连带责任。

C项，《公司法》第177条规定，公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

D项，《公司法司法解释（三）》第12条规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：①制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；②通过虚构债权债务关系将其出资转出；③利用关联交易将出资转出；④其他未经法定程序将出资抽回的行为。第14条规定，公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承

担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。

三、不定项选择题

1. 某上市公司因售出产品发生质量问题，销售单位对顾客的处理方案不妥当，引发舆论的负面评价，因此股价不正常下跌。为了扭转股价下跌的趋势，公司拟用未分配利润回购公司股份，关于该公司的股份回购下列说法正确的有（ ）。]

- A. 该回购事项需通过股东大会决议
- B. 回购股份不能超过已经发行股份的10%
- C. 股份回购应通过公开集中交易进行
- D. 公司回购的股份应当在半年内注销或转让

【答案】B|C

【解析】《公司法》第142条规定，公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外：上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司因前款规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第1款规定收购本公司股份后，属于前述情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

A项，本案所述情形属于上述情形，上市公司为了维护公司价值和股东权益而托盘维稳，出手救市，为顺应资本市场的需求，决策需要快，故可授权2/3以上董事出席的董事会进行决议，并非必需股东大会。

BD两项，基于资本市场的运作需求，回购量和持有时间均有所加大延长，公司持有的股份总额不能超过已发行股份总额的10%，且允许于3年内处理。

C项，某公司是上市公司，上市公司因资本市场需求回购股份还需要进行信息披露并通过公开集中交易方式进行。

2. 紫霞股份有限公司是一家从事游戏开发的非上市公司，注册资本5000万元，已发行股份总额为1000万股。公司成立后经营状况一直不佳，至2015年底公司账面亏损3000万元。2016年初，公司开发出一款游戏，备受玩家追捧，市场异常火爆，年底即扭亏为盈，税后利润达7000万元。

1). 2016年底，为回馈股东多年的付出，紫霞公司决定分配利润。此时公司的法定公积金余额仅为5万元。就此次利润分配行为，下列选项正确的是（ ）。

- A. 公司应提取的法定公积金数额为400万元
- B. 公司可提取法定公积金的上限为税后利润的一半，即3500万元
- C. 经股东会决议，公司可提取任意公积金1000万元
- D. 公司向股东可分配利润的上限为3605万元

【答案】A|C|D

【解析】《公司法》第166条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

A项，公司法定公积金余额5万元，不足以弥补以前年度亏损，所以应当先将税后利润7000万元弥补亏损3000万元。剩余4000万元再提取10%即400万元列入法定公积金。

B项，法定公积金的提取数额为税后利润的10%而非50%。

C项，任意公积金的提取比例由股东会或者股东大会决定。因此，经股东会决议，公司可提取任意公积金1000万元。

D项，公司在分配2016年税后利润7000万之前，应当先弥补往年亏损3000万元，再计提400万的法定公积金，如此还剩下3600万利润可供分配。但是由于公司可用2016年底的5万元公积金来弥补亏损，则从2016年税后利润中用来弥补亏损的只需2995万，如此弥补亏损加上计提法定公积金之后的剩余利润为3605万元。所以，公司向股东可分配利润的上限为3605万元。

2). 如紫霞公司在2016年底的分配利润中，最后所提取的各项公积金数额总计为2800万元，关于该公积金的用途，下列选项正确的是（ ）。

- A. 可用于弥补公司2016年度的实际亏损
- B. 可将其中的1500万元用于新款游戏软件的研发
- C. 可将其中1000万元的任意公积金全部用于公司资本的增加
- D. 可将其中1000万元的法定公积金用于公司资本的增加

【答案】B|C

【解析】ABC三项，《公司法》第168条第1款规定，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。据此，公司公积金可以用于弥补公司日后经营中的亏损，但是不可能用于弥补公司当年的亏损，因为只有在弥补了2016年当年的亏损之后，才可能提取公积金，不可能再用公积金去弥补当年的亏损。公积金可以用于扩大生产，也可以用于转增资本。

D项，《公司法》第168条第2款规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。本题中，转增前公司注册资本为5000万元，公司转增注册资本后其法定公积金留存不得少于1250万。因为公司2016年的法定公积金数额只有405万元，少于转增前公司注册资本的25%，故不能用于转增注册资本。

3). 明星股份公司董事长艾某自行决定以公司财产为股东黄某提供担保，后又利用职务之便，将原本以公司名义谈好的一笔交易让给其亲戚经营的公司。加入公司刚满1个月的股东范某（持股0.5%）和陈某（持股0.5%）对此表示不满。下列说法正确的是（ ）。

- A. 艾某是董事长，也必然是法定代表人，其行为应视为公司的行为
- B. 以公司财产为黄某提供担保应当经公司董事会同意
- C. 公司监事会若起诉艾某，应当列公司为原告

D. 范某和陈某在穷尽公司内部救济的情况下可以联合起诉艾某

【答案】C

【解析】《公司法》第13条规定，公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。艾某是公司的董事长，但并不必然是公司的法定代表人，谁是公司的法定代表人取决于公司章程的规定。

B项，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。可见，公司为股东黄某提供担保应当经股东会或者股东大会同意。

C项，《公司法司法解释（四）》第23条规定，监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事依据公司法第一百五十一条第一款规定对董事、高级管理人员提起诉讼的，应当列公司为原告，依法由监事会主席或者不设监事会的有限责任公司的监事代表公司进行诉讼。

D项，《公司法》第151条规定，董事、高级管理人员有本法第149条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼。本案中两名小股东的持股数量加起来虽然达到了1%的最低要求，但两名股东加入公司刚满1个月，并不满足连续180天以上持股的时间要求。

四、概念题

1. 股份有限公司

【答案】

股份有限公司简称股份公司，是指由一定人数的股东发起设立的，并可以通过发行股票筹集资本，全部资本分为均等的股份，股东以其所认购的股份为限对公司债务承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。

2. 股份与股权

【答案】（1）股份是指股份有限公司股东所持有的公司资本的基本单位，是股东权存在的基础和计量单位。从股份与股票的关系看，股份是股票的价值内涵，股票是股份的存在形式。准确地说，股份是指以股票这种有价证券形式表现的、股份有限公司的最基本的资本构成单

位，也是股东权的最小计量单位。

（2）股权，即股东权，可作狭义和广义两种理解。狭义的股权，是指股东因向公司出资而享有的权利。而广义的股权，则是对股东权利和义务的总称。股权是任何公司类型中的股东都普遍享有的权利。

（3）股份是只存在于股份有限公司中的概念，股份有限公司的资本分成等额股份，股权与所持股份相一致，一股一权，数股数权；而股权则既可指股份有限公司的股东权，也可指有限责任公司的股东权。

3. （公司的）发起设立

【答案】

发起设立又称共同设立或单纯设立，是由发起人认足全部资本额而促成公司成立的一种设立方式。无限责任公司、两合公司和有限责任公司均属于封闭性公司，不能向社会发行股份，因此，只能采取发起方式设立公司。发起设立具有设立程序简单的优点，通常被认为是中小型企业公司所常采用的一种设立方式。

4. （公司的）募集设立

【答案】

募集设立是指公司发起人只认购部分股份，其余部分则通过公开向社会招募的方式而成立公司的一种设立方式。我国的募集设立可以分为社会募集设立和定向募集设立两种形式。社会募集设立，是指公司发行的股份除由发起人认购外，其余股份应向社会公众公开发行。定向募集设立，是指公司发行的股份除由发起人认购外，其余部分可向特定法人或特定自然人（如内部职工等）发行，但不公开向社会发行。

5. 授权资本制与法定资本制

【答案】（1）授权资本制，是指在公司设立时，资本总额虽应记载于章程，但并不要求发起人全部认缴，只认定并缴付资本总额中的一部分，公司即可成立，未认定部分，授权董事会根据需要，随时发行新股募集的资本制度。

（2）法定资本制，又称确定资本制，是指公司在设立时，必须在章程中对公司的资本总额作出明确的规定，并须由股东全部认缴，否则公司即不能成立的资本制度。

（3）授权资本制与法定资本制都是具有代表性的资本制度，两者

的区别主要在于授权资本制在公司设立时不需发起人认缴资本总额，公司在成立后可以随时由董事会决定募集新股；法定资本制则要求股东必须认缴资本总额，否则公司不能成立，公司成立后增加资本必须由股东大会作出决议。

6. 公司治理

【答案】

公司治理，是指为适应公司的产权结构，以出资者（股东）与经营者分离、分立和整合为基础，连接并规范股东会、董事会、监事会、经理相互间权利、利益、责任关系的制度安排。它包括公司的组织结构及其运行机制两个方面。组织结构是指由公司的意思形成机构、业务执行机构和内部监督机构构成的完整的、有机的、科学的组织系统；运行机制是指股东会、董事会、监事会、经理等公司组织机构在公司运营过程中的激励、监督和制衡机制。

7. 独立董事

【答案】

独立董事是指公司在董事会中设立的由专家等独立人士担任的非执行董事（也称为外部董事）。独立董事制度主要是通过董事会中设置无利害关系同时又具有一定专业知识的独立董事，起到对公司运作提供咨询、顾问和监督的作用。独立董事制度的意义主要在于帮助保持董事会的独立性，维护所有股东利益，增加股东价值；以其专业知识协助管理层对公司进行科学有效的管理，提升公司的效益。

8. 公司合并]

【答案】公司合并，是指由两个或两个以上的公司依法达成合意，归并为一个公司或创设一个新的公司的法律行为。合并的方式包括吸收合并和新设合并。吸收合并是指一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。新设合并是指两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

公司合并的特点包括：①除在吸收合并中吸收公司存续外，其他公司均归于消灭。②合并后消灭的公司的股东自然成为合并后存续公司或新设公司的股东。③因合并而消灭的公司的资产及债权债务，一并转移至合并后存在的公司或新设的公司，无须经过清算程序。④合并是参与合并的公司之间的契约行为，不是股东之间的契约行为。

9. 股东代表诉讼

【答案】

股东代表诉讼，又称派生诉讼、传来诉讼、代位诉讼，是指在公司经营过程中当董事、监事、高级管理人员执行公务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，而公司董事会、监事会或股东大会对此不提起诉讼，由公司一个或多个股东代表公司对违法、加害的董事、监事或公司高级管理人员提起的诉讼。

五、概念题

1. 简述公司章程记载事项的分类。

【答案】依据法律对公司章程记载的事项有无明确规定，以及所记载事项对章程效力的影响，章程的记载事项可分为绝对必要记载事项、相对必要记载事项和任意记载事项。

（1）绝对必要记载事项，是指法律规定的章程中必须予以记载的、不可缺少的事项。公司章程缺少其中任何一项或任何一项记载不合法，就会导致整个章程的无效。对于章程的绝对必要记载事项，各国公司法都予以明文规定，主要是公司性质所要求的章程的必备条款，通常包括公司的名称、住所地、经营范围、注册资本、利润分配、财产责任等。

（2）相对必要记载事项，是指由法律列举规定的、可以听凭章程制定人自主决定是否载入章程的事项。此类事项一旦章程予以记载，便发生效力。如果不予记载或某项记载不合法，则仅该事项无效，章程的其他事项仍然有效，不影响整个章程的效力。

（3）任意记载事项，是指只要不违反法律的强行规定、公共秩序和善良风俗，章程制定人便可根据实际需要载入章程的事项。此类事项只要记载于公司章程，便与其他事项同样具有约束力，非依股东会的特别决议不能变更。如不记载，不影响整个章程的效力；如记载不合法，也仅该事项无效，章程的其他事项仍具效力。

2. 有限责任公司的主要法律特征。

【答案】有限责任公司具有以下特征：

（1）股东人数的限制性。对有限责任公司的股东人数，凡是不承认一人公司的国家的公司法都有下限和上限的规定，一般规定股东人

数为2人以上30人或50人以下；凡是承认一人公司的国家的公司法一般仅规定股东人数的上限，而无下限的规定。

（2）股东责任的有限性。有限责任公司的股东，仅以其出资额为限对公司负责。此外，对公司及公司的债权人不负任何财产责任，公司的债权人亦不得直接向股东主张债权或请求清偿。这是有限责任公司与无限责任公司的根本区别。

（3）股东出资的非股份性。有限责任公司的资本，除采取“出资平等制”或“复数股份制”的国家外，一般不分为股份，每个股东只有一份出资，但其数额可以不同，股东仅以其出资额为限对公司负责。

（4）公司资本的封闭性。有限责任公司的资本只能由全体股东认缴，不能向社会募集股份，不能发行股票。

（5）公司组织的简便性。有限责任公司的设立程序简便，只有发起设立，而无募集设立；有限责任公司的组织机构亦较简单、灵活，其股东会由全体股东组成，董事由股东会选举产生；股东会的召集方法及决议的形成程序亦较简便。

（6）资合与人合的统一性。有限责任公司虽然从本质上说是一种资本的联合，但因其股东人数有上限的规定，资本又具有封闭性的特点，故股东相互间又具有人身信任因素，具有人合的色彩，这就决定了此种公司一般是适合于中小企业的组织形式。

3. 有限责任公司与股份有限公司的设立条件有何不同？

【答案】（1）有限责任公司设立的条件包括：

- ①股东符合法定人数，即50人以下。
- ②有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额。
- ③股东共同制定公司章程。
- ④有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构。
- ⑤有公司住所。

（2）股份有限公司设立的条件包括：

- ①发起人符合法定人数。
- ②有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或募集的实收股本总额。
- ③股份发行、筹办事项符合法律规定。
- ④发起人制定公司章程，采用募集方式设立的并经创立大会通过。
- ⑤有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。
- ⑥有公司住所。

(3) 二者的主要区别在于设立人和注册资本不同。

①有限责任公司由50个以下股东共同设立，而股份有限公司的设立则有赖于适格的发起人的行为。发起人符合法定人数是我国设立股份有限公司的必备重要条件之一、一般应有2人以上200人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

②股份有限公司为自身运营的需要和保护公司债权者的权益，要有相当规模的注册资本作为基础。

4. 简述公司法人格否认制度的一般适用情形。

【答案】公司法人格否认制度的一般适用情形如下：

(1) 公司资本显著不足

公司资本显著不足，是指公司资本不符合公司经营事业、规模或经营风险的最低要求，呈现出显著不足的状态。因各国实行不同的公司资本制度，注册资本的含义不尽相同，故不能简单地将公司注册资本视为公司资本是否充足的判断标准，而应以发行资本作为判断标准。

(2) 利用公司独立人格逃避合同义务

①为回避契约上特定的不作为义务（如竞业禁止），而设立新公司或利用其原有的公司，假借公司名义而掩盖其真实行为。

②“脱壳经营”，即控股股东为逃避原公司巨额债务而抽逃资金或解散该公司或宣告该公司破产，再以原设备、场所、人员及相同经营目的而另设一公司的行为。

③当事人利用公司名义转移财产进行诈欺以逃避合同义务的行为。

(3) 滥用公司法人格规避法律义务或骗取非法利益的行为

这一情形是指股东利用新设立公司或既存公司的独立人格，人为改变了强制性法律规范适用的前提，从而达到规避法律义务之目的的行为。就我国而言，实际上，为凑足股东人数，虚拟股东或虚拟出资，以独资、合资、合作为名，骗取国家关于外商投资企业的优惠政策的情形，虽然实践中未依公司法人格否认制度处理，但亦属此例。

(4) 公司与股东人格混同

公司与股东人格混同，常常构成公司法人格否认的依据。这在一人公司和母子公司中表现得尤为明显，其基本表征如下：

①财产混同

这是对公司与股东财产分离原则的背离，将导致公司财产的不独立。一方面表现在公司财产与股东财产在实际经营上的混同，无法严

格区分；另一方面表现在公司与股东或一公司与他公司利益一体化上。如子公司以一种“不公平的方式”运作，使母子公司之间的交易利润积累于母公司而损失留存于子公司。

②业务混同

一公司完全以另一公司或股东的利益需要为准而进行交易活动，使交易方无法分清是该公司还是其股东及其他公司的交易行为，使公司形式上的独立性都无法获得保证。

③组织机构混同

公司组织机构包括公司的意思机关、执行机关及监督机关，组织机构的混同势必导致公司独立意思无法形成，从而丧失了公司的本质性法律人格要素。

综上所述，公司法人格否认制度是对公司独立人格制度和股东的有限责任制度的重要补充。然而，法官的自由裁量权只能是相对的，只能是在维护公平、正义理念，遵守法的一般原则，运用合法程序，并针对法律司法解释尚未明确的事项下行使的最大的自由，不能滥用，必须按照法律规定适用。

5. 简述有限责任公司股权转让的方式与限制。

【答案】股权转让的方式及限制主要体现在以下方面：

（1）股东之间的股权转让

因其属于内部转让，仅对公司内部股东之股权结构产生影响，故各国（地区）公司法都不予限制。股东之间可以自由转让其全部出资或部分出资，即股东之间的转让不受限制，也无须股东会表决通过。但国有股必须控股或相对控股领域的有限责任公司，股东之间的股权转让不能使国有股丧失控股或相对控股的地位，若依公司具体情况确需非国有资本控股，则须报国家有关部门审批。

（2）股东向股东以外的人转让股权

有限责任公司虽然在本质上属于资合性公司，但又兼具人合性特点，一般股东人数较少，股东之间的人身信用程度较高，股东内部关系的稳定对公司有至关重要的意义。因此，为了保证有限责任公司的内部稳定，绝大多数国家（地区）的公司法都对股东向股东以外的人转让股权作了严格限制。

我国《公司法》第71条第1款规定：“股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东

应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。”

（3）股东优先购买权的行使

我国《公司法》第71条第2款规定：“经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”该规定从有限责任公司的人合性出发，为维护公司内部信用联系，明确规定了股东优先购买权。这里主要涉及三个方面的问题：

①只有当某个股东要将其出资转让给股东以外的人时，其他股东才有这种优先权，如果只是股东之间的内部转让，则不存在优先购买权的问题。

②这种优先权只能是同等条件下的优先权，如果转让给股东以外的人的条件优于本公司的股东，则本公司股东不得以行使优先权为由要求转让给自己。

③两个以上股东主张行使优先购买权的，相互协商不成的，应按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

6. 简述股东代表诉讼的特殊程序。

【答案】股东代表诉讼的特殊程序主要包括四种程序：

（1）股东代表诉讼的前置程序

即股东在起诉前首先应向公司董事会或监事会以公司名义对侵害人提起诉讼，只有在遭受拒绝后方可向法院提起代表诉讼。此程序的主要原因在于该诉权原本属于公司，自然应首先提请公司行使，只有在公司拒绝股东的请求后才能发动股东代表诉讼。但情况紧急，发动期限届满将导致公司利益遭受无法挽回的损害的可直接提请股东代表诉讼。我国《公司法》第151条分三款对股东代表诉讼的条件与前置程序作了明确规定。

（2）股东代表诉讼的管辖

各国（地区）公司法作为实体法，大多不对股东代表诉讼的管辖作明确规定，而将其作为程序法问题处理。我国《公司法》基于实体法中不就诉讼管辖这一程序问题作出规定的立法惯例，未对股东代表诉讼的管辖作明确规定。

（3）诉讼费用担保制度

诉讼费用担保制度，是法院认定原告股东提起股东代表诉讼缺乏合理理由时，法院可责令原告股东向被告提供一定的担保，以便在原告股东败诉时，对被告承担的合理诉讼费用给予补偿。我国现行《公

司法》在导入股东代表诉讼制度时，未明确规定诉讼费用担保制度。

（4）对原告股东诉讼权利的限制

美、日、韩等国公司法均对原告股东处分权的限制作了不同程度的规定。我国《公司法》及我国台湾地区“公司法”均未对股东代表诉讼中原告股东的处分权作明确规定。关于对原告股东处分权的限制，法院不能按照有利于公司利益的原则进行自由裁量。

六、论述题

1. 简述现代企业制度的特点和内容。

【答案】现代企业制度的特点和内容具体如下：

（1）产权清晰

所谓“产权清晰”，主要有两层含义：

①有具体的部门和机构代表国家对某些国有资产行使占有、使用、处置和收益等权利。

②国有资产的边界要“清晰”，即通常所说的“摸清家底”。首先要搞清实物形态国有资产的边界；其次要搞清国有资产的价值和权利边界，包括实物资产和金融资产的价值量，国有资产的权利形态，总资产减去债务后净资产数量等。

（2）权责明确

“权责明确”是指合理区分和确定企业所有者、经营者和劳动者各自的权利和责任。

权利所有者按其出资额，享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利，企业破产时则对企业债务承担相应的有限责任。企业在其存续期间，对由各个投资者投资形成的企业法人财产拥有占有、使用、处置和收益的权利，并以企业全部法人财产对其债务承担责任。经营者受所有者的委托在一定时期和范围内拥有经营企业资产及其他生产要素并获取相应收益的权利。劳动者按照与企业的合约拥有就业和获取相应收益的权利。责任：包含了通常所说的承担风险的内容。要做到“权责明确”，除明确界定所有者、经营者、劳动者及其他企业利益相关者各自的权利和责任外，还必须使权利和责任相对应或相平衡。此外，在所有者、经营者、劳动者及其他利益相关者之间，应当建立起相互依赖又相互制衡的机制，这是因为他们之间是不同的利益主体，既有共同利益的一面，也有不同乃至冲突的一面。相互制衡就要求明确彼此的权利、责任和义务，要求相互监督。

（3）政企分开

“政企分开”的基本含义是政府行政管理职能、宏观和行业管理职能与企业经营职能分开。

①政企分开要求政府将原来与政府职能合一的企业经营职能分开后还给企业，改革以来进行的“放权让利”“扩大企业自主权”等就是为了解决这个问题。

②政企分开还要求企业将原来承担的社会职能分离后交还给政府和社会。问题的关键还在于政府如何才能正确地行使而不是滥用其拥有的所有权。

(4) 管理科学

“管理科学”包括了企业组织合理化的含义：从较窄的意义上说，“管理科学”要求企业管理的各个方面，如质量管理、生产管理、供应管理、销售管理、研究开发管理、人事管理等方面的科学化。管理致力于调动人的积极性、创造性，其核心是激励、约束机制。

根据以上分析，在较为具体的层面，现代企业制度大体可包括以下内容：

①企业资产具有明确的实物边界和价值边界，具有确定的政府机构代表国家行使所有者职能，切实承担起相应的出资者责任。

②企业通常实行公司制度，即有限责任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股东代表大会、董事会、监事会和高级经理人员组成的相互依赖又相互制衡的公司治理结构，并有效运转。

③企业以生产经营为主要职能，有明确的盈利目标，各级管理人员和一般职工按经营业绩和劳动贡献获取收益，住房分配、养老、医疗及其他福利事业由市场、社会或政府机构承担。

④企业具有合理的组织结构，在生产、供销、财务、研究开发、质量控制、劳动人事等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。

⑤企业有着刚性的预算约束和合理的财务结构，可以通过收购、兼并、联合等方式谋求企业的扩展，经营不善难以为继时，可通过破产、被兼并等方式寻求资产和其他生产要素的再配置。

2. 试析我国《公司法》关于一人有限责任公司的规定。

【答案】一人有限责任公司，又称独资公司或独股公司，有狭义和广义之分。狭义的一人公司指股东只有一人，全部股份或出资由一人拥有的公司，又称形式意义上的一人公司；广义的一人公司，不仅包括形式意义上的一人公司，还包括实质意义上的一人公司，即公司的真

实股东只有一人，其余股东仅是为了真实股东一人的利益而持有股份的非实有股份权益者的公司。

现行《公司法》以第二章第三节共计7个条文（第57～63条）的篇幅就一人有限责任公司作了特别规定，从而使一人公司得到了部分承认。其基本内容如下：

（1）我国《公司法》所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。其具体规范除由《公司法》作特别规定者外，皆适用《公司法》的相关规定。

（2）为提高一人有限责任公司的信用能力，法律规定其注册资本最低限额为人民币10万元，并且股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。对此，也有学者认为，该最低限额规定过高，应将其降为3万元。

（3）为避免自然人滥用一人有限责任公司的法律人格，《公司法》规定一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司，并且该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。

（4）在公司治理结构方面，一人有限责任公司不设股东会。股东作出应由股东会决议事项的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

（5）一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。此即一人有限公司的强制审计制度。通过强制审计制度，一人有限责任公司被赋予了高于其他有限责任公司的信息披露义务，从而有利于维护债权人及交易相对人的利益。

（6）一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的；应当对公司债务承担连带责任。此即一人有限责任公司法人人格滥用推定制度。该规定的实质在于确立了一人有限责任公司法人人格滥用的举证责任倒置制度。有学者对该规定给予了高度评价，认为其作为我国的制度创新，不仅是我国一人公司制度走在世界前沿的标志，也是我国对公司法人格否认制度的一大创新。

3. 试述公司人格否认制度。

【答案】（1）公司人格独立的价值分析

现代意义的公司始于19世纪末20世纪初，其标志就是公司独立人格的确立。公司作为法人，其独立人格不仅表现为公司人格与股东人格相互独立，而且表现为公司财产与股东财产的分离，由此形成归公司独立拥有和支配的财产。同时，公司股东放弃对其出资的直接支配

权，换取仅以其出资为限对公司债务负责的有限责任特权。当公司股东严格遵守分离原则时，公司制度就建立起以公司为中心的公司股东与公司债权人群体两极利益平衡体系，即一方面股东为获得债权人的信任，以承认公司对其出资享有法人财产权和放弃对其出资的直接支配权为代价，享有只对公司承担出资义务的有限责任，实现了其投资风险最小化和利润最大化的目的；另一方面债权人虽不能直接追究股东的民事责任，但却获得了股东对其出资直接支配权的放弃，并因与公司组织集中进行经济交往而节省了大量的交易费用。

（2）公司人格否认制度的理论

公司人格否认制度也称“揭开公司面纱”，是指在承认公司具有法人人格的前提下，对特定法律关系中的公司人格加以否认，直接追索公司股东的责任，规制滥用公司人格的行为，以实现公司人格独立价值目标的一种法律制度。由于它是针对那些滥用公司人格的行为设定的，一经产生很快就为西方发达国家所效法并在实践中进行了发展和创新。

（3）公司人格否认在我国的法律实践

《全国法院民商事审判工作会议纪要》强调指出：在审判实践中，要准确把握《公司法》第20条第3款规定的精神。

①只有在股东实施了滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为，且该行为严重损害了公司债权人利益的情况下，才能适用。损害债权人利益，主要是指股东滥用权利使公司财产不足以清偿公司债权人的债权。

②只有实施了滥用法人独立地位和股东有限责任行为的股东才对公司债务承担连带清偿责任，而其他股东不应承担此责任。

③公司人格否认不是全面、彻底、永久地否定公司的法人资格，而只是在具体案件中依据特定的法律事实、法律关系，突破股东对公司债务不承担责任的一般规则，例外地判令其承担连带责任。人民法院在个案中否认公司人格的判决，其既判力仅仅约束该诉讼的各方当事人，不当然适用于涉及该公司的其他诉讼，不影响公司独立法人资格的存续。如果其他债权人提起公司人格否认诉讼，已生效判决认定的事实可以作为证据使用。

④《公司法》第20条第3款规定的滥用行为，实践中常见的情形有人格混同、过度支配与控制、资本显著不足等。在审理案件时，需要根据查明的案件事实进行综合判断，既审慎适用，又当用则用。实践中存在标准把握不严而滥用这一例外制度的现象，同时也存在因法律规定较为原则、抽象，适用难度大，而不善于适用、不敢于适用的现象，均应引起高度重视。

（4）公司人格否认原则的适用条件

①公司须合法有效成立

未取得法人资格，法人资格被消灭，或独立人格存在其他无效事由，都有特定的救济方法，不能适用该原则。

②股东在客观上存在着滥用公司法人人格和股东有限责任的行为

这些行为的主要表现包括：a. 人格混同，即该公司与他公司之间没有严格的区别，在实践中的表现有，一人组成数个公司所引起的人格混同，相互投资所引起的人格混同等；b. 财产混合，即公司的盈利与股东的收益之间已无区别，《公司法》第63条规定的情形即为典型；c. 虚拟股东，虚拟的目的是规避法律和逃避债务；d. 不正当控制，表现为母公司对子公司实施了过度控制，母公司完全操纵了子公司的决策过程，使被操纵的子公司完全丧失了独立性，完全成了母公司的工具。e. “改变自我”亦可成为适用公司人格否认的行为。所谓改变自我，是指在母子公司之间存在着所有权利益的一体化，致使子公司改变了自我，它就不再是一个独立的公司。

③股东滥用公司人格和有限责任的行为严重侵害了债权人的利益

这一要件是强调滥用行为应与损害结果之间具有因果关系，且应为“严重损害公司债权人利益的”。

综上所述，公司人格否认不仅包含着我国建立现代企业制度的目标追求，而且还蕴含着对债权人利益及交易安全的价值判断，但是无论公司人格否认原则如何重要，它只能是公司人格独立原则的补充。在司法实践中一定要慎用公司人格否认原则，决不能本末倒置，导致对法人制度的破坏。

4. 试述《公司法》设立的股东诉讼制度。

【答案】《公司法》设立的股东诉讼制度可从以下几方面分析：

（1）股东诉讼的概念与种类

股东诉讼，是指由股东提起的诉讼。股东诉讼的种类包括：

①直接诉讼，指股东在作为公司成员在公司成立时就享有的股东本身的个体权利受到侵害时所提起的一种诉讼。

②派生诉讼，又称传来诉讼、代位诉讼，是指在公司经营过程中当董事、监事、高级管理人员执行公务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，而公司董事会、监事会或股东大会对此不提起诉讼，由公司一个或多个股东代表公司对违法、加害的董事、监事或公司高级管理人员提起的诉讼。

③直接诉讼与派生诉讼的区别：

a. 被侵害的权利性质不同。直接诉讼侵害的权利属于股东自身的个体性权利；而派生诉讼被侵害的权利则属于公司的团体性权利。

b. 提起诉讼的权利主体不同。直接诉讼可由股东个人以自己的名义提起，是一种单独股东权；而派生诉讼本应由公司提起，只是由于存在法定的特殊原因，才由符合法定条件的股东代为行使。

c. 诉讼的目的不同。直接诉讼的目的是股东个人的利益，胜诉所获得的利益归属于股东个人；而派生诉讼事实上是股东为公司的利益进行诉讼，诉讼的利益归于公司而不是股东个人。

（2）股东诉讼制度的作用

①赋予股东诉权有利于切实维护股东权益。

②赋予股东诉权有利于强化公司的治理结构。

（3）股东诉讼的依据与条件

①股东诉讼的法律依据

《公司法》涉及股东诉讼的主要是第21条、第22条、第150条、第152条、第153条、第183条等规定，这些规定是股东提起直接诉讼和派生诉讼的重要法律依据。

②股东派生诉讼的要件

a. 股东派生诉讼的程序要件

根据《公司法》第151条的规定，穷尽内部救济手段是股东提起派生诉讼的前置程序要件。股东在提起诉讼前，首先应当书面请求董事会或执行董事、监事会或监事提起诉讼，只有在这些机构拒绝起诉或超过法定期限未起诉时，股东方可行使派生诉权，这是股东提起派生诉讼的一般程序。当情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害时，股东可不受前置程序条件的约束，直接提起诉讼。

b. 股东派生诉讼的主体要件

第一，原告。有限责任公司的所有股东都可以充任股东派生诉讼的原告。股份有限公司的股东担任股东派生诉讼的原告须同时具备两个条件：一是须连续180日以上持有公司的股份；二是须单独或者合计持有公司1%以上的股份。

第二，公司。股东派生诉讼是股东为了公司利益提起的诉讼，公司可以作为第三人参与到公司诉讼中。在派生诉讼中，应当将公司列为无独立请求权的第三人。

第三，被告。在派生诉讼中，被告是侵害公司合法权益并给公司造成损害的董事、监事、高级管理人员及他人，“他人”应包括控股股东、实际控制人及交易相对人等。

（4）股东派生诉讼的结果归属

①原告胜诉的结果归属

原则上应由被告直接向公司承担损害赔偿责任；胜诉股东可以要求公司为其补偿合理支出的费用。

②原告败诉的结果归属

原告的诉讼费用应当自理；还要补偿被告因应诉所支出的合理费用。

③和解撤诉的结果归属

在和解撤诉的场合，因和解协议可能影响到全体股东，因此要求和解协议的内容必须向全体股东公开，并须经法官批准。

七、案例分析题

1. 甲、乙、丙三家公司是A有限责任公司的股东，分别持有A公司25%、30%和45%的股权。现在，甲公司和丙公司拟将其持有的15%和25%的A公司股权转让给丁公司。假如你是丁公司聘请的法律顾问，请你就该股权转让中应该注意的法律问题为丁公司提供法律意见的要点。

【答案】针对该股权转让中应注意的法律问题为丁公司提供法律意见如下：

（1）公司股东向股东以外的人转让股权的实质条件

根据《公司法》第72条，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。这是股权转让生效的实质要件。甲和丙公司向丁公司转让股权，应当经其他股东过半数同意。换言之，甲向外转让股权，应当经乙或丙至少一人同意，同理，丙向丁转让股权应当经甲或乙至少一人同意。

（2）转让股东向其他股东通知的义务

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。甲或乙公司都应当履行通知义务，并且只有在其他股东30日内未答复的情况下才能转让股权，否则股权转让不发生效力。

（3）其他股东享有优先购买权

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。即股东同意转让股权的情况下，其他股东仍然享有在同等条件下，优先购买该股权的权利。如果其他股东愿意出同样的价格，那么

丁公司将无法取得股权。

（4）股权的变更要求

根据《公司法》第74条的规定，依照本法第72条、第73条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。在丁公司取得股权以后，可以要求公司签发出资证明书并修改公司章程，以及配合自己办理股权变更登记。

2. 1995年2月，吴某与个体工商户A、B共同设立某服装有限责任公司（以下简称服装公司），吴某拥有公司的大部分股权，并被选聘为公司执行董事兼经理。1996年7月，服装公司先后与凯丰服装厂签订了两份皮衣和西服购销合同。合同约定：凯丰服装厂向服装公司供应某品牌皮衣120件、西服40套，共计价款9.9万元。同年9月，凯丰服装厂按约将皮衣和西服运送至服装公司仓库。10月20日，服装公司因经营状况不佳，资金紧张，与吴某达成协议，向其借款10万元人民币。服装公司因主客观等多方面的因素，经营状况不好，在与凯丰服装厂订立皮衣、西服购销合同前已拖欠多笔债务未还。并且，也有多个债务人拖欠其钱款未还。至1997年5月11日，服装公司虽经多方筹措，只能偿付凯丰服装厂4万元货款。

鉴于经营状况不景气，同年6月，服装公司召开股东会，作出解散公司的决议。随即公司股东组成清算组，对公司财产进行清理，并公告债权人。在清理债权债务时，吴某主张，自己作为公司的债权人，有权要求公司偿还欠款10万元。但凯丰服装厂和公司其他债权人主张，吴某是公司股东，无权作为债权人要求公司偿还其借款。公司财产只能用于清偿其他债权人的债务。且如公司财产不足以清偿债务，吴某还应以其个人财产负清偿责任。故凯丰服装厂联合其他公司债权人，以吴某和服装公司为被告诉至法院，要求吴某和服装公司共同承担赔偿责任。

问：

（1）凯丰服装厂和其他债权人能否要求吴某以个人财产对服装公司的债务承担赔偿责任？

（2）吴某和服装公司之间是什么关系？他是否有权要求公司偿还其借款？

【答案】（1）凯丰服装厂和其他债权人不能要求吴某以个人财产对服装公司的债务承担赔偿责任。因为，服装公司是依法成立的法人，应

以其全部财产对外独立承担民事责任，这是公司法人独立性的集中表现。公司财产最初源自股东投资，但在法律上，股东与公司具有相互独立的人格，股东未投入公司的财产，一般不能强迫用于清偿公司债务。按照公司法的规定，有限责任公司的股东仅以其出资额为限对公司承担法律责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任，因此，公司清偿债务人的债务只以其全部资产为限，当公司的全部资产不足以清偿其债务时，其股东没有义务以其个人资产为公司清偿债务。总之，在本案中，并无否定服装公司法人格而令吴某承担直接清偿责任的根据，因此，吴某作为公司股东，无须以个人财产对公司债务负清偿责任。

(2) 吴某和服装公司之间具有双重身份：一为基于对公司的投资而取得的股东身份；二为公司向其借款而取得的债权人身份。吴某作为公司股东，其投入公司的出资额，属于公司财产，不能抽回，只有在公司解散清偿债务后，就公司剩余财产按出资比例受偿。但是，吴某同时又是服装公司的债权人，其借给公司的钱属于自己的个人财产，公司成立后就作为独立的法人与其股东的财产分离，和其股东之间是相互独立的法律主体，即使公司向其股东借钱，也应偿还。故吴某有权要求公司偿还其借款，不能将吴某的股东身份与其债权人身份混淆。

3. 中万股份有限公司（以下简称中万公司）由于市场情况发生重大变化，经股东大会决议解散公司。股东大会选任公司董事甲、乙、丙、丁、戊五人组成了清算组。清算组组成后10日内将公司解散事项分别通知了公司债权人并在报纸上进行了公告，规定对自公告之日起3个月内未向公司申报债权人，将不负清偿责任。晨光公司是中万公司多年的贸易伙伴，中万公司决定解散而开始清算时，尚欠晨光公司货款58万元，但合同约定的付款期限6个月后才到期。此外，双方还有一份合同未履行完毕。依该合同，中万公司还应向晨光公司提供机械产品10台，该项合同义务已到履行期限，计价款28万元。晨光公司在中万公司通知的期限内向中万公司申报了债权，同时提出解除合同未履行部分，余下10台机械不再发货。理由是中万公司已解散，在法律上已丧失履约主体资格。

中万公司清算组成员对如何处理与晨光公司的债权债务，发生了分歧。甲、乙主张：10台机械应依约发送给晨光公司，同时要求对方支付价款。至于中万公司所欠58万元货款。虽尚未到期，但由于公司已解散清算，为使晨光公司利益免受损失，也应进行清偿。故所欠58万元扣除10台机械应收款28万元，应向晨光公司清偿债务总额为30万

元；丙、丁、戊则主张：晨光公司拒绝我方履行合同，已违约在先，又因欠其货款6个月后才到偿还期，故中万公司无义务提前清偿。根据多数人意见，清算组决定将10台机械装车发货，未到期货款不列入清算方案中清偿。4个月后，中万公司清算终结，办理了公司注销登记，法人终止。晨光公司虽接受了中万公司10台机械，但仍有30万元债权无法得到清偿，遂以清算组全体成员为被告向人民法院提起诉讼，要求赔偿损失。

问：

(1) 中万公司股东大会决议解散公司是否合法？为什么？

(2) 中万公司股东大会委任5名董事组成清算组是否合法？为什么？

(3) 中万公司与晨光公司之间的机械供应合同未履行部分是否可以由晨光公司单方解除？为什么？

(4) 中万公司所欠晨光公司的货款是否可以列入清偿范围？为什么？

(5) 晨光公司的30万元损失应由谁来承担？为什么？

【答案】 (1) 中万公司股东大会决议解散公司是合法的。

根据现行《公司法》的规定，由公司的权力机构进行解散是公司解散的原因之一。

(2) 中万公司股东大会委任5名董事组成清算组合法。

根据《公司法》第184条的规定，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。该案中的5名董事是由股东大会委任的，是合法的。

(3) 中万公司与晨光公司之间的机械供应合同未履行部分不可以由晨光公司单方解除。

公司解散后至办理注销登记之前，公司虽解散，但在清算目的范围内，法人资格继续存在，由清算组处理与清算有关的公司未了结的业务。公司解散时，尚未了结的业务，如尚未履行完毕的合同，清算组必须代表公司为之了结。

(4) 中万公司所欠晨光公司的货款可以作为普通的债权列入清偿范围。

(5) 晨光公司的30万元损失应当由中万公司的财产进行清偿，但是必须以普通债权的名义申报破产清算财产的债权。

第五章 非公司企业法

一、单项选择题

1. 甲、乙、丙共同成立了某普通合伙企业，2017年甲向丁借款100万元，到期无法清偿。甲拟以其持有的合伙企业份额对丁进行清偿，其他合伙人均不同意。下列选项说法正确的是？（ ）

- A. 可以合伙企业盈利对丁进行清偿
- B. 若丁向法院申请强制执行甲的合伙份额，应经其他合伙人一致同意
- C. 为了避免债权人强制执行甲的合伙份额，其他合伙人协商代为清偿
- D. 若丁向法院申请强制执行甲的合伙份额，其他合伙人不行使优先购买权，也不同意对外转让份额的，则视为其他合伙人同意对外转让

【答案】C

【解析】A项，《合伙企业法》第42条第1款规定，合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。本题中，甲向丁借款100万元，属于甲的个人债务，与合伙企业无关，应当先用甲的自有财产来清偿，当甲的自有财产无法清偿其个人负债的，可以根据本款的规定进行清偿。合伙企业的盈利属于全体合伙人的共同利益，不可以用来清偿个别合伙人的个人负债。

BD两项，《合伙企业法》第42条第2款规定，人民法院强制执行合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人，其他合伙人有优先购买权；其他合伙人未购买，又不同意将该财产份额转让给他人，依法为该合伙人办理退伙结算，或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。

C项，合伙企业具有较强的人合性的特点，其他合伙人基于意思自治，在征得债权人丁的同意之后，自愿代为清偿，合法又合理。

2. 逐道茶业是一家生产销售野生茶叶的普通合伙企业，合伙人分别为赵、钱、孙。合伙协议约定如下：第一，赵、钱共同担任合伙事务执行人；第二，赵、钱共同以合伙企业名义对外签约时，单笔标的额不得超过30万元。对此，下列哪一选项是正确的？（ ）

A. 赵单独以合伙企业名义，与甲茶农达成协议，以12万元的价格收购其茶园的茶叶，该协议为有效约定

B. 孙单独以合伙企业名义，与乙茶农达成协议，以10万元的价格收购其茶园的茶叶，该协议为无效约定

C. 赵、钱共同以合伙企业名义，与丙茶叶公司签订价值28万元的明前茶销售合同，该合同为有效约定

D. 赵、钱共同以合伙企业名义，与丁茶叶公司签订价值35万元的明前茶销售合同，该合同为无效约定

【答案】C

【解析】《合伙企业法》第37条规定，合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。据此可知，当合伙人违反合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，而对外订立合同时，不能当然地认定该合同有效或无效，还要结合相对人是否为善意来加以判断。

A项，赵单独以合伙企业名义对外签约，违反了合伙协议约定，若甲茶农知情，则甲不是善意第三人，此时构成无权代理，该协议效力待定。

B项，孙不是合伙事务执行人，不能对外签约，但同样不能对抗善意第三人。

C项，赵、钱共同以合伙企业名义，与丙茶叶公司签订价值28万元的明前茶销售合同符合合伙协议约定，合同有效。

D项，赵、钱对外签约的金额超过30万，如果相对人善意，则合同有效。

3. “李老汉私房菜”是李甲投资开设的个人独资企业。关于该企业遇到的法律问题，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 如李甲在申请企业设立登记时，明确表示以其家庭共有财产作为出资，则该企业是以家庭成员为全体合伙人的普通合伙企业
- B. 如李甲一直让其子李乙负责企业的事务管理，则应认定为以家庭共有财产作为企业的出资
- C. 如李甲决定解散企业，则在解散后5年内，李甲对企业存续期间的债务，仍应承担偿还责任
- D. 如李甲死后该企业由其子李乙与其女李丙共同继承，则该企业必须分立为两家个人独资企业

【答案】C

【解析】A项，《个人独资企业法》第18条规定，个人独资企业投资人在申请企业设立登记时明确以其家庭共有财产作为个人出资的，应当依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任。据此可知，个人独资企业设立时可以家庭共有财产作为个人出资，其性质仍为个人独资企业。

B项，《个人独资企业法》第19条第1款规定，个人独资企业投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。据此，李甲可以委托他人（包括自己的儿子李乙）管理个人独资企业事务，不能因此认定李甲是以家庭共有财产出资。

C项，《个人独资企业法》第28条规定，个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在5年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭。据此，个人独资企业出资人对企业债务承担无限责任的期限为企业依法解散后5年内。

D项，个人独资企业的投资人只能是一个自然人，因继承使得不满足个人独资企业设立条件的，可以申请变更为其他企业形式，并非必须分立为两家个人独资企业。

4. 甲企业是由自然人安琚与乙企业（个人独资）各出资50%设立的普通合伙企业，欠丙企业货款50万元，由于经营不善，甲企业全部资产仅剩20万元。现所欠货款到期，相关各方因货款清偿发生纠纷。对此，下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 丙企业只能要求安琚与乙企业各自承担15万元的清偿责任

- B. 丙企业只能要求甲企业承担清偿责任
- C. 欠款应先以甲企业的财产偿还，不足部分由安琚与乙企业承担无限连带责任
- D. 就乙企业对丙企业的应偿债务，乙企业投资人不承担责任

【答案】C

【解析】

《合伙企业法》第38条规定，合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。第39条规定，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。在合伙企业中，除法律另有规定外，普通合伙人须对合伙企业的债务负无限连带责任。当合伙企业财产不足以清偿时，普通合伙人要以自己的全部财产清偿。本题中，普通合伙企业甲对外欠债50万元，但合伙企业全部资产仅剩20万元，欠款应先以甲企业的财产偿还，不足部分应由合伙人安琚与乙企业承担无限连带责任。

5. 某普通合伙企业为内部管理与拓展市场的需要，决定聘请陈东为企业经营管理人。对此，下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 陈东可以同时具有合伙人身份
- B. 对陈东的聘任须经全体合伙人的一致同意
- C. 陈东作为经营管理人，有权以合伙企业的名义对外签订合同
- D. 合伙企业对陈东对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗第三人

【答案】B

【解析】AB两项，《合伙企业法》第31条第6项规定，除合伙协议另有约定外，合伙企业聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员，应当经全体合伙人一致同意。根据题干信息，应该确定陈东是合伙人以外的人。担任经营管理人并不当然取得合伙人身份，且对陈东的聘任须经全体合伙人的一致同意。

C项，《合伙企业法》第35条第1款规定，被聘任的合伙企业的经营管理人员应当在合伙企业授权范围内履行职务。本题中，虽然陈东

被聘任为经营管理人，从事内部管理、拓展市场，但应当是在“合伙企业授权范围内”有权以合伙企业的名义对外签订合同。该选项的表述不完整，会让人误以为陈东只要被聘任为经营管理人，不用授权就可以对外签订合同。

D项，首先，经营管理人只有在经过合伙企业授权之后，才有权在授权范围内对外“代理”合伙企业，陈某若无对外代表合伙企业的权利，则当然不存在对该权利进行内部限制的问题；其次，根据《合伙企业法》第37条的规定，合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。陈某若获得对外代表合伙企业的授权，则合伙企业对其行使该权利的限制不能对抗的是善意第三人，而非任意第三人。

6. 李军退休后于2014年3月，以20万元加入某有限合伙企业，成为有限合伙人。后该企业的另一名有限合伙人退出，李军便成为唯一的有限合伙人。2014年6月，李军不幸发生车祸，虽经抢救保住性命，但已成为植物人。对此，下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 就李军入伙前该合伙企业的债务，李军仅需以20万元为限承担责任
- B. 如李军因负债累累而丧失偿债能力，该合伙企业有权要求其退伙
- C. 因李军已成为植物人，故该合伙企业有权要求其退伙
- D. 因唯一的有限合伙人已成为植物人，故该有限合伙企业应转为普通合伙企业

【答案】A

【解析】A项，《合伙企业法》第77条规定，新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。李军以20万元加入某有限合伙企业，成为有限合伙人，仅以20万元为限承担有限责任。

B项，根据《合伙企业法》第78条和第48条的规定，有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；②作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；③合伙人在合伙企业中的全

部财产份额被人民法院强制执行。据此，丧失偿债能力并非有限合伙人的退伙原因，有限合伙人只以认缴的出资额为限承担责任，丧失清偿能力不影响有限合伙人承担相应责任。

C项，《合伙企业法》第79条规定，作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。因为有限合伙人~~不执行~~合伙事务，也不得对外代表有限合伙企业，不需要具有行为能力。故不能因为李军成为植物人而要求其退伙。

D项，《合伙企业法》第75条规定，有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散；有限合伙企业仅剩普通合伙人的，转为普通合伙企业。因为李军丧失行为能力并未影响其有限合伙人资格，不会影响有限合伙企业的存续。

7. 2007年1月，甲、乙、丙设立一普通合伙企业。2008年2月，甲与戊结婚。2008年7月，甲因车祸去世。甲除戊外没有其他亲人，合伙协议对合伙人资格取得或丧失未作约定。下列哪一选项是正确的？
()

- A. 合伙企业中甲的财产份额属于夫妻共同财产
- B. 戊依法自动取得合伙人地位
- C. 经乙、丙一致同意，戊取得合伙人资格
- D. 只能由合伙企业向戊退还甲在合伙企业中的财产份额

【答案】C

【解析】A项，本题中，甲在婚前与他人设立合伙企业，其财产份额应为甲的个人财产，在甲去世后作为遗产依继承处理。

BCD三项，《合伙企业法》第50条第1款规定，合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。甲死亡后，戊是甲的唯一继承人，且合伙协议对合伙人资格取得或丧失没有约定，因此经乙、丙同意，戊可取得合伙人资格。

8. 甲乙丙丁4人组成一个运输有限合伙企业，合伙协议规定甲、乙为普通合伙人，丙、丁为有限合伙人。某日，丁为合伙企业运送石材，路遇法院拍卖房屋，丁想替合伙企业竞买该房，于是以合伙企业的名义将石材质押给徐某，借得20万元，竞买了房子。徐某的债权若得不到实现，应当向谁主张权利？（ ）

- A. 应当要求丁承担清偿责任
- B. 应当要求甲、乙、丙、丁承担连带清偿责任
- C. 应当要求甲、乙承担连带清偿责任
- D. 应当要求甲、乙、丁承担连带清偿责任

【答案】D

【解析】

《合伙企业法》第2条第3款规定，有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。第68条第1款规定，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。第76条第1款规定，第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。本题中，甲、乙作为普通合伙人对合伙企业债务承担连带无限责任，丁作为有限合伙人为合伙企业运送石材，以合伙企业的名义与徐某进行交易，徐某有理由相信丁为普通合伙人。对于徐某的债权，丁与甲乙一起承担连带无限责任，丙为有限合伙人，仅以出资额为限对此承担有限责任。

9. 张某打算自己投资设立一企业从事商贸业务。下列哪一选项是错误的？（ ）

- A. 张某可以设立一个一人有限责任公司从事商贸业务
- B. 张某可以设立一个个人独资企业从事商贸业务
- C. 如果张某设立个人独资企业，则该企业不能再入伙普通合伙企业

D. 如果张某设立一人有限责任公司，则该公司可以再入伙普通合伙企业

【答案】C

【解析】A项，《公司法》第57条第2款规定，本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。张某作为一个自然人有权设立一人有限责任公司。

B项，《个人独资企业法》第2条规定，本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。张某作为一个自然人有权设立个人独资企业。

C项，《合伙企业法》第2条第1款规定，本法所称合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照本法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。由此可见，法律并未禁止个人独资企业成为普通合伙人。

D项，《合伙企业法》第2条第2款规定，普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。《公司法》第15条规定，公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。因此，一人公司不能成为普通合伙人，即一人公司不可以再入普通合伙企业或作为普通合伙人入有限合伙企业。

10. 关于商事组织出资人财产份额转让，下列说法错误的是（ ）。

A. 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业的份额时，应当通知其他合伙人，其他合伙人在同等条件下享有优先购买权

B. 有限合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业的份额时，应当通知其他合伙人，但其他合伙人无优先购买权

C. 有限责任公司作为普通合伙人，向合伙人以外的人转让其合伙份额时，应当经过公司股东会的同意

D. 如果合伙人的财产被法院强制执行，普通合伙企业的其他合伙人既不同意将该财产份额转让给他人，又不购买的，则该被执行人只能退伙

【答案】C

【解析】A项，《合伙企业法》第23条规定，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是，合伙协议另有约定的除外。

B项，《合伙企业法》第73条规定，有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前30日通知其他合伙人。

C项，《合伙企业法》第22条规定，除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。未规定须经股东会同意。

D项，《合伙企业法》第42条第2款规定，人民法院强制执行合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人，其他合伙人有优先购买权；其他合伙人未购买，又不同意将该财产份额转让给他人的，依照本法第51条的规定为该合伙人办理退伙结算，或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。

11. 丁、贺、李、秦四人成立了一个普通合伙企业，现在合伙企业存续期间，出现下列情况，在合伙协议没有明确规定的情况下，合伙人的主张不成立的有（ ）。

- A. 丁在合伙企业成立1年后丧失了偿债的能力，丁当然退伙
- B. 秦要求退伙，丁、贺、李三人同意了这一要求
- C. 因为一起侵权案件，贺须向被侵权人承担赔偿责任，贺在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行，贺应当被除名
- D. 李在执行合伙事务时严重违反了合伙协议约定，给合伙企业造成重大损失，秦提出将李除名

【答案】C

【解析】AC两项，《合伙企业法》第48条规定，合伙人有下列情形之一的，当然退伙：①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；②个人丧失偿债能力；③作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；④法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；⑤合伙人在合伙企

业中的全部财产份额被人民法院强制执行。丁属于当然退伙；贺某属于当然退伙，而非除名退伙。

B项，《合伙企业法》第45条规定，合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：①合伙协议约定的退伙事由出现；②经全体合伙人一致同意；③发生合伙人难以继续参加合伙的事由；④其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。第46条规定，合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合伙人。秦属于自愿退伙。

D项，《合伙企业法》第49条第1款规定，合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：①未履行出资义务；②因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；③执行合伙事务时有不正当行为；④发生合伙协议约定的事由。李属于除名退伙。

12. 大学生郑某、杨某、郭某、孙某毕业后决定自主创业，成立一家合伙企业，郑某以劳务出资，杨某以知识产权出资，郭某现金出资5万元，孙某以实物出资5万元，四人签订了合伙协议，则下列说法正确的是（ ）。

A. 郑某、杨某、郭某、孙某之间的合伙协议应当载明合伙企业的经营范围和合伙人争议的解决方式

B. 郑某以劳务出资，应委托法定评估机构根据其工作的时间和能力评估确定

C. 杨某以知识产权出资，其出资份额不得超过合伙企业注册资本的20%

D. 孙某以实物出资，其作价必须由全体合伙人委托法定评估机构进行评估

【答案】A

【解析】A项，《合伙企业法》第18条规定，合伙协议应当载明下列事项：①合伙企业的名称和主要经营场所的地点；②合伙目的和合伙经营范围；③合伙人的姓名或者名称、住所；④合伙人的出资方式、数额和缴付期限；⑤利润分配、亏损分担方式；⑥合伙事务的执行；⑦入伙与退伙；⑧争议解决办法；⑨合伙企业的解散与清算；⑩违约

责任。本题中，符合第②、⑧项的规定。

B项，《合伙企业法》第16条第3款规定，合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。

C项，《合伙企业法》没有规定“知识产权出资，其出资份额不得超过合伙企业注册资本的20%”。

D项，《合伙企业法》第16条第2款规定，合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可由全体合伙人委托法定评估机构进行评估。

13. 甲、乙、丙、丁四人达成合伙协议，成立一合伙饭店，以乙的名义登记为个体户，名为“一品鲜饭店”。出资比例为各占1/4。甲为厨师劳务出资，作价出资10万元，同时甲每月开工资8000元；乙、丙和丁每人现金出资10万元，乙出资10万元到位，丙、丁没有出资。开业第二天，甲在给客人炒菜时不明原因炉灶突然爆燃失火将甲烧伤，花去医疗费40000元。以下说法中正确的是（ ）。

A. 丁有权随时主张解除合伙合同而退出合伙

B. 甲劳务出资无效，因此甲不是合伙人

C. 因为丙没有出资，丁有权拒绝出资10万元

D. 甲自担损失10000元

【答案】D

【解析】A项，根据《民法典》第976规定，合伙人对合伙期限没有约定或者约定不明确，依据《民法典》第510条的规定仍不能确定合伙期限的，视为不定期合伙。合伙人可以随时解除不定期合伙合同，但是应当在合理期限之前通知其他合伙人。甲、乙、丙、丁四人没有约定合伙期限，视为不定期合伙，丁有权主张解除合伙合同而退伙，但不是随时解除而退伙，应当在合理期限之前通知其他合伙人。

B项，民事活动坚持“法无禁止即自由”的原则，《民法典》对合伙出资形式没有具体规定限制和禁止条件，合伙人出资坚持“意思自治原则”，因此甲以劳务出资的行为有效，甲具有合伙人的身份，享有合伙人权利，承担合伙人义务。

C项，《民法典》第968条规定，合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出资义务。一个或者数个合伙人不履行出

资义务的，其他合伙人不能因此拒绝出资。因此，丁不能以丙没有履行出资义务而抗辩，拒绝履行自己的出资义务。

D项，本题中，甲有双重身份：①甲是合伙合同的当事人，是合伙人；②甲与合伙组织，又存在劳动关系。甲因为执行合伙工作任务造成损害，全体合伙人应当对甲的损失40000元承担连带赔偿责任。

《民法典》第973条规定，合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。因此甲的40000元医疗费损失甲乙丙丁四人承担连带赔偿责任，内部等额按份分担损失，因此甲、乙、丙、丁每人分担10000元，因此甲可以要求乙、丙、丁承担30000元医疗费力的连带赔偿责任。

二、多项选择题

1. 甲、乙、丙共同出资设立某普通合伙企业，分别出资50万元、10万元和40万元。甲、乙、丙共同约定由甲执行合伙事务。合伙企业经营良好，于是甲找乙和丙协商增资投资一个不在经营范围内的项目，合伙协议无特别约定，就该增资事宜合伙企业需如何做出决议？
()

- A. 可以协商不按照出资比例进行增资缴纳
- B. 决议需要甲乙通过即可
- C. 决议需要甲乙丙共同通过
- D. 决议需要甲丙通过即可

【答案】A|C

【解析】A项，合伙企业强调人合性和合伙人自治，故增资比例可由全体合伙人协商决定，未必按照原出资比例认缴。

BCD三项，《合伙企业法》第31条规定，除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点。扩充合伙企业的经营范围属于全体合伙人一致决议的事项。故本案中决议需经全体合伙人一致同意。

2. 郭蓉和王倩设立火凤凰火锅店（普通合伙企业），出资比例分别是80%和20%，合伙协议约定郭蓉是合伙企业事务执行人。后郭蓉聘请

国外留学回来的表妹小黄担任火锅店的经营管理人员全权负责火锅店的运营事务。王倩后来得知此消息但未对此事表态。小黄大胆地更换了火锅店的大厨和服务员，火锅店生意日渐好转，终扭亏为盈。一年后，为扩大火锅店的规模，小黄以合伙企业名义向小李借款100万元用于火锅店的经营，并以火锅店的店面做抵押。下列说法正确的有（ ）。

- A. 小黄无权以火锅店店面做抵押
- B. 小黄无权更换大厨和服务员
- C. 小黄自王倩同意后正式成为火锅店的经营管理人员
- D. 小黄无权以合伙企业名义向小李借款

【答案】A|C

【解析】《合伙企业法》第31条规定，除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：①处分合伙企业的不动产；②聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

A项，用合伙企业店面设定抵押系处分合伙企业不动产的行为，依法应经全体合伙人一致同意，所以小黄作为经营管理人员无权实施此行为。

BD两项，更换大厨和服务员以及借款均属于合伙企业正常的经营范围，无法定特殊情形，小黄作为经营管理人员被授权全权负责火锅店的运营事务，有权代表合伙企业实施此行为。

C项，郭蓉作为合伙协议约定的合伙事务执行人，并无单独决定聘请经营管理人员的权利，其越权聘任的情形被王倩知情后，王倩未表态视为对此聘任结果的追认，故此时的聘任生效。

3. 杨某、段某、郭某、黄某、周某是某有限合伙企业的合伙人，其中杨某是普通合伙人，段某、郭某、黄某、周某是有限合伙人。合伙协议对合伙份额的转让、质押等处分行为未做约定。下列说法正确的有（ ）。

- A. 杨某死亡后，其合法继承人有权继承杨某在该合伙企业中的份额

B. 段某的债权人申请法院执行段某的合伙份额还债，其他合伙人不能主张优先购买权

C. 郭某对外转让其合伙份额时，其他合伙人无权主张优先购买权

D. 黄某可随时转让其合伙份额给周某

【答案】C|D

【解析】A项，《合伙企业法》第50条第1款规定，合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。杨某作为普通合伙人，其死亡后继承人需要在法定条件下才能继承其资格，并非绝对“有权”继承。

B项，《合伙企业法》第74条第2款规定，人民法院强制执行有限合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人。在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。虽然有限合伙人份额没有人合属性，但是在法院强制执行时，为了提高执行效率，保护其他合伙人的优先购买权。

C项，《合伙企业法》第73条规定，有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提30日通知其他合伙人。郭某作为有限合伙人，其份额没有人合属性，对外转让时，只需要提前30日通知其他合伙人。不用其他合伙人同意也不保护其他合伙人的优先购买权。

D项，有限合伙人的份额在合伙人内部可以自由转让。

4. 甲公司是合伙企业乙的有限合伙人之一，乙运营良好但是一直没有向甲公司分配利润。后甲公司经营不善，法院裁定进行破产重整，根据重整计划，甲公司被注销，全部资产及权利义务关系归丙公司承接。下列说法正确的有（ ）。

A. 甲公司进入破产重整程序以后，立即丧失有限合伙人资格

B. 丙公司可继承甲公司的合伙人资格

C. 重整期间，管理人有权查阅、复制乙合伙企业的财务账簿等财务资料

D. 甲公司重整期间，管理人可以将其在乙合伙的份额设定质押

【答案】BD

【解析】A项，《合伙企业法》第48条规定，合伙人有下列情形之一的，当然退伙：作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产。《合伙企业法》第78条规定，有限合伙人有本法第48条第1款第1项、第3项至第5项所列情形之一的，当然退伙。作为有限合伙人的法人或者其他组织主体灭失时才会法定退伙，而甲公司进入破产重整程序时，尚未注销或宣告破产，主体尚未灭失，不会立即丧失有限合伙人资格。

B项，《合伙企业法》第80条规定，作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。甲公司作为有限合伙人注销，丙公司作为其权利承受人，可以继承其有限合伙人的资格。

C项，《合伙企业法》第68条规定，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。有限合伙人的下列行为。不视为执行合伙事务：对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料。有限合伙人在合伙企业中，只是财务投资者，对其知情权有相应的限制，只能查阅与自身利益有关的财务账簿，但不能复制。

D项，《合伙企业法》第72条规定，有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质；但是，合伙协议另有约定的除外。合伙协议无特殊约定的，有限合伙人有权将其份额质押。

5. 雀凰投资是有限合伙企业，从事私募股权投资活动。2017年3月，三江有限公司决定入伙雀凰投资，成为其有限合伙人。对此，下列哪些选项是错误的？（ ）

A. 如合伙协议无特别约定，则须经全体普通合伙人一致同意，三江公司才可成为新的有限合伙人

B. 对入伙前雀凰投资的对外负债，三江公司仅以实缴出资额为限承担责任

C. 三江公司入伙后，有权查阅雀凰投资的财务会计账簿

D. 如合伙协议无特别约定，则三江公司入伙后，原则上不得自营与雀凰投资相竞争的业务

【答案】A|B|C|D

【解析】A项，《合伙企业法》第43条第1款规定，新合伙人入伙，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。据此，在合伙协议没有特别约定的情况下，有限合伙人的入伙需要经过其他全体合伙人的一致同意而不仅仅是普通合伙人的同意。

B项，《合伙企业法》第77条规定，新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。据此，三江公司应当以认缴的出资额而不是以实缴的出资额为限承担责任。

C项，根据《合伙企业法》第68条第2款第5项的规定，对涉及自身利益的情况，有限合伙人查阅企业财务会计账簿等财务资料不视为执行合伙企业事务。由此可知，有限合伙人只有在涉及自身利益的情况下才能够查阅合伙企业财务会计账簿，而不能随意查阅。

D项，《合伙企业法》第71条规定，有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；但是，合伙协议另有约定的除外。由此可知，三江公司原则上可以自营与雀凰投资相竞争的业务。

6. 灏德投资是一家有限合伙企业，专门从事新能源开发方面的风险投资。甲公司是灏德投资的有限合伙人，乙和丙是普通合伙人。关于合伙协议的约定，下列哪些选项是正确的？（ ）]

- A. 甲公司派驻灏德投资的员工不领取报酬，其劳务折抵10%的出资
- B. 甲公司不得与其他公司合作从事新能源方面的风险投资
- C. 甲公司不得将自己在灏德投资中的份额设定质权
- D. 甲公司不得将自己在灏德投资中的份额转让给他人

【答案】B|C

【解析】A项，《合伙企业法》第64条规定，有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限

合伙人不得以劳务出资。本题中，甲公司为灏德投资的有限合伙人，不能以劳务出资，故合伙协议不能约定甲公司以劳务出资。

B项，《合伙企业法》第71条规定，有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；但是，合伙协议另有约定的除外。据此，合伙协议可以约定甲公司不得与其他公司合作从事新能源方面的风险投资。

C项，《合伙企业法》第72条规定，有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质；但是，合伙协议另有约定的除外。据此，合伙协议可以排除甲公司对合伙份额的出质权。

D项，《合伙企业法》第73条规定，有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前30日通知其他合伙人。据此，转让合伙企业份额是有限合伙人不可剥夺的权利，合伙协议不能禁止合伙份额转让。

7. 2015年6月，刘璋向顾谐借款50万元用来炒股，借期1个月，结果恰遇股市动荡，刘璋到期不能还款。经查明，刘璋为某普通合伙企业的合伙人，持有44%的合伙份额。对此，下列哪些说法是正确的？
()

- A. 顾谐可主张以刘璋自该合伙企业中所分取的收益来清偿债务
- B. 顾谐可主张对刘璋合伙份额进行强制执行
- C. 对刘璋的合伙份额进行强制执行时，其他合伙人不享有优先购买权
- D. 顾谐可直接向合伙企业要求对刘璋进行退伙处理，并以退伙结算所得来清偿债务

【答案】A|B

【解析】AB两项，《合伙企业法》第42条第1款规定，合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。顾谐可以主张以刘璋在该合伙企业中所分取的收益清偿债务，也可以主张对刘璋合伙份额进行强制执行。

CD两项，《合伙企业法》第42条第2款规定，人民法院强制执行

合伙人的财产份额时，应当通知全体合伙人，其他合伙人有优先购买权；其他合伙人未购买，又不同意将该财产份额转让给他人的，依照本法第51条的规定为该合伙人办理退伙结算，或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。对刘璋的合伙份额进行强制执行时，其他合伙人享有优先购买权。相比合伙份额转让，合伙人退伙会给合伙企业造成更大的不良影响，只有在合伙人的合伙份额无法转让给其他人时，才能办理退伙结算。

8. 君平昌成律师事务所是一家采取特殊普通合伙形式设立的律师事务所，曾君、郭昌是其中的两名合伙人。在一次由曾君主办、郭昌辅办的诉讼代理业务中，因二人的重大过失而泄露客户商业秘密，导致该所对客户应承担巨额赔偿责任。关于该客户的求偿，下列哪些说法是正确的？（ ）

- A. 向该所主张全部赔偿责任
- B. 向曾君主张无限连带赔偿责任
- C. 向郭昌主张补充赔偿责任
- D. 向该所其他合伙人主张连带赔偿责任

【答案】A|B

【解析】A项，《合伙企业法》第58条规定，合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任。据此，客户可以要求君平昌成律师事务所承担全部赔偿责任，律所应以该所的全部财产对合伙人给客户造成的损失承担责任后，由合伙人曾君、郭昌按照合伙协议的约定对给律所造成的损失承担赔偿责任。

BCD三项，《合伙企业法》第57条第1款规定，一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。本题中，因为曾君、郭昌的重大过失致人损害，应当由曾君、郭昌对客户的损失承担无限连带责任，而其他合伙人仅以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

9. 甲、乙、丙、丁以合伙企业形式开了一家餐馆。就该合伙企业事务的执行，下列哪些表述是正确的？（ ）

- A. 如合伙协议未约定，则甲等四人均享有对外签约权
- B. 甲等四人可决定任命丙为该企业的对外签约权人
- C. 不享有合伙事务执行权的合伙人，以企业名义对外签订的合同一律无效
- D. 不享有合伙事务执行权的合伙人，经其他合伙人一致同意，可担任企业的经营管理人

【答案】A|B|D

【解析】A项，《合伙企业法》第26条规定，合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。所以，合伙协议没有约定时，合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。

B项，根据《合伙企业法》第26条的规定，如果根据合伙协议的约定或者经过全体合伙人一致同意，由一人或者数个合伙人执行合伙事务的，则其他合伙人不再执行合伙事务。甲等四人为全体合伙人，可以决定任命丙为该企业的对外签约权人。

D项，根据《合伙企业法》第31条第6项的规定，除合伙协议另有约定外，聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员，应当经全体合伙人一致同意。本条规定了聘请合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员的表决方式，而并没有禁止合伙人担任经营管理人。所以，经其他合伙人一致同意，合伙人可以担任经营管理人。

C项，《合伙企业法》第37条规定，合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。即合伙企业对所有合伙人所做的任何内部限制对内有效，对外一律无效，不得对抗善意第三人，这就是“内不抗外”的原则。所以，不享有合伙事务执行权的合伙人，以企业名义对外签订的合同并非一律无效，如果经全体合伙人一致同意，则为有效。

10. 2009年3月，周、吴、郑、王以普通合伙企业形式开办一家湘菜馆。2010年7月，吴某因车祸死亡，其妻欧某为唯一继承人。在下列哪

些情形中，欧某不能通过继承的方式取得该合伙企业的普通合伙人资格？（ ）

- A. 吴某之父对欧某取得合伙人资格表示异议
- B. 合伙协议规定合伙人须具有国家一级厨师资格证，欧某不具有
- C. 郑某不愿意接纳欧某为合伙人
- D. 欧某因夫亡突遭打击，精神失常，经法院宣告为无民事行为能力人

【答案】B|C|D

【解析】《合伙企业法》第50条规定，合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。有下列情形之一的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额：①继承人不愿意成为合伙人；②法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格，而该继承人未取得该资格；③合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人。

A项，欧某作为吴某唯一的继承人，吴某父亲作为合伙人之外的人，对欧某继承吴某的合伙人资格一事，不享有任何权利。因此吴某的父不同意，不妨碍欧某继承吴某的合伙人资格。

B项，合伙协议约定合伙人必须具有国家一级厨师资格证，欧某不具有该资格，从而不能继承合伙人资格。

C项，欧某作为吴某的唯一继承人，如继承吴某的普通合伙人资格，须依照合伙协议的约定或经全体合伙人一致同意，C项中合伙人郑某不同意，因此欧某不能继承合伙人资格。

D项，欧某成为无民事行为能力人，即使经全体合伙人一致同意，也只能成为有限合伙人，但不能成为普通合伙人。

11. 甲、乙、丙三人拟共同设立一个有限合伙企业，下列哪些表述是错误的？（ ）

- A. 该有限合伙企业至少应当有一个普通合伙人
- B. 经合伙协议约定，有限合伙人可以货币、实物、劳务、知识产权或其他财产作价出资
- C. 经合伙协议约定，有限合伙人可以执行部分合伙事务
- D. 如有限合伙人转为普通合伙人，则对其作为有限合伙人期间企业的债务不承担连带责任

【答案】B|C|D

【解析】A项，《合伙企业法》第61条第2款规定，有限合伙企业至少应当有1个普通合伙人。

B项，《合伙企业法》第64条规定，有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。与普通合伙人不同，有限合伙人不能以劳务出资。

C项，《合伙企业法》第68条第1款规定，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。该条规定是强制性规定，合伙人不能在合伙协议中作相反约定，否则协议无效。

D项，《合伙企业法》第83条规定，有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。此条是强制性规定，合伙协议作出相反约定的无效。

12. 张某为避免合作矛盾与问题，不想与人合伙或合股办企业，欲自己单干。朋友对此提出以下建议，其中哪一建议是错误的？（ ）

- A. “可选择开办独资企业，也可选择开办一人有限公司”
- B. “如选择开办一人公司，那么注册资本不能少于10万元”
- C. “如选择开办独资企业，则必须自己进行经营管理”
- D. “可同时设立一家一人公司和一家独资企业”

【答案】B|C

【解析】A项，《公司法》第57条第2款规定，本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。根据该条规定可知，自然人和法人均可作为股东设立一人有限公司，因此，在本题中，张某可以开办一人有限公司。《个人独资企业法》第2条规定，本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。本题中，张某作为自然人，可以开办个人独资企业。

B项，现行《公司法》对一人公司已无最低注册资本的限制。

C项，《个人独资企业法》第19条第1款规定，个人独资企业投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。由此可知，自然人开办个人独资企业，并不是必须自己进行管理。

D项，《公司法》第58条规定，一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。因此，法律仅限制一个自然人只能开办一个一人公司，并不限制一个自然人同时开办一人公司和个人独资企业。

13. 万豪以20万元（认缴80万元）入伙喜来旅店（有限合伙企业），成为有限合伙人。后该企业的另一名有限合伙人退出，万豪便成为唯一的有限合伙人。2019年3月，万豪不幸发生车祸，虽经抢救保住性命，但已成为植物人。对此，下列表述错误的是（ ）。

- A. 就万豪入伙前该合伙企业的债务，其需以20万元为限承担责任
- B. 就万豪入伙前该合伙企业的债务，其需以80万元为限承担责任
- C. 因万豪已成为植物人，故该合伙企业有权要求其退伙
- D. 因唯一的有限合伙人已成为植物人，故该有限合伙企业应转为普通合伙企业

【答案】A|C|D

【解析】AB两项，《合伙企业法》第77条规定，新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。因此万豪应当以其认缴的80万元对合伙企业的债务承担责任。

CD两项，《合伙企业法》第79条规定，作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。因此该合伙企业无权要求其退伙，该有限合伙企业无须转为普通合伙企业。

14. 美国人川特计划在中国投资，根据《外商投资法》，关于负面清单，下列说法正确的是（ ）。

- A. 外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，川特不得投资
- B. 外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，川特不得投资
- C. 外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，川特进行投资应当符合负面清单规定的条件
- D. 外商投资准入负面清单以外的领域，按照外资优先的原则实施管理

【答案】A|C

【解析】A项，《外商投资法》第28条第1款规定，外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得投资。

BC两项，第28条第2款规定，外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，外国投资者进行投资应当符合负面清单规定的条件。

D项，第28条第3款规定，外商投资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则实施管理。

三、不定项选择题

1. 甲、乙、丙三人共同商定出资设立一家普通合伙企业，其中约定乙以其所有房屋的使用权出资，企业的财务由甲负责。2015年4月，该合伙企业亏损巨大。5月，见股市大涨，在丙不知情的情况下，甲与乙直接将企业账户中的400万元资金，以企业名义委托给某投资机构来进行股市投资。同时，乙自己也将上述房屋以600万元变卖并过户给丁，房款全部用来炒股。至6月下旬，投入股市资金所剩无几。丙得知情况后突发脑溢血死亡。

1). 关于甲、乙将400万元资金委托投资股市的行为，下列说法正确的是（ ）。

- A. 属于无权处分行为
- B. 属于改变合伙企业经营范围的行为
- C. 就委托投资失败，甲、乙应负连带赔偿责任
- D. 就委托投资失败，该受托的投资机构须承担连带责任

【答案】C

【解析】A项，《合伙企业法》第31条规定，除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：①改变合伙企业的名称；②改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；③处分合伙企业的不动产；④转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；⑤以合伙企业名义为他人提供担保；⑥聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。本题中，甲、乙决定将合伙企业的400万元现金用于股市投资，不属于应当由全体合伙人一致同意的情形，按照合伙企业事务执行的一般决议程序办理即可。《合伙企业法》第30条第1款规定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。本题中，甲、乙决定将合伙企业的400万元现金用于股市投资，因为表决人数已经超过了全体合伙人的半数，故甲、乙有权决定将400万元现金用于股市投资，甲、乙的行为属于有权处分。

B项，甲、乙二人只是临时动用合伙企业资金炒股，并不涉及改变合伙企业经营范围的问题，不属于改变合伙企业经营范围的行为。

CD两项，合伙人对合伙企业有关事项作出决议应经全体合伙人过半数或者一致同意，方为有效。甲、乙二人违反合伙企业表决程序，在丙不知情的情况下擅自动用合伙企业财产炒股，给合伙企业造成损失，就委托投资失败应当承担连带责任。就委托投资失败，题干中并未说明受托的投资机构存在过错或者违反委托合同约定，因此在考虑责任承担时，该受托的投资机构不需承担责任。

2). 关于乙将房屋出卖的行为，下列选项正确的是（ ）。

- A. 构成无权处分行为
- B. 丁取得该房屋所有权
- C. 丁无权要求合伙企业搬出该房屋
- D. 乙对合伙企业应承担违约责任

【答案】B|D

【解析】A项，以房屋使用权出资的，出资人并不因出资行为而丧失房屋的所有权，出资财产的所有权仍属于出资人，合伙企业只享有使用和管理权。乙以其房屋使用权作为出资，并未将房屋所有权转移给合伙企业，其对房屋仍然享有处分权，故乙将房屋卖给丁属于有权处分。

BC两项，《民法典》第209条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但是法律另有规定的除外。乙将房屋出卖给丁，并且办理了过户登记，丁获得房屋所有权，有权要求合伙企业搬出该房屋。

D项，《合伙企业法》第103条第1款规定，合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。对合伙企业而言，乙按照合伙协议约定将房屋使用权作为对合伙企业的出资，其擅自转卖房屋给丁违反了合伙协议，应当对合伙企业承担违约责任。

3). 假设丙有继承人戊，则就戊的权利，下列说法错误的是（ ）。

- A. 自丙死亡之时起，戊即取得该合伙企业的合伙人资格
- B. 因合伙企业账面上已处于亏损状态，戊可要求解散合伙企业并进行清算
- C. 就甲委托投资股市而失败的行为，戊可直接向甲主张赔偿
- D. 就乙出卖房屋而给企业造成的损失，戊可直接向乙主张赔偿

【答案】A|B|C|D

【解析】A项，《合伙企业法》第50条第1款规定，合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。戊要成为继承人，需符合合伙协议约定或经全体合伙人一致同意，而不能当然取得合伙人资格。

B项，第85条规定，合伙企业有下列情形之一的，应当解散：①合伙期限届满，合伙人决定不再经营；②合伙协议约定的解散事由出现；③全体合伙人决定解散；④合伙人已不具备法定人数满三十天；⑤合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；⑥依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；⑦法律、行政法规规定的其他原因。合伙企业亏损并非合伙企业解散的法定事由，戊作为丙的继承人还没有取得合伙人资格，其没有权利要求解散合伙企业。

CD两项，第96条规定，合伙人执行合伙事务，或者合伙企业从业人员利用职务上的便利，将应当归合伙企业的利益据为己有的，或者采取其他手段侵占合伙企业财产的，应当将该利益和财产退还合伙企业。给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

甲、乙将合伙企业的400万元资金用于炒股，违反了合伙人对合伙企业的忠实勤勉义务，给合伙企业造成损失，应当对合伙企业或者其他合伙人承担责任。乙擅自转卖房屋，给合伙企业造成损失，应当对合伙企业或者其他合伙人承担责任。但戊作为丙的继承人，并不能当然成为合伙人，所以不能直接向甲或乙主张赔偿。

2. 王某、张某、田某、朱某共同出资180万元，于2012年8月成立绿园商贸中心（普通合伙）。其中王某、张某各出资40万元，田某、朱某各出资50万元；就合伙事务的执行，合伙协议未特别约定。

1). 2013年9月，鉴于王某、张某业务能力不足，经合伙人会议决定，王某不再享有对外签约权，而张某的对外签约权仅限于每笔交易额3万元以下。关于该合伙人决议，下列选项正确的是（ ）。

A. 因违反合伙人平等原则，剥夺王某对外签约权的决议应为无效

B. 王某可以此为由向其他合伙人主张赔偿其损失

C. 张某此后对外签约的标的额超过3万元时，须事先征得王某、田某、朱某的同意

D. 对张某的签约权限制，不得对抗善意相对人

【答案】C|D

【解析】AB两项，《合伙企业法》第26条规定，合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以委托1个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。因此，合伙人会议有权决定王某不享有对外签约的权利，而且这样的决定不会给王某造成经济损失。

C项，合伙企业对合伙人的代表权限限制在合伙企业内部，具有拘束力，张某必须遵从合伙人会议决定。

D项，《合伙企业法》第37条规定，合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。因此，对张某的签约限制仅对内有效，但对外不得对抗善意第三人。

2). 2014年1月，田某以合伙企业的名义，自京顺公司订购价值80万元的节日礼品，准备在春节前转销给某单位。但对这一礼品订购合同的签订，朱某提出异议。就此，下列选项正确的是（ ）。

A. 因对合伙企业来说，该合同标的额较大，故田某在签约前应取得朱某的同意

B. 朱某的异议不影响该合同的效力

C. 就田某的签约行为所产生的债务，王某无须承担无限连带责任

D. 就田某的签约行为所产生的债务，朱某须承担无限连带责任

【答案】B|D

【解析】A项，合伙企业对田某的对外代表权限并无特别规定，则该订购合同的签订不因数额较大而需要特别征得朱某同意。

B项，《合伙企业法》第29条第1款规定，合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应当暂停该项事务的执行。如果发生争议，依照《合伙企业法》第30条规定作出决定。本题中，事务执行人提出异议，相关事务应当暂行执行。但田某对外签约是以合伙企业的名义，完全合法有

效，故异议不影响合同的效力。

CD两项，《合伙企业法》第38条规定，合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。第39条规定，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。本题中的合伙企业属于普通合伙企业，所有的合伙人对外都要承担无限连带责任，而不论是否执行合伙企业事务。因此，就田某的签约行为所产生的债务，王某、朱某作为共同合伙人均须承担无限连带责任。

3). 2014年4月，朱某因抄底买房，向刘某借款50万元，约定借期四个月。四个月后，因房地产市场不景气，朱某亏损不能还债。关于刘某对朱某实现债权，下列选项正确的是（ ）。

- A. 可代位行使朱某在合伙企业中的权利
- B. 可就朱某在合伙企业中分得的收益主张清偿
- C. 可申请对朱某的合伙财产份额进行强制执行
- D. 就朱某的合伙份额享有优先受偿权

【答案】B|C

【解析】A项，《合伙企业法》第41条规定，合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务，也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。本题中，朱某与刘某的债权债务与合伙企业无关，因此不可代位行使朱某在合伙企业中的权利。

BC两项，《合伙企业法》第42条第1款规定，合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿，债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。

D项，《合伙企业法》第23条规定，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。但是，合伙协议另有约定的除外。刘某非合伙内部成员，故不享有优先受偿权。

四、概念题

1. 个人独资企业

【答案】

个人独资企业是指一个自然人投资，财产属投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。其特征包括：①一个自然人出资，生产资料归投资者所有；②雇工经营；③具有一定的生产经营规模。

2. 合伙

【答案】

合伙是指两个以上自然人或法人以共同经营为目的，相约共同出资、共享利益、共担风险的合同。在法律关系上，合伙有两种类型：①作为民事法律行为，即合伙合同，不设立企业；②将设立企业作为合伙合同的法律效力，企业是合伙人所组成的人与财产相结合的实体。根据我国法律规定，合伙包括普通合伙和有限合伙。合伙属于非法人组织，具有民事主体的资格。

3. 普通合伙

【答案】

普通合伙是指由两个以上的人根据协议，互约出资，经营共同事业，并对合伙债务承担无限连带责任的社会组织。普通合伙企业属于营利性普通合伙。其法律特征有：①由两个以上的人组成的组织；②合伙协议是合伙形成的基础条件；③合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，并对合伙的债务承担无限连带责任。

4. 有限合伙

【答案】

有限合伙是指由对合伙债务承担有限责任的有限合伙人和对合伙债务承担无限责任的普通合伙人共同组成的合伙。有限合伙的特征有：①有限责任与无限责任相结合；②由普通合伙人执行合伙事务。

5. 有限合伙企业

【答案】

有限合伙企业是指由一个以上的普通合伙人和一个以上的有限合伙人

共同设立的合伙企业。换言之，有限合伙企业中至少有一个普通合伙人和至少有一个有限合伙人，否则就不能成为有限合伙。根据《合伙企业法》的规定，有限合伙企业由2个以上50个以下合伙人设立，但法律另有规定的除外。

6. 外商投资

【答案】外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下简称“外国投资者”）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括：①外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；②外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益；③外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；④法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资。

外商投资企业组织形式、组织机构及其活动准则，适用《公司法》《合伙企业法》等法律的规定。

五、简答题

1. 简述合伙法律特征。

【答案】合伙是指两个以上的人互约出资，经营共同事业。合伙属于非法人组织，具有民事主体的资格，能以合伙的名义进行民事活动。我国法律规定的合伙包括普通合伙和有限合伙。普通合伙又包括特殊的普通合伙。具体如下：

（1）普通合伙。指由两个以上的人根据协议，互约出资，经营共同事业，并对合伙债务承担无限连带责任的社会组织。普通合伙企业属于营利性普通合伙。其法律特征有：①由两个以上的人组成的组织；②合伙协议是合伙形成的基础条件；③合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，并对合伙的债务承担无限连带责任。

（2）特殊的普通合伙。指在特定情况下，不由全体合伙人对合伙债务承担无限连带责任的普通合伙。特殊的普通合伙的特征包括：

①是一种特殊的普通合伙。在特定情况下各合伙人对合伙债务承担的责任不同。

②在特定情况下不由全体合伙人对合伙债务承担无限连带责任。因故意或者重大过失造成的合伙债务，应当由其责任人承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以合伙份额为限承担责任。非因故意或者重大过失造成的合伙债务由全体合伙人承担无限连带责任。

（3）有限合伙。指由对合伙债务承担有限责任的有限合伙人和对

合伙债务承担无限责任的普通合伙人共同组成的合伙。有限合伙的特征有：

①有限责任与无限责任相结合。有限合伙中，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

②由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人不得执行合伙事务，不得对外代表有限合伙。

2. 有限合伙设立的条件。

【答案】有限合伙的设立需具备以下条件：

(1) 普通合伙具备的条件，包括：①有两个以上合伙人；②有书面合伙协议；③有合伙人认缴或者实际缴付的出资；④有合伙企业的名称和生产经营场所。

(2) 与普通合伙不同，有限合伙还需要具备以下条件：

①除非法律另有规定的，由2个以上50个以下的合伙人组成，其中至少有一个普通合伙人。

②除普通合伙协议内容以外，还应载明法律规定的其他事项。

③有限合伙名称中应当标明“有限合伙”字样。

④有限合伙人的出资。有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。劳务出资会导致出资与责任分配不明，不利于保护债权人。有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。有限合伙登记事项中应载明有限合伙人的姓名或者名称及认缴出资数额。这一做法对维护交易安全，保护交易相对人的利益有着积极作用。

3. 简述入伙的效力。

【答案】入伙，是指非合伙人加入已成立的合伙，而取得合伙人资格的行为。入伙人与原合伙人依法签订入伙协议书后即取得合伙人的资格。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙协议另有约定的，从其约定。

(1) 普通合伙人的入伙。新入伙人对入伙前的合伙债务承担无限连带责任，从而保护了债权人的利益，避免合伙人串通用推迟入伙日期的方法逃避债务。

(2) 有限合伙人的入伙。新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

4. 合伙企业债务的承担与清偿。

【答案】（1）普通合伙人的合伙债务的承担与清偿：

①合伙债务的承担。合伙企业应先以其全部财产对其所承担的债务进行清偿。合伙企业不能清偿的，由合伙人承担无限连带责任。合伙人清偿数额超过其应当承担份额，可以向其他合伙人追偿。应注意的是：

a. 合伙人如果是以个人财产出资参与合伙，则以个人财产对合伙债务承担无限责任。

b. 合伙人如果是以家庭财产出资参与合伙，则应以合伙人家庭共有财产对合伙债务承担无限责任。

c. 合伙人如果是以个人财产出资参与合伙，但将合伙盈余分配所得用于合伙人家庭成员的共同生活，则应先以合伙人的个人财产承担清偿责任，不足部分则以合伙人的家庭共有财产承担。

②合伙人个人债务的清偿。合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。如果同时存在合伙债务与合伙人个人债务且二者皆不能完全清偿时，合伙的财产优先清偿合伙的债务，合伙人个人的财产优先清偿个人债务。

（2）有限合伙人的合伙债务的承担与清偿：

在一个合伙企业中，普通合伙人对合伙的债务承担无限连带责任，有限合伙人对合伙的债务承担有限责任。

①有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间合伙发生的债务承担无限连带责任。

②普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙发生的债务承担无限连带责任。

（3）合伙企业的清偿与分配顺序：

合伙解散后，应当开始清算，清算时合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产按照各合伙人应得的比例进行分配。

（4）合伙企业注销后合伙人对合伙债务的责任：

合伙注销后，原合伙人对合伙企业存续期间的债务，仍应承担清偿责任。

①普通合伙企业。普通合伙人承担无限连带责任；特殊的普通合伙的合伙人一般承担无限连带责任，但是对于部分合伙人在执业活动

中因故意或者重大过失造成的合伙债务，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

②有限合伙企业。普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其出资为限承担责任。原合伙人对合伙企业存续期间的债务清偿应当适用《民法典》一般诉讼时效期间的规定。

六、案例分析题

1. 张某、王某是好朋友，张某出资2万元，王某出资3万元，共同投资了一饭馆，由张某经营，利润按比例分享，亏损由双方按比例分担。后经营不善，王某提出散伙。饭馆现有资产5.5万元。

问：

(1) 若张某提出将王某应有的份额卖给自己，王某不愿意，后张某提出4万元买下王某的份额，王某则称宁可以3万元卖给他人，后王某以2.5万元卖给了李某，为此，张某诉至法院，要求确认王、李的买卖行为无效，王某应将份额出售给他，其主张是否成立？为什么？

(2) 若饭馆散伙时欠债15.5万元，应如何分担？

【答案】 (1) 张某请求确认王、李的买卖行为无效的主张不成立。理由如下：

王某和张某之间行为属于个人合伙，而非合伙企业性质。王、张二人出资，经营共同事业，但是没有合伙名称，组织松散，或者是临时性的，其性质属于合伙合同，没有民事主体资格，不受《合伙企业法》的调整。因此，张某不享有《合伙企业法》第23条规定的优先购买权。

(2) 张某和王某应当按照出资比例以各自财产对该债务承担连带清偿责任。理由如下：

《合伙企业法》第38条规定，合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。第39条规定，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。

本案中，对饭馆散伙时所欠债务，张某和王某均负有清偿全部债务的义务；当张某或王某中的一人偿还合伙债务超过自己应当承担的数额时，有权要求另一人偿付其应当承担的份额。

2. 甲因单位困难，下岗在家，生活很困难。他的朋友乙在一家食品厂做销售工作，建议甲在社区内开一家食品店，为该食品厂代销各种食品，乙答应为甲供货，价格从优，而且乙可以赊销，甲卖后再给乙

钱。因为甲没有钱注册登记，担心工商部门不给执照。乙说个人独资企业又不是公司，没有注册资本的要求，一块钱也可以办企业。

试对乙的说法进行分析。

【答案】《个人独资企业》第8条规定，设立个人独资企业的条件：投资人为自然人；有合法的企业名称；有投资人申报的出资；有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件；有必要的从业人员。甲要开办食品店，只要符合以上条件即可注册。虽然《个人独资企业法》对个人独资企业的设立没有规定最低注册资本金的要求，但这并不是企业的设立和经营不需要资金保障，也不意味着企业登记不必需要注册资本。

个人独资企业是一种营利性的组织，其从事经营活动必须有经济基础，如没有物质保障，即一元钱就可以办企业，那就很可能产生欺骗行为，损害债权人的利益。投资人申报的出资是个人独资企业成立之初的经营资本，也是企业对外承担责任的重要财产来源。

规定出资是国家对个人独资企业监督的要求。事实上，在设立个人独资企业时，投资人承诺将投入企业的资金不仅是企业设立和经营的基本保障，也是登记机关据以登记的企业出资额。由于个人独资企业对资金的需求相对较小，同时为了鼓励中小企业的成立，注册资本采取实事求是的方法，不规定最低限额，只要求保障生产经营的实际需要即可。故乙的说法不确切。

第六章 商业银行法与支付法

一、单项选择题

1. 万公司购买梓公司的一批钢材，签发一张承兑汇票给梓公司支付货款，梓公司将该汇票背书给仟公司，并请甲公司提供担保，但没有约定担保金额和被保证人名称，仟公司又背书转让给宏公司。梓公司向万公司交付的钢材质量不达标。宏公司向付款银行提示承兑时被拒绝，以下说法正确的是（ ）。

- A. 宏公司应向仟公司请求给付票据款项
- B. 因钢材质量不达标，万公司有权拒绝向宏公司承担付款责任
- C. 因未约定被保证人名称，甲公司不承担保证责任
- D. 如果梓公司向宏公司给付了票据款项，可向甲公司行使追索权

【答案】D

【解析】A项，《票据法》第50条规定，被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的，持票人有权向保证人请求付款，保证人应当足额付款。持票人在被拒绝承兑后可时其前手义务人连带追索，追索对象并不限于直接前手，所以宏公司可向包含仟公司在内的前手义务人们主张连带责任。

B项，梓公司交付给万公司的钢材质量不合格，此关系仅存在于买卖合同相对方的万公司和梓公司之间，万公司可据此对梓公司的追索提出抗辩，基于票据无因性，此原因与其他主体无关，所以万公司不能据此对宏公司的追索进行抗辩。

C项，《票据法》第47条规定，保证人在汇票或者粘单上未记载前条第3项（被保证人名称）的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人。本案中，甲公司作出保证行为时，未记载被保证人名称，因为票据未被承兑，应视出票人万公司为被保证人，且保证人甲公司与被保证人万公司应对后手承担连带责任。

D项，梓公司行使再追索权，甲公司作为万公司的保证人是梓公司的前手，应对其承担追索的付款责任。

2. 甲公司拖欠乙银行贷款2000万元，到期无力清偿，现乙银行欲通过资产管理公司实现债转股来清理不良贷款，根据《商业银行法》及《银行业监督管理法》下列说法正确的是（ ）。

A. 乙银行应将其对甲公司的债权转移给资产管理公司，由资产管理公司对甲公司进行债转股

B. 乙银行可直接对甲公司进行债转股

C. 应由资产管理公司购买甲公司的股权，甲公司用所得的股款偿还乙银行的欠款

D. 应由乙银行购买甲公司的股份，甲公司用所得的股款偿还乙银行的欠款

【答案】A

【解析】A项，银行清理不良贷款的方式往往是设立资产管理公司，将银行的不良贷款转移给资产管理公司，资产管理公司再用此债权出资到债务人的公司中，转为股权。

BD两项，《商业银行法》第43条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。为了确保银行资金的安全，银行不得向非银行的金融机构或企业投资，本案中，乙银行不能直接向甲公司投资。而债转股本质上是以债权作为出资，所以乙银行不得直接对甲公司债转股。乙银行也不能直接购买甲公司的股份，否则相当于乙银行直接对甲公司投资。

C项，债转股的过程并非通过资产管理公司购买债务人股权来实现。如果这样操作，首先，资产管理公司需要大笔资金，其次，如果该笔资金进入债务人账户被挪作他用而没有归还给银行，会有诸多不可控的后果。

3. 甲公司为支付向乙有限公司采购商品的款项，向乙开具一张金额为100万元的银行承兑汇票，并向丙银行办理了承兑。2018年6月乙又将该票据背书给丁公司，2018年7月丁公司办公楼失火，该张票据被烧毁灭失，仅剩其留档复印件。甲公司、乙公司均在该复印件上签章，以

证明彼此间的交易情况。对此，下列说法正确的是？（ ）

- A. 丙银行无须承担票据责任
- B. 丁公司向丙银行出具票据复印件提示付款，丙银行应当无条件付款
- C. 丁公司可凭票据复印件向乙公司主张票据权利
- D. 丁公司可凭票据复印件向甲公司主张票据权利

【答案】A

【解析】

《票据法》第4条规定，票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。票据是设权证券和要式证券，票据的制作必须严格符合国家法律的规定。票据权利人行使票据权利，应当出示合法有效的票据，票据在灭失之后，可以通过挂失止付、公示催告或提起民事诉讼来实现救济。本题中，票据原件烧毁，票据复印件并不具有票据效力，丁公司无法依该复印件行使票据权利。

4. 甲公司为支付货款向乙公司签发了一张金额为80万元的汇票。丙公司在汇票上作为保证人并签章。下列说法正确的是？（ ）

- A. 甲公司未在汇票上记载被保证人的名称，则丙公司无须承担保证责任
- B. 甲公司未在汇票上记载保证日期的，保证无效
- C. 甲公司可以进行附条件保证
- D. 丙公司与甲公司对持票人乙公司承担连带责任

【答案】D

【解析】AB两项，《票据法》第47条的规定，保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人的名称的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人；未承兑的汇票，出票人为被保证人。保证人在汇票或者粘单上未记载保证日期的，出票日期为保证日期。由此可知，未记载被保证人名称的，丙公司仍需承担保证责任。未记载保证日期的以出票日期为保证日期，保证仍然有效。

C项，《票据法》第48条规定，保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任。

D项，《票据法》第50条规定，被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的，持票人有权向保证人请求付款，保证人应当足额付款。因此，保证人与被保证人之间以及保证人之间就票据债务负连带责任。

5. 甲公司为履行与乙公司的箱包买卖合同，签发一张以乙公司为收款人、某银行为付款人的汇票，银行也予以了承兑。后乙公司将该汇票背书赠与给丙。此时，甲公司发现乙公司的箱包为假冒伪劣产品。关于本案，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 该票据无效
- B. 甲公司不能拒绝乙公司的票据权利请求
- C. 丙应享有票据权利
- D. 银行应承担票据责任

【答案】D

【解析】A项，《票据法》第22条规定，汇票必须记载下列事项：①表明“汇票”的字样；②无条件支付的委托；③确定的金额；④付款人名称；⑤收款人名称；⑥出票日期；⑦出票人签章。汇票上未记载前款规定事项之一的，汇票无效。本题中，票据形式合法，而且签发汇票也不存在非法交易的情形，不存在任何无效事由。

B项，《票据法》第13条规定，票据债务人不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人。但是，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩。本法所称抗辩，是指票据债务人根据本法规定对票据债权人拒绝履行义务的行

为。甲乙公司作为票据的直接前、后手，可以主张票据抗辩，甲公司可以拒绝乙公司的票据权利请求。

C项，《票据法》第11条规定，因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利不得优于其前手的权利。本题中丙接受乙公司赠与而获得票据，其享有的票据权利不能优于其前手乙公司，所以甲公司可以拒绝丙的票据权利请求。

D项，《票据法》第44条规定，付款人承兑汇票后，应当承担到期付款的责任。本题中，银行已经予以承兑，因此，应当承担票据责任。

6. 甲从乙处购置一批家具，给乙签发一张金额为40万元的汇票。乙将该汇票背书转让给丙。丙请丁在该汇票上为“保证”记载并签章，随后又将其背书转让给戊。戊请求银行承兑时，被银行拒绝。对此，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 丁可以采取附条件保证方式
- B. 若丁在其保证中未记载保证日期，则以出票日期为保证日期
- C. 戊只有在向丙行使追索权遭拒绝后，才能向丁请求付款
- D. 在丁对戊付款后，丁只能向丙行使追索权

【答案】B

【解析】A项，《票据法》第48条规定，保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任。据此，丁为保证时不能附条件。

B项，《票据法》第47条第2款规定，保证人在汇票或者粘单上未记载前条第（四）项（保证日期）的，出票日期为保证日期。所以，若丁在其保证中未记载保证日期，则以出票日期为保证日期。

C项，《票据法》第50条规定，被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的，持票人有权向保证人请求付款，保证人应当足额付款。所以，保证人丁应当与被保证人丙对持票人承担连带责任，且没有顺序限制。

D项，《票据法》第52条规定，保证人清偿汇票债务后，可以行使持票人对被保证人及其前手的追索权。所以，丁可以向被保证人丙及其前手甲、乙进行追索。

7. 依票据法原理，票据具有无因性、设权性、流通性、文义性、要式性等特征。关于票据特征的表述，下列哪一选项是错误的？（ ）

- A. 没有票据，就没有票据权利
- B. 任何类型的票据都必须能够进行转让
- C. 票据的效力不受票据赖以发生的原因行为的影响
- D. 票据行为的方式若存在瑕疵，不影响票据的效力

【答案】D

【解析】A项，票据具有设权性，票据权利的产生必须首先做成证券。在票据做成之前，票据权利是不存在的。票据权利是随着票据的做成同时发生的。没有票据，就没有票据权利。

B项，票据具有流通性，票据的一个基本功能就是流通。票据上的权利，经背书或单纯交付即可让与他人，无须依民法有关债权让与的有关规定。一般说来，无记名票据，可依单纯交付而转让；记名票据，须经背书交付才能转让。但是，并非所有的票据都能够转让，

《票据法》第27条第2款规定，出票人在汇票上记载“不得转让”字样的，汇票不得转让。

C项，票据是无因证券。票据法律关系是一种单纯的金钱支付关系，不受基础关系是否存在及其效力的影响。权利人享有票据权利只以持有符合票据法规定的有效票据为必要。至于票据赖以发生的原因则在所不问。即使原因关系无效或有瑕疵，均不影响票据的效力。即票据行为的原因行为不成立、无效或者被撤销，票据效力也不受影响。所以，票据权利人在行使票据权利时，无须证明给付原因，票据债务人也不得以原因关系对抗善意第三人。

D项，票据是要式证券，《票据法》严格地规定了票据的制作格式和记载事项。不按《票据法》及相关法规的规定进行票据事项的记载，就会影响票据的效力甚至会导致票据的无效。此外，在票据上所为的一切行为，如出票、背书、承兑、保证都必须严格按照《票据法》规定的程序与方式进行，否则会导致票据行为无效，甚至导致票据无效。如《票据法》第9条第2款规定，票据金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。

8. 关于支票的表述，下列选项正确的是（ ）。

- A. 张三签发的现金支票只能用于支取现金
- B. 李四信用良好，可以签发空头支票
- C. 王五签发的支票上另行记载付款日期，该支票无效
- D. 赵六签发的支票未记载收款人名称的，该支票无效

【答案】A

【解析】A项，《票据法》第83条第2款规定，支票中专门用于支取现金的，可以另行制作现金支票，现金支票只能用于支取现金。

B项，《票据法》第87条第1款的规定，支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额。由该规定可知，空头支票被禁止。

C项，《票据法》第90条的规定，支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。另行记载付款日期的，该记载无效。记载无效并非支票无效。

D项，《票据法》第86条第1款的规定，支票上未记载收款人名称的，经出票人授权，可以补记。

9. 根据《商业银行法》的规定，2018年商业银行与乙房地产公司进行的下列业务往来活动合法的是（ ）。

- A. 双方共同开发某经济特区的房地产项目，并成立丙项目公司
- B. 甲银行副行长兼任房地产公司副董事长，甲银行向丙项目公司投资1亿元
- C. 乙房地产公司以该公司的房地产作抵押，向甲商业银行提出贷款申请
- D. 甲商业银行经审核后，向乙公司发放了2亿元抵押贷款，该行当月资本余额为17.9亿元

【答案】C

【解析】AB两项，《商业银行法》第43条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

C项，《商业银行法》第40条规定，禁止向关系人发放信用贷款，但并不禁止向关系人发放担保贷款。只是发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

D项，《商业银行法》第39条规定，商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定：①资本充足率不得低于8%；②流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%；③对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%；④国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的其他规定。该商业银行向房地产开发公司发放2亿元人民币贷款已超过其资本余额的10%，违反了第③项的规定。

二、多项选择题

1. 甲公司给乙公司开了一张汇票，付款人为临海银行。乙公司向临海银行确认此票据有效，到期付款。乙公司随后将此票据背书转让给张某。张某遗失此汇票被刘某捡到，刘某仿造张某的签章，把汇票背书转让给丙公司履行其与丙公司的货款给付义务，丙公司按照约定向刘某交货，刘某收到货后将之转卖后携款潜逃。丙公司请求临海银行付款时，被告知经张某申请法院已经对此票据进行了除权判决。下列说法正确的有（ ）。

- A. 临海银行不应对丙公司承担付款责任
- B. 甲公司应对丙公司承担票据付款责任
- C. 乙公司不应对丙公司承担票据付款责任
- D. 刘某应对丙公司承担付款责任

【答案】A|C|D

【解析】ABC三项，《民事诉讼法》第229条规定，没有人申报的，人民法院应当根据申请人的申请，作出判决，宣告票据无效。判决应当公告，并通知支付人。自判决公告之日起，申请人有权向支付人请求支付。法院作出除权判决后，票据无效，不存在票据责任。

D项,《票据法》第14条第1款规定,票据上的记载事项应当真实,不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任。刘某实施过伪造签章的行为,虽然不承担票据责任,但毕竟刘某和丙公司之间存在买卖合同民事法律关系,丙公司已经交货给了刘某,按此买卖合同刘某应当承担给付货款的民事法律义务。

2. 东霖公司向忠谥公司购买一个元器件,应付价款960元。东霖公司为付款开出一张支票,因金额较小,财务人员不小心将票据金额仅填写了数码的“¥960元”,没有记载票据金额的中文大写。忠谥公司业务员也没细看,拿到支票后就放入文件袋。关于该支票,下列哪些选项是正确的?()

- A. 该支票出票行为无效
- B. 忠谥公司不享有票据权利
- C. 东霖公司应承担票据责任
- D. 该支票在使用前应补记票据金额的中文大写

【答案】CD

【解析】

《票据法》第84条规定,支票必须记载下列事项:①表明“支票”的字样;②无条件支付的委托;③确定的金额;④付款人名称;⑤出票日期;⑥出票人签章。支票上未记载前款规定事项之一的,支票无效。同时,《票据法》第85条规定,支票上的金额可以由出票人授权补记,未补记前的支票,不得使用。据此,欠缺票据金额并不会导致支票无效,只要在使用支票前补记金额即可。本题中,出票人因为疏忽,未记载票据金额的中文大写,使用之前补记中文大写即可,不影响支票的效力。

3. 甲公司为清偿对乙公司的欠款,开出一张收款人是乙公司财务部长李某的汇票。李某不慎将汇票丢失,王某拾得后在汇票上伪造了李某的签章,并将汇票背书转让给外地的丙公司,用来支付购买丙公司电缆的货款,王某收到电缆后转卖得款,之后不知所踪。关于本案,下列哪些说法是正确的?()

- A. 甲公司应当承担票据责任
- B. 李某不承担票据责任
- C. 王某应当承担票据责任
- D. 丙公司应当享有票据权利

【答案】A|B|D

【解析】A项，《票据法》第26条规定，出票人签发汇票后，即承担保证该汇票承兑和付款的责任。出票人在汇票得不到承兑或者付款时，应当向持票人清偿本法第70条、第71条规定的金额和费用。本题中，甲公司签发的票据合法有效，甲公司应当承担票据责任。

BC两项，《票据法》第14条第1款规定，票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。本题中，因为被假冒人李某并未在票据上签章，所以李某不承担票据责任。伪造人王某因为没有在票据上签章，所以王某不承担票据责任，但是王某仍需承担其他民事责任乃至刑事责任。

D项，《票据法》第14条第2、3款规定，票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同在变造之前签章。本题中，丙公司作为票据的合法持有人，享有票据权利。

4. 关于支票的表述，下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 现金支票在其正面注明后，可用于转账
- B. 支票出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额
- C. 支票上不得另行记载付款日期，否则该记载无效
- D. 支票上未记载收款人名称的，该支票无效

【答案】B|C

【解析】A项，《票据法》第83条规定，支票可以支取现金，也可以转账，用于转账时，应当在支票正面注明。支票中专门用于支取现金的，可以另行制作现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票中专门用于转账的，可以另行制作转账支票，转账支票只能用于转账，不得支取现金。由此可知，现金支票不得用于转账。

B项，要求票据基础关系的真实性是我国《票据法》的基本理念，《票据法》第87条规定，支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额。出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。禁止签发空头支票。

C项，《票据法》第90条规定，支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。另行记载付款日期的，该记载无效。

D项，《票据法》第86条第1款规定，支票上未记载收款人名称的，经出票人授权，可以补记。据此，收款人名称并非支票的必要记载事项，支票上未记载收款人名称并不会导致支票无效。

5. 甲向乙购买原材料，为支付货款，甲向乙出具金额为50万元的商业汇票一张，丙银行对该汇票进行了承兑。后乙不慎将该汇票丢失，被丁拾到。乙立即向付款人丙银行办理了挂失止付手续。下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 乙因丢失票据而确定性地丧失了票据权利
- B. 乙在遗失汇票后，可直接提起诉讼要求丙银行付款
- C. 如果丙银行向丁支付了票据上的款项，则丙应向乙承担赔偿责任
- D. 乙在通知挂失止付后十五日内，应向法院申请公示催告

【答案】B|C

【解析】A项，票据丢失之后，失票人可以通过挂失止付并申请公示催告来救济自己的票据权利，而并未丧失票据权利。《票据法》第15条第1款规定，票据丧失，失票人可以及时通知票据的付款人挂失止付，但是，未记载付款人或者无法确定付款人及其代理付款人的票据除外。

B项，丙银行已经对汇票进行了承兑，确定地负有票据义务，故乙可以起诉要求丙银行付款。

C项，《票据法》第15条第2款规定，收到挂失止付通知的付款人，应当暂停支付。本题中，乙在丢失票据后立即办理了挂失止付，如果丙银行向丁支付票款，则应当向乙承担赔偿责任。

D项，《票据法》第15条第3款规定，失票人应当在通知挂失止付后3日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。据此，乙应当在挂失止付后3日内申请公示催告。

三、不定项选择题

1. 下列情形中汇票的背书转让有效的是（ ）。

A. 出票人A公司将汇票背书给B公司，并记载“不得转让”字样，B公司再转让

B. 背书人C公司将票据背书给D公司后，但未记载背书日期

C. 汇票背书给甲委托收款后，甲又背书将票据权利转让给乙

D. 汇票金额分别转让给甲和乙

【答案】B

【解析】A项，《票据法》第27条规定，出票人在汇票上记载不得转让字样的，汇票不得转让。《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第52条规定，依照《票据法》第27条规定，出票人在票据上记载“不得转让”字样，其后手以此票据进行贴现、质押的，通过贴现、质押取得票据的持票人主张票据权利的，人民法院不予支持。

B项，《票据法》第29条规定，背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。

C项，《票据法》第35条规定，背书记载“委托收款”字样的，被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利。但是，被背书人不得再以背书转让汇票权利。

D项，《票据法》第33条规定，将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书无效。

四、概念题

1. 票据行为的无因性

【答案】

票据行为的无因性又称抽象性，是指票据行为只要具备法律规定的形式即自行产生效力，而不问其基于的原因关系或基础关系存在与否或是否有效。票据行为是依据其自身的要件产生效力的，而并不受到基础关系的影响，亦即票据关系与基础关系在法律上是互相分离的。

2. 票据的伪造与票据的变造

相关试题：

(1) 票据的变造[中国政法2020年研；天津师大2013年研；南京大学2005年研]

(2) 票据伪造与票据变造之比较。[简答题，武大2004年研]

【答案】(1) 票据的伪造，是指假冒他人的名义而实施的票据行为，包括假冒出票人的名义签发票据的行为，以及假冒他人名义而为的背书、承兑、保证等其他票据行为。

(2) 票据的变造，是指无变更权的人对票据上除签章以外的有关记载事项进行变更的行为。票据变造的条件包括：①必须是无变更权的人所为的变更行为；②必须是变更票据签章以外的其他事项；③变更票据其他记载事项足以引起票据权利内容发生变化。票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据变造之前或者之后签章的，视同在变造之前签章。

(3) 二者的相同点：伪造的票据和变造的票据都属于有瑕疵的票据，因此，票据伪造和票据变造都可能构成民事侵权行为、刑事犯罪行为 and 行政违法行为。

(4) 二者的区别：

①所针对的行为不同。票据的伪造必须针对签章，而票据的变造必须是变更票据签章以外的其他事项。

②效力不同。票据的伪造从一开始就是无效的，即使持票人是善意的，被伪造人和伪造人也不承担票据义务；票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。在票据的变造中，当事人签章在变造之前应按照原记载内容负责，在签章之后的则按变造后的记载内容负责；如果无法辨别变造时间，则视同在变造前签章。

3. 本票

【答案】

本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。本票具有以下特征①本票是票据的一种，也是完全有价证券、设权证券、无因证券、文义证券、金钱债权证券、流通证券、要式证券。②本票是由出票人自己对收款人支付并承担绝对付款责任的票据。③本票是出票人在到期日无条件支付票款的票据。

4. 支票

【答案】

支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票具有以下特征：①支票是票据的一种，具有一般票据的共同特征；②支票的付款人仅限于银行或其他金融机构；③支票是见票即付的票据；④支票的无因性受到一定的限制。

5. 空头支票

【答案】

空头支票是指支票的出票人在与付款人之间不存在资金关系的情况下签发的支票，或出票人超过资金关系中的约定范围签发的支票。我国法律禁止签发空头支票。

五、简答题

1. 简述商业银行的主要职能。

【答案】商业银行的主要职能有：

（1）信用中介职能

信用中介职能是指银行通过其负债业务，把社会上的各种闲散货币资金集中到银行里来，再通过资产业务把它投向经济各部门。它是商业银行的最基本职能。

（2）支付中介职能

支付中介职能是指商业银行利用其技术、网络、资源为客户代理收付、汇兑、转账等资金转移的功能。它是商业银行最初和最先具有

的职能，该职能和信用中介职能相互推进，构成商业银行借贷资本的整体运作。

（3）信用创造职能

信用创造职能指的是存款货币的创造，即存款货币的派生能力，是商业银行在信用中介职能和支付中介职能的基础上产生的一种派生职能。商业银行在吸收存款的基础上发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款可以转化为存款，在存款不提取的情况下，商业银行就增加了资金来源。最后在整个银行体系，形成数倍于原始存款的派生存款。这是商业银行区别于其他金融机构的重要特征。

（4）金融服务职能

金融服务职能是商业银行充当客户财务顾问，提供各种商情咨询、征信服务的职能。金融服务职能是在银行基本职能发展的基础上形成的。

（5）经济调节职能

调节经济是指商业银行通过其信用中介活动，调剂社会各部门的资金短缺，同时在人民银行货币政策和其他国家宏观政策的指引下，实现对经济结构、消费比例投资、产业结构等方面的调整。商业银行通过其在国际市场上的融资活动还可以调节本国的国际收支状况。

此外，作为重要的金融机构，商业银行在为客户进行风险识别和风险控制等方面也发挥着越来越重要的作用，成为商业银行的一项基本职能。

2. 简述票据行为的特征。

【答案】票据行为与一般的法律行为相比，具有以下特征：

（1）要式性

要式性，是指票据行为是一种严格的书面行为，应当依据票据法的规定，在票据上记载法定事项，票据行为人必须在票据上签章，其票据行为才能产生法律效力。票据行为的要式性有利于票据的安全流通。

（2）文义性

文义性，是指票据行为的内容均依票据上所载的文义而定。票据债务的具体内容完全以票据上记载的文义为准，即使该记载与实际情况不符，也不允许当事人以票据以外的证明方法加以变更或补充。这是票据要式性的具体表现。票据文义直接决定票据的权利和票据义务的范围和最高限度。

（3）无因性

无因性，又称抽象性或无因性，是指票据行为与作为其发生前提的基础关系（又称实质关系）相分离，从而使票据行为的效力不再受基础关系存在与否及效力瑕疵的影响。票据行为的无因性体现了票据法的技术性。票据行为的无因性是为了保障票据的流通性和安全性，适应商品经济活动的需要，而由票据法特别加以规定的。

（4）独立性

独立性，是指在同一票据上所作的各种票据行为互不影响，各自独立发生其法律效力。许多国家的票据法都确立了票据行为的独立原则，目的是保证票据的流通和社会交易的安全。

（5）连带性

连带性，是指同一票据上的各种票据行为人均对持票人承担连带责任。由于票据行为具有独立性和无因性，这就使持票人的权利实现受到影响，因此票据法规定了连带原则，以保护持票人的票据债权。

3. 简述票据权利及其特征。

【答案】（1）票据权利的概念

《票据法》第4条第4款规定：“本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。”

（2）票据权利的特征

①票据权利是一种金钱债权

这是由票据的金钱债权证券性质所决定的。其意义有二：

a. 票据权利是一种债权，即要求票据债务人为一定行为的请求权。票据权利的债权性质，决定了票据权利只能向特定的相对人行使。

b. 票据权利的内容是请求票据债务人支付票据金额，亦即权利的客体只能是一定数量的货币。

②票据权利是一种证券化权利

票据是完全有价证券，票据权利与证券不可分离，票据权利的发生、转移和行使，都以票据的存在为必要。票据权利的发生必须作成票据，票据权利的转移必须交付票据，票据权利的行使必须持有票据。由于票据权利是证券化权利，因此票据权利与票据所有权（即作为纸张的票据的所有权）是统一的。

③票据权利是一种无因性权利

这是由票据的无因性所决定的。权利人仅凭占有票据即享有票据权利，至于票据权利发生的原因或权利人取得票据的原因，从票据上

是看不出来的，权利人对此原因没有说明的义务，义务人也没有审查的权利。

④票据权利是一种两次性权利

权利人可以对两个以上的不同债务人行使两次请求权。第一次请求权是付款请求权，指票据权利人对票据主债务人或其他付款义务人请求支付票据金额的权利。第二次请求权是追索权，指票据权利人在付款请求权得不到实现时向付款人以外的票据债务人要求支付票据金额和其他有关费用的权利。

六、论述题

1. 试述出票的效力。

【答案】出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为。出票是最基本的、主要的票据行为，没有出票也就没有背书、承兑、保证等附属的票据行为。出票行为作为基本票据行为，一经完成即对汇票当事人产生票据法上的效力。具体表现在以下几方面：

（1）对出票人的效力

出票人必须对其签发的汇票获得承兑和获得付款承担担保责任。

①担保承兑，是指出票人保证其签发的汇票能够获得承兑，如果持票人在请求承兑时遭到拒绝，出票人就必须向持票人负偿还责任。

②担保付款，是指出票人保证持票人到期能够获得付款，如果汇票到期不获付款，出票人就必须向持票人负偿还责任。

出票人的这种担保承兑和担保付款责任，是票据法强行规定的绝对性义务。这种责任的存在与出票人是否具有担保的意思无关，出票人也不得通过在汇票上作有关记载来免除自己的担保责任。即使出票人在汇票上作了免除担保责任的记载，此项记载也视作未记载。

（2）对收款人的效力

出票人作成汇票并将汇票实际交付给收款人后，收款人便取得了汇票上的权利，包括付款请求权和追索权。不过，在付款人对汇票进行承兑之前，收款人的付款请求权尚处于不确定状态，仅仅是一种期待权。只有在付款人承兑以后，该期待权才成为现实权。此外，收款人行使追索权也必须符合一定的条件。

（3）对付款人的效力

出票人的出票行为是单方法律行为，出票行为一旦完成即产生法律效力，而无须由出票人与付款人之间达成合意。出票，包括在汇票上记载付款人的名称，因此出票也对付款人产生一定的法律效力。一

般说来，付款人因出票而取得一种地位或权限，即可以对汇票进行承兑。这即是说，付款人可以对汇票进行承兑，也可以不进行承兑。付款人是否要对汇票进行承兑，取决于其与出票人之间的约定，这一点在汇票上是看不出来的。付款人不对汇票作承兑的，他就不负任何付款义务。只有在付款人对汇票进行承兑后，才成为汇票的第一债务人，对收款人或持票人负绝对的付款义务。

2. 试析本票与汇票的异同。

【答案】本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票是由出票人签发的，要求付款人在见票时或在一定期限内，向收款人或持票人无条件支付一定款项的票据。

（1）本票与汇票的相同点

本票除了不具有承兑、拒绝承兑证明等特征外，其他各项制度与汇票均相同。我国《票据法》第80条也规定：“本票的背书、保证付款行为和追索权的行使，除本章规定外，适用本法第二章有关汇票的规定。本票的出票行为，除本章规定外，适用本法第24条关于汇票的规定。”

（2）本票与汇票的不同点

①本票是自付证券，汇票是委付证券。

②本票是出票人自己付款的承诺，汇票是出票人要求他人付款的委托或指示。

③本票无须承兑，汇票除见票即付的以外均可以或应当请求承兑。

④见票后定期付款的本票也无须承兑，而应当见票，见票后定期付款的汇票必须请求承兑，以确定汇票的到期日。

⑤本票的出票人始终是第一债务人，汇票在承兑以前不存在第一债务人，在承兑后付款人为第一债务人。

⑥在我国《票据法》中，本票仅指银行本票，而汇票包括银行汇票和商业汇票两种。

⑦本票仅限于见票即付，而汇票可以是见票即付、定日付款、出票后定期付款、见票后定期付款。

⑧本票的付款期限，自出票日起不得超过2个月，而汇票的付款期限无此特别限制。

七、案例分析题

1. A公司为支付所欠B公司货款，于1998年5月5日开出一张50万元的商业承兑汇票。B公司用此汇票进行背书转让给C公司，以购买一批原材料。但事后不久，B公司发现C公司根本无货可供，完全是一场骗局，于是马上通知付款人停止向C公司支付货款。C公司获此票据后，又将该票据背书转让给了D公司，以支付其所欠工程款。D公司用此汇票向E公司购买一批钢丝，背书时注明了“货到后此汇票方生效”。E公司于1998年7月5日向付款人请求付款。

付款人在对该汇票审查后拒绝付款，理由是：（1）C公司以欺诈行为从B公司获取票据的行为为无效票据行为，B公司已通知付款人停止付款；（2）该汇票未记载付款日期，且背书附有条件，为无效票据。随即付款人便作成退票理由书，交付于E公司。

问：

（1）付款人可否以C公司的欺诈行为为由拒绝向E公司支付票款？为什么？

（2）A公司开出的汇票未记载付款日期，是否为无效票据，为什么？

（3）D公司的背书是否有效？该条件是否影响汇票效力？

（4）E公司的付款请求权得不到实现时，可以向本案哪些当事人行使追索权？

【答案】（1）付款人不可以C公司的欺诈行为为由拒绝向E公司支付票款。

《票据法》第19条第1款规定：“汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。”出票人的出票行为是单方法律行为，出票行为一旦完成即产生法律效力。

根据票据行为的无因性，票据行为只要具备法律规定的形式要件即产生效力，而不问其基于的原因关系或基础关系是否存在或是否有效。所以，付款人不能以B与C公司之间作为基础关系的合同关系存在欺诈为由拒绝付款。

（2）A公司开出的汇票不因未记载付款日期而无效。

《票据法》第23条第1款规定：“汇票上记载付款日期、付款地、出票地等事项的，应当清楚、明确。汇票上未记载付款日期的，为见票即付。”这说明，出票人在出票时也应当在汇票上明确记载付款日期、付款地和出票地等事项，但如果未作记载，因为法律对此有补充规定，所以汇票并不因此而无效。

（3）D公司的背书有效，但所附条件无效，该条件不影响票据的

效力，视为未附条件。

《票据法》第33条第1款规定：“背书不得附有条件。背书附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。”

(4) E公司的付款请求权得不到实现时，可以向本案当事人A、B、C、D、付款人行使追索权。

汇票追索权，是指持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑或有其他法定原因时，在依法行使或保全了汇票权利后，向其前手请求偿还汇票金额、利息及其他法定款项的一种票据权利。《票据法》第61条第1款规定：“汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。”第68条第2款规定：“持票人不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。”

2. 甲市一个建筑公司因为基建工程资金不足，后期工程无法完成，欲向该市工商银行申请贷款600万元，但是该市工商银行资金困难，无法出货，乙市一家百货商场经理闻知，提出本市银行可以帮助解决资金问题。于是，建筑公司经理、工商银行行长以及信贷科长一行数人赶到乙市，约见该市工商银行行长以及商场经理。四方商量提出一个方案：先由建筑公司开出1000万元的银行承兑汇票，经甲市工商银行（以下称甲银行）承兑后，再由百货商场送交乙市工商银行（以下称乙银行）办理汇票贴现，所得1000万元，转汇甲银行600万元，贷给建筑公司使用，留下400万元留给商场使用。到期则由乙银行收回各方票款。甲银行当场开出两张汇票，一张600万元，一张400万元，汇票上均未填具交易合同号码和承兑契约编号。当天，乙银行即办理了票据贴现，次日则以百货商场名义转汇甲银行600万元，留下400万元冲抵了百货商场的债务。年底建筑公司如期偿还了600万元贷款的本息，甲银行也如期归还到百货商场，但是，百货商场无力归还400万元本息，汇票到期后甲银行拒绝付款。乙银行遂告甲银行，并将百货商场和建筑公司列为第三人。

问：

(1) 甲银行签发的无商品交易的银行承兑汇票是否有效？为什么？

(2) 甲银行有无权利拒绝付款？为什么？

(3) 如果汇票到期之前乙银行将该汇票背书后转让给了丙银行，甲银行能否拒绝丙银行的付款请求？为什么？

【答案】（1）甲银行签发的无商品交易的银行承兑汇票有效。

汇票具有无因性，票据行为只要具备法律规定的形式即自行产生效力，而不问其基于的原因关系或者基础关系存在与否或者是否有效。所以本题中甲银行签发的无商品交易的银行承兑汇票是有效的。

（2）甲银行有权拒绝付款。

甲银行与乙银行存在基础关系，同时甲银行已经如期履行其票据义务，因此不承担因百货商场的责任而导致的票据付款义务，并且这种抗辩具有直接性。

（3）甲银行无权拒绝丙银行的付款请求。

拒绝付款的事由须具有直接性，票据经过背书后，出票人不得间接对抗背书人的付款请求权。

第七章 保险法

一、单项选择题

1. 张三为中天公司调试某设备，双方约定，如果因张三的原因造成损失，张三只需要承担10%的赔偿责任。后来，中天公司为该设备投保损失险，未将与张三的约定告知保险公司，保险公司也未询问针对此设备有无免责约定。不久，张三在调试设备时因擅自修改设备参数，造成火灾，中天公司损失10万元。下列说法正确的是（ ）。

- A. 保险公司向中天公司赔偿后，可向张三追偿1万元
- B. 保险公司向中天公司赔偿后，可向张三追偿10万元
- C. 保险公司主张代位求偿的管辖法院，依保险合同关系确定
- D. 如果保险公司已经向中天公司赔偿，可向其主张返还赔偿金

【答案】A

【解析】AB两项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》（以下简称《保险法司法解释（四）》）第9条规定，在保险人以第三者为被告提起的代位求偿权之

诉中，第三者以被保险人在保险合同订立前已放弃对其请求赔偿的权利为由进行抗辩，人民法院认定上述放弃行为合法有效，保险人就相应部分主张行使代位求偿权的，人民法院不予支持。保险合同订立时，保险人就是否存在上述放弃情形提出询问，投保人未如实告知，导致保险人不能代位行使请求赔偿的权利，保险人请求返还相应保险金的，人民法院应予支持，但保险人知道或者应当知道上述情形仍同意承保的除外。本案中，中天公司在投保前对作为投保标的的机器设备豁免了张三90%的赔偿责任，该放弃合法有效，故张三只承担10%的赔偿责任，在保险公司赔偿后，向张三追偿，也只能追偿10%的赔偿责任。

C项，《保险法司法解释（四）》第12条规定，保险人以造成保险事故的第三者为被告提起代位求偿权之诉的，以被保险人与第三者之间的法律关系确定管辖法院。代位求偿诉讼的双方当事人是保险公

司和第三者，保险公司的权利承继自被保险人，所以诉讼争议原本是被保险人和第三者之间的关系，应按照被保险人和第三者之间的关系确定管辖法院。

D项，投保人告知的义务限于保险公司询问的范围和内容。保险公司在投保时未就免责事宜询问，中天公司没有告知的责任，所以不存在保险公司“被骗”的情形，保险公司不能主张中天公司返还已经支付的保险赔偿金。

2. 甲为自己投保一份以死亡为给付保险金的人身保险合同，在体检时发现自己患有不能承保的慢性疾病，保险公司业务员乙知情后仍然想办法为甲办理了该保险并收取了保费，受益人栏目中注明“法定”，未约定受益的顺序和份额。一年后，甲发病身亡，下列说法正确的有（ ）。

- A. 受益人约定为“法定”，该受益人的指定无效
- B. 保险赔偿金由甲的妻子和儿子平均分配
- C. 甲未履行如实告知的义务，保险公司可以解除合同
- D. 保险公司无须给付保险赔偿金

【答案】B

【解析】AB两项，《保险法司法解释（三）》第9条规定，投保人指定受益人未经被保险人同意的，人民法院应认定指定行为无效。当事人对保险合同约定的受益人存在争议，除投保人、被保险人在保险合同之外另有约定外，按以下情形处理：①受益人约定为“法定”或者“法定继承人”的，以民法典规定的法定继承人为受益人。②受益人仅约定为身份关系的，投保人与被保险人为同一主体时，根据保险事故发生时与被保险人的身份关系确定受益人；投保人与被保险人为不同主体时，根据保险合同成立时与被保险人的身份关系确定受益人。③约定的受益人包括姓名和身份关系，保险事故发生时身份关系发生变化的，认定为未指定受益人。因此，受益人约定为“法定”并非无效，而是按照《民法典》规定的法定继承人锁定为受益人，受益顺序和份额没有约定时，各受益人平均受益，因此由甲的妻子和儿子平均分配。

CD两项，《保险法》第16条第6款规定，保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险

事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。保险公司业务员乙属于保险公司代理人，甲隐瞒病情的事宜，乙知情等同于保险公司知情，发生保险事故时保险公司不能主张甲未如实告知而解除合同或不予赔偿，而是应依合同约定给付赔偿金。

3. 杨某为全家人投保了人身保险同时也为全部家庭财产投保了财产险，在两份保险合同的存续期间，保险公司在下列哪项情况下不享有解除保险合同的权利？（ ）

A. 杨某全家的人身保险合同中都是约定采用分期交纳保险费的方式，但是杨某在支付首期保险费后已超过合同约定的期限两年半未缴纳第2期的保险费的

B. 杨某的房屋在保险合同成立后，由于周边环境的改变，出现危险程度显著增加的情形

C. 财产保险中保险事故发生后杨某不积极进行施救的

D. 人身保险中杨某为其母亲申报的年龄不真实，合同成立3个月后保险公司发现被保险人杨某的母亲的真实年龄不符合合同约定的年龄限制

【答案】C

【解析】A项，《保险法》第37条第1款规定，合同效力依照本法第36条规定中止的，经保险人与投保人协商并达成协议，在投保人补交保险费后，合同效力恢复。但是，自合同效力中止之日起满2年双方未达成协议的，保险人有权解除合同。

B项，《保险法》第52条第1款规定，在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。

C项，《保险法》第57条规定，保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失。保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担；保险人所承担的数额在保险标的的损失赔偿金额以外另行计算，最高不超过保险金额的数额。可见，法律虽然要求保险事故发

生时被保险人尽力采取必要的措施防止或者减少损失，但是在这种情况下并未给予保险人解除合同的权利。

D项，《保险法》第32条第1款规定，投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值。保险人行使合同解除权，适用本法第16条第3款、第6款的规定。

4. 姜某的私家车投保商业车险，年保险费为3000元。姜某发现当网约车司机收入不错，便用手机软件接单载客。后辞职专门跑网约车。某晚，姜某载客途中与他人相撞，造成车损10万元。姜某向保险公司索赔，保险公司调查后拒赔。关于本案，下列哪一选项是正确的？
()

- A. 保险合同无效
- B. 姜某有权主张约定的保险金
- C. 保险公司不承担赔偿保险金的责任
- D. 保险公司有权解除保险合同并不退还保险费

【答案】C

【解析】AD两项，《保险法》第52条第1款规定，在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。据此，被保险人违反了保险标的危险程度增加的通知义务，保险公司有权解除合同，但不影响保险合同的效力。保险公司解除保险合同时，应当将超过保险合同期限部分的保险费退还给投保人。

BC两项，《保险法》第52条第2款规定，被保险人未履行前款规定的通知义务的，因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。本题中，姜某未履行通知义务，由此而发生的保险事故，保险公司不承担赔偿保险金的责任。

5. 杨某为其妻王某购买了某款人身保险，该保险除可获得分红外，还约定若王某意外死亡，则保险公司应当支付保险金20万元。关于该保

保险合同，下列哪一说法是正确的？（ ）

- A. 若合同成立2年后王某自杀，则保险公司不支付保险金
- B. 王某可让杨某代其在被保险人同意处签字
- C. 经王某口头同意，杨某即可将该保险单质押
- D. 若王某现为无民事行为能力人，则无须经其同意该保险合同即有效

【答案】B

【解析】A项，《保险法》第44条第1款规定，以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立或者合同效力恢复之日起2年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。本题中，如果王某在合同成立2年后自杀，保险公司应当支付保险金。

B项，《保险法》第34条第1款规定，以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。此处强调的“同意并认可保险金额”，被保险人既可以自己签字，也可以授权他人签字。

C项，《保险法》第34条第2款规定，按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或者质押。

D项，《保险法》第34条第3款规定，父母为其未成年子女投保的人身保险，不受本条第1款规定限制。据此，死亡保险必须经过被保险人同意只有父母为未成年人子女购买保险这一项例外情形，投保人为配偶购买死亡保险仍然要经过被保险人的同意。

6. 甲以自己为被保险人向某保险公司投保健康险，指定其子乙为受益人，保险公司承保并出具保单。两个月后，甲突发心脏病死亡。保险公司经调查发现，甲两年前曾做过心脏搭桥手术，但在填写投保单以及回答保险公司相关询问时，甲均未如实告知。对此，下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 因甲违反如实告知义务，故保险公司对甲可主张违约责任

- B. 保险公司有权解除保险合同
- C. 保险公司即使不解除保险合同，仍有权拒绝乙的保险金请求
- D. 保险公司虽可不必支付保险金，但须退还保险费

【答案】B

【解析】A项，《保险法》第16条第1款规定，订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。本题中，甲填写投保单以及回答保险公司相关询问时，均未如实告知心脏搭桥手术的事实，违反投保人告知义务。根据第16条第2、4、5款规定，甲违反告知义务，保险公司可以解除合同、不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不涉及主张违约责任的规定。

BC两项，《保险法》第16条第2款规定，投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。本题中，投保人甲故意或者因重大过失未告知心脏搭桥手术，保险公司可以解除保险合同。保险合同的解除是指在保险合同成立后，基于法定的或约定的事由，保险合同当事人行使解除权，从而使保险合同发生自始无效的后果的单方法律行为。保险合同在解除之前是合法有效的，如果保险公司不行使解除权，则仍要履行合同支付保险金。

D项，《保险法》第16条第5款规定，只有在投保人因为重大过失而未履行告知义务时，保险公司才需要退还保险费。本题中，题目没有明确说明投保人的主观意图，难以确定投保人甲属于因重大过失而未履行告知义务，更多的可能是其故意违反告知义务。

7. 甲公司将其财产向乙保险公司投保。因甲公司要向银行申请贷款，乙公司依甲公司指示将保险单直接交给银行。下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 因保险单未送达甲公司，保险合同不成立
- B. 如保险单与投保单内容不一致，则应以投保单为准
- C. 乙公司同意承保时，保险合同成立
- D. 如甲公司未缴纳保险费，则保险合同不成立

【答案】C

【解析】

《保险法》第13条第1款规定，投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证。保险合同为诺成合同，双方当事人意思表示一致合同即可成立，不以交付标的物为成立要件。本题中，乙公司同意承保，保险合同便已成立，保险费是否缴纳、保单是否送达不影响合同的成立。保险单为保险合同凭证，如保险单与投保单内容不一致，则应以保险单为准。

8. 甲向某保险公司投保人寿保险，指定其秘书乙为受益人。保险期间内，甲、乙因交通事故意外身亡，且不能确定死亡时间的先后。该起交通事故由事故责任人丙承担全部责任。现甲的继承人和乙的继承人均要求保险公司支付保险金。下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 保险金应全部交给甲的继承人
- B. 保险金应全部交给乙的继承人
- C. 保险金应由甲和乙的继承人平均分配
- D. 某保险公司承担保险责任后有权向丙追偿

【答案】A

【解析】ABC三项，《保险法》第42条规定，被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务：①没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；②受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的；③受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。即保险金应当作为被保险人甲的遗产。受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。即可以推定受益人乙先于被保险人甲死亡，且无其他受益人，此时其保险金应作为被保险人甲的遗产由甲的继承人继承。

D项，保险人的代位求偿权只在财产保险中存在，人身保险中不存在代位求偿权。《保险法》第46条规定，被保险人因第三者的行为

而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利，但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。

二、多项选择题

1. 老王给老婆投保了金额为20万元的人身保险，受益人是20岁的儿子小王，保险期限五年。后来老王做生意需要钱，遂准备将此保险合同退保，老婆和儿子都不同意。下列说法正确的有（ ）。

- A. 老王有权解除该保险合同
- B. 老婆不同意退保，老王不能解除此保险合同
- C. 儿子不同意退保，老王不能解除此保险合同
- D. 如果老婆向老王支付了相当于保单现金价值的款项，并通知了保险公司，此合同不能解除

【答案】A|D

【解析】《保险法司法解释（三）》第17条规定，投保人解除保险合同，当事人以其解除合同未经被保险人或者受益人同意为由主张解除行为无效的，人民法院不予支持，但被保险人或者受益人已向投保人支付相当于保险单现金价值的款项并通知保险人的除外。

ABC三项，保险合同的双方当事人是投保人和保险公司，基于自愿原则，投保人享有解除合同的法定权利，被保险人或受益人仅为保险合同的关系人，无法阻止当事人解除合同。

D项，但人身保险合同对被保险人或受益人意义很大，如果被保险人或受益人已经向投保人支付了相当于保单现金价值的款项并通知了保险公司，则保全了投保人想解除保险合同的经济利益，为了交易秩序的稳定及对被保险人或受益人的权益保障，此时保险合同不解除。

2. 甲公司投保了财产损失险的厂房被烧毁，甲公司伪造证明，夸大此次火灾的损失，向保险公司索赔100万元，保险公司为查清此事，花费

5万元。关于保险公司的权责，下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 应当向甲公司给付约定的保险金
- B. 有权向甲公司主张5万元花费损失
- C. 有权拒绝向甲公司给付保险金
- D. 有权解除与甲公司的保险合同

【答案】A|B

【解析】AC两项，《保险法》第27条第3款规定，保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任。据此，在投保人等夸大损失的情形，保险人对于夸大的部分不支付保险金，对于实际损失则需要按照约定支付保险金。

B项，《保险法》第27条第4款规定，投保人、被保险人或者受益人有前3款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

D项，《保险法》第16条规定，订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。

《保险法》第27条规定，未发生保险事故，被保险人或者受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除合同，并不退还保险费。《保险法》第32条规定，投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值。保险人行使合同解除权，适用本法第16条第3款、第6款的规定。据此，投保人夸大保险损失并非解除保险合同的事由。

3. 潘某请好友刘某观赏自己收藏的一件古玩，不料刘某一时大意致其落地摔毁。后得知，潘某已在甲保险公司就该古玩投保了不足额财产险。关于本案，下列哪些表述是正确的？（ ）

- A. 潘某可请求甲公司赔偿全部损失
- B. 若刘某已对潘某进行全部赔偿，则甲公司可拒绝向潘某支付保险赔偿金
- C. 甲公司对潘某赔偿保险金后，在向刘某行使保险代位求偿权时，既可以自己的名义，也可以潘某的名义
- D. 若甲公司支付的保险金不足以弥补潘某的全部损失，则就未取得赔偿的部分，潘某对刘某仍有赔偿请求权

【答案】B|D

【解析】A项，不足额保险合同，是指保险金额低于保险价值的合同。另据《保险法》第55条第4款的规定，保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿保险金的责任。本题中，潘某就自己的古玩所投保险为不足额保险，甲保险公司只需按照保险金额与保险价值的比例赔偿潘某的部分损失，而不需要赔偿潘某的全部损失。

B项，《保险法》第60条第2款规定，保险事故发生后，被保险人已经从第三者取得损害赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人从第三者已取得的赔偿金额。如果刘某已经对潘某进行了全部赔偿，则保险公司可以拒绝向潘某支付保险金。

C项，《保险法》第60条第1款规定，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。《保险法司法解释（二）》第16条第1款规定，保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。甲公司只能以自己的名义行使代位求偿权。

D项，《保险法》第60条第3款规定，保险人依照本条第一款规定行使代位请求赔偿的权利，不影响被保险人就未取得赔偿的部分向第三者请求赔偿的权利。甲公司支付的保险金不足以弥补潘某的全部损失，则就未取得赔偿的部分，潘某对刘某仍有赔偿请求权。

4. 甲公司交纳保险费为其员工张某投保人身保险，投保单由保险公司业务员代为填写和签字。保险期间内，张某找到租用甲公司槽罐车的李某催要租金。李某与张某发生争执，张某打碎车窗玻璃，并挡在槽罐车前。李某怒将张某撞死。关于保险受益人针对保险公司的索赔理由的表述，下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 投保单虽是保险公司业务员代为填写和签字，但甲公司交纳了保险费，因此保险合同成立
- B. 张某的行为不构成犯罪，保险公司不得以此为由主张免责
- C. 张某的行为属于合法的自助行为，保险公司应予以理赔
- D. 张某的死亡与张某的行为并无直接因果关系，保险公司应予以理赔

【答案】A|B|D

【解析】A项，《保险法》第13条第1款规定，投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。本题中，保险单尽管是由保险公司的业务员代为填写，但投保人成功缴纳了保险费，应视为保险已同意承保，所以保险合同成立。

BD两项，《保险法》第45条规定，因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。本题中，张某的行为不属于故意犯罪，其死亡是由于第三人李某的故意杀害行为所致，与其本身的行为并无直接因果关系，保险公司应予以理赔。

C项，自助行为是指权利人受到不法侵害之后，为保全或者恢复自己的权利，在情势紧迫而不能及时请求国家机关予以救助的情况下，依靠自己的力量对他人的财产或自由施加扣押、拘束或其他相应措施的行为。张某本身没有受到不法侵害，其行为自然也不属于合法的自助行为。

5. 甲为其妻乙投保意外伤害保险，指定其子丙为受益人。对此，下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 甲指定受益人时须经乙同意
- B. 如因第三人导致乙死亡，保险公司承担保险金赔付责任后有权向该第三人代位求偿
- C. 如乙变更受益人无须甲同意
- D. 如丙先于乙死亡，则出现保险事故时保险金作为乙的遗产由甲继承

【答案】A|C|D

【解析】A项，《保险法》第39条规定，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人。被保险人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。本题中，甲为乙投保，指定第三人丙为受益人，须经乙同意。

B项，《保险法》第46条规定，被保险人因第三者的行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利，但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。故如因第三人导致乙死亡，保险公司承担保险金赔付责任后无权向该第三人代位求偿。

C项，《保险法》第41条规定，被保险人或者投保人可以变更受益人并书面通知保险人。保险人收到变更受益人的书面通知后，应当在保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单。投保人变更受益人时须经被保险人同意。投保人指定及变更受益人均须经被保险人同意，而被保险人指定或变更受益人不存在道德风险问题，所以不需经投保人同意。

D项，《保险法》第42条规定，被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务：①没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；②受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的；③受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。本题中，受益人丙先于被保险人乙死亡，保险金应作为乙的遗产由法定继承人继承，甲作为乙的配偶，是第一顺序法定继承人。

6. 保险法中的保险利益原则是指投保人应当对保险标的具有法律上承认的利益，否则会导致保险合同无效。下列哪些选项符合保险利益原则？（ ）

A. 甲经同事乙同意，为其购买一份人寿险

B. 丙为自己刚出生一个月的孩子购买一份人身险

C. 丁公司为其经营管理的风景区内的一颗巨型钟乳石投保一份财产险

D. 戊公司为其一座已经投保的仓库再投保一份财产险

【答案】A|B|C|D

【解析】保险利益原则是《保险法》的基本原则之一，其基本内容是投保人应对保险标的具有保险利益，否则，不具有成为投保人、订立保险合同的资格，即使订立了合同，该合同也不具有法律效力，保险人不负赔偿或给付责任。财产保险合同和人身保险合同中判断保险利益是否存在的规则不相同。保险利益原则的根本目的在于防止道德风险的发生，从而更好地实现保险“分散危险和消化损失”的功能。

AB两项，《保险法》第31条规定，投保人对下列人员具有保险利益：①本人；②配偶、子女、父母；③前项以外与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成员、近亲属；④与投保人有劳动关系的劳动者。除前款规定外，被保险人同意投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。订立合同时，投保人对被保险人不具有保险利益的，合同无效。乙虽然仅是甲的同事，但是乙同意甲为其投保，甲对乙则具有保险利益。而丙对自己的孩子同样具有保险利益。

C项，财产保险合同中，投保人对自己所有或者经营管理的财产或者与其有利害关系的他人的财产具有保险利益。丁公司对其经营管理的钟乳石具有保险利益。

D项，《保险法》第56条规定，重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。重复保险的投保人可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费。重复保险是指投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，且保险金额总和超过保险价值的保险。因此，只要具有保险利益，法律并不禁止重复投保，戊公司有权重复投保。

7. 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》（以下简称《保险法司法解释（四）》），下列说法正确的是（ ）。

A. 保险人已向投保人履行了保险法规定的提示和明确说明义务，保险标的受让人以保险标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由，主张免除保险人责任的条款不生效的，人民法院不予支持

B. 保险人已向投保人履行了保险法规定的提示和明确说明义务，保险标的受让人以保险标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由，主张免除保险人责任的条款不生效的，人民法院应予支持

C. 被保险人死亡，继承保险标的的当事人主张承继被保险人的权利和义务的，人民法院应予支持

D. 被保险人死亡，继承保险标的的当事人主张承继被保险人的权利和义务的，人民法院不予支持

【答案】A|C

【解析】AB两项，《保险法司法解释（四）》第2条规定，保险人已向投保人履行了保险法规定的提示和明确说明义务，保险标的受让人以保险标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由，主张免除保险人责任的条款不生效的，人民法院不予支持。

CD两项，《保险法司法解释（四）》第3条规定，被保险人死亡，继承保险标的的当事人主张承继被保险人的权利和义务的，人民法院应予支持。

三、不定项选择题

1. 张某与甲保险公司签订了财产保险合同，为自己的轿车投保了财产险，轿车的保险价值为20万元，保险金额为10万元，与乙保险公司签订了人身保险合同，为自己投保了意外伤害险，保险金额为10万元，某日张某驾车出行时与一横穿马路的卡车相撞，张某被撞伤致残，轿车被严重撞毁，经鉴定，轿车的价值损失了80%，甲保险公司向张某赔偿了8万元，乙保险公司向张某赔偿了7万元，以下说法正确的是（ ）。

A. 甲保险公司向张某赔偿后，可以要求肇事者向自己赔偿8万元

B. 乙保险公司向张某赔偿后，可以要求肇事者向自己赔偿7万元

- C. 甲保险公司向张某赔偿后，张某有权要求肇事者赔偿2万元
- D. 乙保险公司向张某赔偿后，张某有权要求肇事者按照民法的规定足额赔偿自己的人身损害

【答案】A|C|D

【解析】A项，《保险法》第60条规定，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。前款规定的保险事故发生后，被保险人已经从第三者取得损害赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人从第三者已取得的赔偿金额。保险人依照本条第一款规定行使代位请求赔偿的权利，不影响被保险人就未取得赔偿的部分向第三者请求赔偿的权利。本题中，甲保险公司向被保险人赔偿保险金后，在赔偿金额范围内有权代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利，即甲保险公司有权在8万元的范围内行使代位求偿权。

B项，代位求偿权是财产保险中的制度，人身保险中没有代位求偿权制度。乙保险公司承担了赔偿责任后，无权向第三者追偿。

C项，张某的损失并未被保险金完全填补，仍有2万元的部分未获得赔偿，因此张某有权在2万元的范围内要求肇事者赔偿。

D项，人身保险中，保险人支付了赔偿或者保险金后，被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。本题中，保险公司虽然支付了赔偿，张某仍有权要求肇事者足额赔偿。

2. 某个体企业主张金柱欲为其62岁的母亲图雅、8岁的女儿张玉以及在其企业工作的员工28岁的司机罗帆投保意外伤害险。为此，他向保险公司详细询问了有关意外伤害保险的具体条件，并与保险公司签订了3份人身保险合同。

1). 有关该3份保险合同签订的下列说法正确的是（ ）。

- A. 张金柱有权为上述三人投保人身意外伤害保险
- B. 张金柱有权为上述三人指定受益人（经上述三人同意后）
- C. 张金柱可以在签订上述合同时依法指定自己为受益人

D. 设张金柱签订的上述格式合同中具有排除其作为投保方依法享有的权利的条款，则如保险公司未在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人张金柱注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人张金柱作出明确说明的，该条款不产生效力

【答案】A

【解析】A项，《保险法》第31条规定，投保人对下列人员具有保险利益：①本人；②配偶、子女、父母；③前项以外与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成员、近亲属；④与投保人有劳动关系的劳动者。除前款规定外，被保险人同意投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。订立合同时，投保人对被保险人不具有保险利益的，合同无效。

BC两项，第39条规定，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人。被保险人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

D项，第17条规定，订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

2). 在张某为其母亲图雅投保的合同中，具有下列情形，正确的说法是（ ）。

A. 设某险种要求被保险人年龄在60周岁之下方能投保，张某谎称母亲图雅的年龄为52岁而入保，则保险公司有权解除合同

B. 设某险种要求被保险人年龄在60周岁之下方能投保，张某谎称母亲图雅的年龄为52岁而入保，则保险公司也可以要求张某增加保费而保留合同

C. 如图雅罹患老年痴呆症而成为无民事行为能力人，则张某不能为其投保以死亡为给付保险金条件的人身保险合同

D. 如图雅罹患老年痴呆症而成为限制民事行为能力人，张某依然有权为其投保任何人身保险合同

【答案】A|C|D

【解析】AB两项，《保险法》第32条规定，投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值。保险人行使合同解除权，适用本法第16条第3款、第6款的规定。投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人支付的保险费少于应付保险费的，保险人有权更正并要求投保人补交保险费，或者在给付保险金时按照实付保险费与应付保险费的比例支付。投保人申报的被保险人年龄不真实，致使投保人支付的保险费多于应付保险费的，保险人应当将多收的保险费退还投保人。

CD两项，第33条规定，投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保。父母为其未成年子女投保的人身保险，不受前款规定限制。但是，因被保险人死亡给付的保险金总和不得超过国务院保险监督管理机构规定的限额。

3). 张金柱为其女张玉签订了以死亡为给付保险金条件的人身保险合同，并且约定分期支付保险费，每年女儿生日5月10日到来时支付当年保费。对于该合同下列说法正确的是（ ）。

A. 该合同不得转让

B. 该合同无须张玉同意，即可以转让

C. 如果张某于2010年7月14日仍未支付当年保费，则合同的效力依法中止

D. 如张某破产，至2011年5月8日仍未缴付去年和今年的保费，则保险人有权解除合同

【答案】A

【解析】AB两项，《保险法》第34条规定，以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同

意，不得转让或者质押。父母为其未成年子女投保的人身保险，不受本条第1款规定限制。

CD两项，第36条规定，合同约定分期支付保险费，投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人自保险人催告之日起超过30日未支付当期保险费，或者超过约定的期限60日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。被保险人在前款规定期限内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。

4). 张金柱为其企业员工罗帆签订了以死亡为给付保险金条件的人身保险合同，有关该合同的说法正确的是（ ）。

- A. 因罗帆为张某企业员工，故该合同无须经过罗帆本人同意并认可保险金额
- B. 该合同经过罗帆本人的书面同意，可以质押
- C. 张某可以未经罗帆同意而指定罗帆的妻子和儿子为受益人
- D. 罗帆跳槽到其他单位，张某有权解除该保险合同

【答案】B|D

【解析】AB两项，《保险法》第34条规定，以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或者质押。父母为其未成年子女投保的人身保险，不受本条第1款规定限制。

C项，第39条规定，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人。被保险人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。可见，只有被保险人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的情形下方不经同意。

D项，商业保险合同并无强制性，投保人当然有权依据自己的意愿解除其投保的合同。

5). 有关张金柱为其企业员工罗帆签订的以死亡为给付保险金条件的人身保险合同，下列说法正确的是（ ）。

- A. 张金柱须一次性支付罗帆保险合同的全部保费
- B. 罗帆妻子与罗帆离婚，张金柱即直接将合同受益人变更为罗帆父亲和儿子
- C. 设合同签订一年后，罗帆因感情问题精神分裂为无行为能力人，后自杀，则保险公司应当赔偿保险金
- D. 若合同签订1年半之后，罗帆因交通肇事罪而重伤死亡，如无其他情形，则保险人应当承担给付保险金的责任

【答案】C|D

【解析】A项，《保险法》第35条规定，投保人可以按照合同约定向保险人1次支付全部保险费或者分期支付保险费。

B项，第41条规定，被保险人或者投保人变更受益人并书面通知保险人。保险人收到变更受益人的书面通知后，应当在保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单。投保人变更受益人时须经被保险人同意。

C项，第44条规定，以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立或者合同效力恢复之日起2年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。保险人依照前款规定不承担给付保险金责任的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

D项，第45条规定，因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足2年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。交通肇事罪属于过失犯罪，保险人应当承担给付保险金的责任。

6). 有关上述合同履行过程中出现了下列情形，则说法正确的是（ ）。

- A. 设图雅外出散步，因李大壮酒后驾车肇事而致图雅死亡，则张某有权要求保险公司和李大壮都承担赔偿责任

B. 设张玉因飞机失事，意外死亡，张金柱悲伤过度，沉沦数年，飞机失事3年后欲向保险人要求赔偿保险金，则保险公司有权拒绝张玉死亡的赔偿保险金

C. 设张某因罗帆消极怠工，拒付其保险合同的保险费，则罗帆有权起诉要求张某支付该保费给保险公司

D. 如张金柱意外死亡，则上述3份合同效力自动终止

【答案】A|C

【解析】A项，《保险法》第46条规定，被保险人因第三者的行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利，但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。人身保险合同保险人无代位求偿权。

B项，《保险法》第26条规定，人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人，向保险人请求赔偿或者给付保险金的诉讼时效期间为2年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为5年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

C项，第38条规定，保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。员工不在限制之列，具有诉权。

D项，《保险法》并未规定投保人死亡，其投保的人身保险合同效力终止，其相关效力仍应依据相关缴付保费的法律规定来处理。

3. 齐某给自己家的冰箱投了全额火灾险，某日邻居常某不慎将其冰箱焚毁，对于本案以下说法正确的是（ ）。

A. 齐某如果放弃对常某的赔偿请求，保险公司可以对齐某拒绝赔偿

B. 齐某如果向保险公司索赔后放弃对常某的赔偿请求，该弃权无效

C. 如果齐某投的是不足额保险，那么他向保险公司索赔后可以就未获得赔偿的部分向常某再索赔

D. 如果常某是齐某的家庭成员，则保险公司对齐某赔偿后不能对常某进行追偿

【答案】A|B|C

【解析】AB两项，《保险法》第61条规定，保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利的，保险人不承担赔偿保险金的责任。保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对第三者请求赔偿的权利的，该行为无效。本题中，齐某如果放弃对常某的赔偿请求，保险公司可以对齐某拒绝赔偿；齐某如果向保险公司索赔后放弃对常某的赔偿请求，该弃权无效。

CD两项，《保险法》第62条规定，除被保险人的家庭成员或者其组成人员故意造成本法第60条第1款规定的保险事故外，保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。因此C项符合代位求偿的原理。D项说法过于绝对，如果常某故意损毁冰箱，则保险公司赔偿以后有权利向其追偿。

四、概念题

1. 近因原则

【答案】

近因原则，又称因果关系，是指保险事故的发生与损失结果的形成存在直接的因果关系，且保险事故发生原因属承保风险范围时，保险人才承担保险责任。所谓近因，系英美法概念，而非时间上最近的原因，指对造成损失起决定性、能动性和有效性作用的关键原因。近因原则是处理复杂因果关系保险案件时法律上通常采用的评判规则，对于防止保险责任的无限扩大及推卸具有重要意义。

2. 人身保险与人寿保险

【答案】（1）人身保险，是指以人的身体和生命作为保险标的的保险。人身保险的保险人在被保险人投保后，根据约定在被保险人因保单载明的意外事故、灾难及衰老等原因而发生死亡、疾病、伤残、丧失工作能力或退休等情形时给付一定的保险金额或年金。

（2）人寿保险，是指以人的生命为保险标的，以被保险人的生存、死亡或生存死亡两全为保险金给付条件的人身保险，又可分为生存保险、死亡保险和生存死亡两全保险等。

(3) 人身保险是人寿保险的上位概念，人身保险包括但不限于人寿保险，除此之外还包括人身意外伤害保险、健康保险等；人寿保险是人身保险的最主要、最基本的种类，在人身保险业务中占绝大部分份额。

3. 再保险

【答案】

再保险，是指保险人将其承担的保险业务，以分保形式部分转移给其他保险人的行为。根据不同的标准，再保险可以划分为不同的类型。按责任限制分类，其可分为比例再保险和非比例再保险；按照安排方式分类，再保险可以分为临时再保险、合约再保险和预约再保险。

4. 保险代理人与保险经纪人

【答案】(1) 保险代理人是指向保险人收取代理费用，根据保险人的委托在保险人授权的范围内代为办理招揽与接受业务、收取保险费、勘查业务、签发保单、审核赔款等保险业务的单位或个人。

(2) 保险经纪人，是指基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。

(3) 二者的区别有：

①保险经纪人代表的是投保人的利益；保险代理人代表的是保险人的利益。

②保险经纪人的行为后果由保险经纪人自身承担；保险代理人代理行为的后果由保险人承担。

③保险经纪人可以向投保人和保险人双方收取佣金；保险代理人只能向保险人收取代理佣金。

五、简答题

1. 简述保险的种类。

【答案】依据不同的标准，保险可以划分为不同的种类。

(1) 以保险标的为标准，可以分为人身保险与财产保险。

①人身保险，是指以人的身体和生命作为保险标的的保险。

②财产保险，是指以补偿被保险人的经济损失为基本目的，以特定的财产物资及其相关利益为承保标的的保险。

(2) 以保险实施形式为标准，可以分为强制保险与自愿保险。

①强制保险，又称为法定保险，是指根据国家颁布的有关法律和法规，凡是在规定范围内的单位或个人，无论出于自愿都必须参加的保险。如机动车第三者责任保险。

②自愿保险，是指在自愿原则下，投保人与保险人双方在平等协商的基础上，通过订立保险合同而建立的保险关系。

(3) 以承担责任的次序为标准，可以分为原保险与再保险。

①原保险，是指保险人与投保人之间直接签订保险合同而建立保险关系的一种保险。

②再保险，是指保险人将其承担的保险责任中的一部分转移给其他保险人承保的保险。

(4) 以保险标的的保险价值在投保时是否确定为标准，可以分为定值保险与不定值保险。

①定值保险，是指保险合同双方当事人事先确定保险标的的价值，并在合同中载明以确定保险金最高限额的财产保险。

②不定值保险，是指双方当事人在订立合同时只列明保险金额，不预先确定保险标的的价值，须至危险事故发生后，另行确定保险价值而确定其损失的保险。

(5) 以给付保险金的目的为标准，可以分为补偿性保险与给付性保险。

①补偿性保险，是指保险人所给付的保险金的目的在于补偿被保险人因保险事故所受实际损失的保险。财产保险属于补偿性保险。

②给付性保险不以补偿损失为目的。大多数人身保险都属于给付性保险。

(6) 以保险金额与保险价值的关系为标准，可以分为足额保险、不足额保险与超额保险。

①足额保险，又称全额保险，是指保险金额等于或大体相当于保险价值的保险。

②不足额保险，又称低额保险，是指保险金额低于保险价值的保险。

③超额保险，是指保险金额大于财产价值的保险。

(7) 以保险标的的数量状况为标准，可以分为个别保险、集合保险与总括保险。

①个别保险，又称单独保险，是指以一人或者以一物为保险标的的保险。多数保险都属于个别保险。

②集合保险，是指集合多数性质相似的保险标的而订立一个保险。

③总括保险，又称“统保单”，是指无特定保险标的，仅按一定标

准所限定的可以变动的多数人或者物的集体为标的的保险。

(8) 以保险人的情况为标准, 可以分为单保险与复保险。

①单保险, 是指投保人对同一保险标的就同一保险利益、同一保险事故、同一保险期间与一个保险人订立的保险。

②复保险, 又称重复保险, 是指投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同, 且保险金额总和超过保险价值的保险。

2. 保险合同的无效原因。

【答案】(1) 保险合同的无效, 是指已经订立的保险合同因违反国家法律、法规的规定或其他原因, 在法律上自始不发生效力的情形。

根据无效的程度和范围, 保险合同无效可分为全部无效和部分无效两种情况。全部无效是指保险合同全部不发生效力; 部分无效是指保险合同的某些条款虽然违反法律规定, 但并不影响其他条款的法律效力。

(2) 导致保险合同无效的要件, 原则上可以适用我国《民法典》中关于无效合同的规定。除此之外, 可导致保险合同无效的情形还有:

①投保人对保险标的无保险利益。

②投保人为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的保险, 但法律另有规定的除外。

③以死亡为给付保险金条件的合同, 未经被保险人书面同意并认可保险金额的, 但法律另有规定的除外。

④恶意的复保险(我国《保险法》未作此规定)。

六、论述题

1. 论保险法的基本原则。

【答案】保险法的基本原则包括:

(1) 最大诚信原则

最大诚信原则, 是指保险合同当事人必须充分而准确地向对方告知有关保险的所有重要事实, 不允许存在任何虚构、欺骗、隐瞒行为的原则。

①如实告知义务

a. 如实告知义务, 又称据实说明义务、如实披露义务, 是指投保

人在订立保险合同过程中，对保险人的询问所作陈述应当全面、真实、客观，不得隐瞒或者故意不回答，也不得编造虚假情况来欺骗保险人。

b. 投保人所应如实告知的重要事实通常包括以下四个方面的内容：第一，足以使被保险人危险增加的事实；第二，为特殊动机而投保的，有关该动机的事实；第三，表明被保险危险特殊性质的事实；第四，显示投保人在某方面非正常的事实。

c. 违反如实告知义务的法律后果

第一，投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。

第二，投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。

第三，投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但应当退还保险费。

②信守保证义务

保证，指投保人或被保险人对某些特定事项如为一定行为、不为一定行为或某特定事项的真实性向保险人所作的担保。保证分为明示保证和默示保证。

③条款说明义务

条款说明义务，是指保险人应当就保险合同利害关系条款特别是免责条款向被保险人明确说明的义务。

④不可抗辩规则

不可抗辩规则，又称不可抗辩条款，是指保险合同自生效之日起经过一段时间（一般为2年），就成为不可争议的文件，保险人就不得以投保人在订立保险合同时违反诚实信用原则、未履行如实告知义务为由而主张合同无效并拒绝赔偿保险金。

（2）保险利益原则

①保险利益原则的含义

保险利益原则，是指只有具有保险利益的保险行为才具有法律效力。保险利益，又称可保利益，是指投保人或者被保险人对保险标的具有的法律上承认的利益。

②人身保险的保险利益

《保险法》第31条规定，投保人对下列人员具有保险利益：a. 本人；b. 配偶、子女、父母；c. 前项以外与投保人有抚养、赡养或者

扶养关系的家庭其他成员、近亲属；d. 与投保人有劳动关系的劳动者。此外，被保险人同意投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。

③财产保险的保险利益

财产保险的保险利益的要素如下：a. 财产保险的保险利益是法律上认可的利益；b. 财产保险的保险利益必须为经济上的利益，即必须是可以用金钱估算的利益；c. 财产保险的保险利益必须是能够确定的利益。

（3）损失补偿原则

损失补偿原则，是指被保险人在保险合同约定的保险事故发生后所受实际损失，保险人应在其责任范围内进行充分补偿。

（4）近因原则

近因是指造成保险标的损害的最直接、最有效的起主导作用或支配性作用的原因。

近因原则，是指危险事故的发生与损失结果的形成，须有直接的因果关系，保险人才对发生的损失负赔偿责任。

2. 试述我国对保险公司设立及监管的主要规定。

【答案】对于保险公司的设立，根据《保险法》规定，保险公司应当采取以下形式：股份有限公司和国有独资公司。

（1）根据《保险法》的规定，设立保险公司应当具备下列条件：

①有符合保险法和公司法规定的章程。

②有符合保险法规定的注册资本最低限额。《保险法》规定，保险公司的最低注册资本额为2亿元人民币，而且必须为实缴货币资本。在保险公司设立后，保险监督管理部门可以根据保险公司的业务范围、经营规模调整其注册资本的最低限额，但不得低于2亿元人民币的法定限额。

③有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员。对此，我国保险监督管理机构规定，保险公司的高级管理人员必须具有符合规定的学历和资历且无经营管理不善而致使公司亏损、破产的记录。此外还规定，保险公司的主要负责人不得由公务员担任，保险公司的法定代表人不得由离、退休人员担任。

④有健全的组织机构和管理制度。国有独资保险公司的组织机构包括董事会和监事会，股份有限保险公司的组织机构包括股东会、董事会和监事会。不论是国有独资保险公司还是股份有限保险公司都应建立再保险制度、工作制度、工资分配制度、保险营销制度等完备的

规章制度，以保证保险业务的正常营运。

⑤有符合要求的营业场所和与业务有关的其他设施。

(2)《保险法》规定，申请设立保险公司，应当提交下列文件、资料以供初步审查：

①设立申请书。设立申请书应当注明拟设立保险公司的名称、注册资本、业务范围等内容。

②可行性研究报告。可行性研究报告目的在于论证设立保险公司的可行性，主要内容是对保险市场整体状况、拟设立保险公司的业务开展预计进行全面分析。

③保险监督管理部门规定的其他文件、资料，如投资者背景材料、筹建负责人的简历、筹建方案等。

(3)金融监督管理部门对设立保险公司的申请进行初步审查认为合格后，应通知申请人依照《保险法》和《公司法》的规定进行保险公司的筹建。具备设立保险公司条件的，保险人应向保险监督管理部门提交正式申请表和下列有关文件、资料：①保险公司的章程；②股东名册及其股份或者出资人及其出资额；③持有公司股份10%以上的股东的资信证明和有关资料；④法定验资机构出具的验资证明；⑤拟任职的高级管理人员的简历和资格证明；⑥经营方针和计划；⑦营业场所和与业务有关的其他设施的资料；⑧保险监管机构规定的其他文件、资料。保险监管机构自收到设立保险公司的正式申请文件之日起6个月内，应当作出批准或者不批准的决定。经批准设立的保险公司，由批准部门颁发经营保险业务许可证，并凭经营保险业务许可证向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照。保险公司自取得经营保险业务许可证之日6个月内无正当理由未办理公司设立登记的，其经营保险业务许可证自动失效。此外，对于保险公司在我国境内外设立分支机构，根据《保险法》的专门规定，应经保险监督管理机构批准，取得分支机构经营保险业务许可证；保险公司分支机构不具有法人资格，其民事责任由保险公司承担。保险公司在我国境内外设立子公司、分支机构，须经保险监督管理机构批准。

七、案例分析题

1. 王明杰与妻子赵世琴以及女儿王媛媛为三口之家。某日，王明杰以自己为被保险人向某人寿保险公司投保了死亡保险，但在投保时并未指定保险金受益人。

(1) 假设王明杰突患重病并经抢救无效死亡，试问：赵世琴与王媛媛谁具有保险金请求权？若王明杰生前曾向其友赵某借款，试问：

赵某是否能够以债权人的名义申请对保险金请求权进行扣押。

(2) 假设王明杰因抢劫银行，并与围捕其之警察发生枪战，最后被枪毙身亡。试问：保险公司是否应当承担给付保险金的责任？

(3) 假设王明杰与赵世琴因家庭纠纷而发生口角，王明杰因一时想不通而服毒自杀。试问：保险公司是否应当承担给付保险金的责任？

(4) 假设王明杰在投保时指定妻子赵世琴与女儿王媛媛为保险金受益人。合同生效后的某日，王明杰与赵世琴，因家庭纠纷而发生口角，争执过程中，王明杰被赵世琴用菜刀砍成重伤，在送往医院的途中死亡。赵世琴因故意伤人被公安部门逮捕。试问：此时，赵世琴是否享有保险金请求权？其女儿是否享有保险金请求权？[南京大学2007年研]

【答案】(1) 被保险人死亡后，没有指定受益人的，保险金作为被保险人的遗产，赵世琴和王媛媛作为第一顺位继承人，均具有保险金请求权。

赵某可以以债权人的名义申请对保险金请求权进行扣押，根据《民法典》的规定，继承人应以被继承人的财产为限，清偿被继承人的债务。

(2) 保险公司不应承担给付保险金的责任。《保险法》第45条规定，因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足二年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

(3) 以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立或者合同效力恢复之日起二年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任。如果王明杰在保险合同成立或合同效力恢复之日起二年内自杀，保险公司不承担给付保险金的义务，如果超过二年，则保险公司应承担给付保险金的责任。

(4) 赵世琴不享有保险金请求权，其女儿享有保险金请求权。

《保险法》第43条规定，受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

第八章 证券法

一、单项选择题

1. 下列关于内幕信息知情人的说法，错误的是（ ）。

- A. 由于法定职责对证券发行、交易进行管理的人员属于内幕信息知情人
- B. 一般情况下，上市公司实际控制人的高级管理人员不属于内幕信息知情人
- C. 一般情况下，持有公司股份比例不到5%的股东不属于内幕信息知情人
- D. 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员属于内幕信息知情人

【答案】B

【解析】

根据《证券法》规定，证券交易内幕信息知情人包括：①发行人的董事、监事、高级管理人员；②持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；③发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；④由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；⑤上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；⑥因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；⑦因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；⑧因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；⑨国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

2. 下列（ ）属于《证券法》对证券公司承销或者销售擅自公开发行或变相公开发行的证券的处罚措施。

- A. 没收违法所得，并处以违法所得二倍以上五倍以下的罚款
- B. 给投资者造成损失的，应当与发行人承担按份额赔偿责任
- C. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予警告并撤销任职或证券从业资格
- D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人处以三万元以上十万元以下的罚款

【答案】C

【解析】

《证券法》第183条规定，证券公司承销或者销售擅自公开发行或变相公开发行的证券的，责令停止承销或者销售，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销相关业务许可。给投资者造成损失的，应当与发行人承担连带赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销任职资格或者证券从业资格，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

3. 下列关于证券交易的说法，不正确的是（ ）。

- A. 非依法发行的证券，不得买卖
- B. 公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易
- C. 证券在证券交易所上市交易，必须采用公开的集中交易方式
- D. 证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法

【答案】C

【解析】

根据《证券法》第38条规定，证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

4. 下列关于证券承销业务的说法，不正确的是（ ）。

- A. 证券公司承销证券，应当同发行人签订代销或者包销协议
- B. 代销的特点是承销期结束时，未售出的证券将被全部退还给发行人
- C. 向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成
- D. 证监会应当为发行人指定承销的证券公司

【答案】D

【解析】

根据《证券法》第27条规定，公开发行证券的发行人有权依法自主选择承销的证券公司。证券公司不得以不正当竞争手段招揽证券承销业务。

5. 关于上市公司征集人制度，下列选项错误的是（ ）。

- A. 上市公司持有1%以上有表决权股份的股东可以作为征集人
- B. 依照规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合
- C. 可以用有偿的方式公开征集股东权利
- D. 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任

【答案】C

【解析】AB两项，根据《证券法》第90条规定，上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券

服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照上述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。

C项，禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。即不可以用有偿的方式公开征集股东权利。

D项，公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

二、多项选择题

1. 根据《证券法》，关于发行人、上市公司公告的招股说明书、财务会计报告等信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的责任承担，下列说法正确的是（ ）。

- A. 发行人、上市公司应承担赔偿责任
- B. 证券服务机构与发行人、上市公司承担按份赔偿责任
- C. 发行人、上市公司的控股股东承担过错责任
- D. 保荐人、承销的证券公司承担过错推定责任

【答案】A|C|D

【解析】

依据《证券法》第85条规定，信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

2. 下列尚未公开的信息中，（ ）属于内幕信息。

- A. 上市公司订立可使其全年销售收入大幅增长的销售合同
- B. 持有公司3%股份的股东，其持有股份发生微小变动
- C. 上市公司发生重大损失
- D. 上市公司做出与另一公司合并的决定，且合并后将取得在行业内的垄断地位

【答案】A|C|D

【解析】

内幕信息，是指可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息。B项，在尚未公开的信息中，持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化的信息属于内幕消息。

3. 单独或者通过合谋，利用（ ）联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量是《证券法》明确列示的操纵证券市场的手段。

- A. 资金优势
- B. 持股优势
- C. 信息优势
- D. 地理优势

【答案】A|B|C

【解析】

根据《证券法》第55条规定，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：①单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；②与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易；③在自己实际控制的账户之间进行证券交易；④不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报；⑤利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；⑥对证券、发行人公开作出评价、预测或者

投资建议，并进行反向证券交易；⑦利用在其他相关市场的活动操纵证券市场；⑧操纵证券市场的其他手段。操纵证券市场行为给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

4. 下列行为中，构成操纵证券、期货市场行为的是（ ）。

- A. 甲与乙合谋利用资金优势连续买卖，操纵证券交易价格
- B. 甲与乙相互串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格
- C. 甲以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格
- D. 甲系证券公司工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息，从事与该信息相关的证券活动

【答案】A|B|C

【解析】

D项，利用因职务便利获取的内幕信息从事相关的证券活动属于内幕交易行为。

5. 根据《证券法》，下列关于证券交易方式或制度的说法，错误的是（ ）。

- A. 依法公开发行的股票、公司债券及其他证券必须在依法设立的证券交易所上市交易
- B. 证券交易必须采用无纸化交易方式
- C. 投资者应当使用实名开立的账户进行交易
- D. 证券公司不得从事向客户融资或者融券的证券交易活动

【答案】A|B|D

【解析】

A项，根据《证券法》第37条规定，依法公开发行的股票、公司债券

及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易；B项，根据《证券法》第39条规定，证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式；D项，证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务，应当按照国务院的规定并经国务院证券监督管理机构批准。

三、概念题

1. 证券的公开发行与非公开发行

【答案】（1）证券的公开发行，是发行者向不特定的社会公众广泛出售证券的行为。我国《证券法》对公开发行作了明确的界定。有下列情形之一的，为公开发行：①向不特定对象发行证券的。②向特定对象发行证券累计超过200人，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内。③法律、行政法规规定的其他发行行为。

（2）证券的非公开发行，是指面向少数特定的投资者发行证券的行为。我国《证券法》对非公开发行作出了限制：非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

（3）公开发行与非公开发行都是证券发行募集资金的方式；二者的区别主要在于发行对象的不同。

2. 债券

【答案】

债券是指政府、金融机构及公司依法向投资者出具的、在一定时期内按约定的条件履行还本付息义务的一种有价证券。其特点有：①债券的发行人可以是中央或地方政府，也可以是金融机构或企业。由国家发行的，并由国家财政负责其本息偿还的是国债；由地方政府发行的，并由地方财政负责其本息偿还的是地方债；由银行和非银行金融机构发行并负责其本息偿还的是金融债，由公司发行并负责其本息偿还的是公司债（也称“企业债”）。②债券是债权凭证。它对投资者来说是金融资产，对发行者来说是金融负债。债券持有人是债券发行人的债权人，债券发行人是债券持有人的债务人。债券体现的是投资人和筹资人之间的债权债务关系。一旦约定条件具备，筹资人必须履行还本付息的义务。③债券是有期限的投资证券。无论什么样的债券都有一定的偿还期限。偿还期限届满，发行人就应向持券人偿还本金。有的债券在发行一段时间之后到期之前，可开始部分偿还本金。

3. 证券上市

【答案】

证券上市有广义和狭义之分。广义的证券上市是指已发行的证券依照法定的条件和程序在证券交易所或其他法定交易场所进行交易的行为。其中，已发行的证券包括公开发行的和非公开发行的证券，交易可以在证券交易所进行（场内交易），也可以在其他法定的交易场所进行（场外交易）。狭义的证券上市是指公开发行的证券依法在证券交易所挂牌进行集中竞价交易的行为，不包括非公开发行的证券的挂牌交易，也不包括场外交易市场的证券交易。依据我国《证券法》的规定以及学界和实务界的主流观点，一般所指称的证券上市采取的是狭义说。

4. 证券监管中的行政和解

【答案】证券监管中的行政和解是指中国证监会在对行政相对人涉嫌违反证券期货法律、行政法规和相关监管规定的行为进行调查执法过程中，根据行政相对人的申请，与其就改正涉嫌违法行为、消除涉嫌违法行为不良后果、交纳行政和解金、补偿投资者损失等事项进行协商，达成行政和解协议，并据此终止调查执法程序的制度。该制度被认为是中国证监会行政执法体制改革的一个重大创新，是适应资本市场快速发展需要，化解有限行政资源与行政效率之间矛盾，保护投资者合法权益的重要制度安排。

我国现行《证券法》从立法层面确认了证券领域的行政和解制度，第171条明确规定，国务院证券监督管理机构对涉嫌证券违法的单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人书面申请，承诺在国务院证券监督管理机构认可的期限内纠正涉嫌违法行为，赔偿有关投资者损失，消除损害或者不良影响的，国务院证券监督管理机构可以决定中止调查。被调查的当事人履行承诺的，国务院证券监督管理机构可以决定终止调查；被调查的当事人未履行承诺或者有国务院规定的其他情形的，应当恢复调查。

5. 信义义务与诚实信用原则

【答案】（1）信义义务是指在信托法律关系中，接受委托人的委托，为受益人的利益或者特定目的，对信托财产进行管理或者处分的人，即受托人，负有的义务。

（2）诚信原则是诚实信用原则的简称，是指民事主体在民事活动

中应当本着讲求诚实、恪守信用的态度，依照善意的方式行使权利、履行义务。《民法典》第7条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”

(3) 二者的不同：

①诚实信用只是原则，而信义义务包含具体的规则。

②诚实信用适用于全部民事活动，而信义义务仅适用于公司、信托等有限领域。

③诚实信用是基本标准，而信义义务则是民事活动中的高级标准。商事信托中的受托人的注意义务不仅比普通活动中的诚实信用标准高，甚至高于公司法中的董事、监事、高级管理人员的信义义务，因为公司法中的商事判断规则在一定程度上保护公司的董事、监事、高级管理人员，减轻了其信义义务，而商事判断规则并不必然适用于信托受托人。

四、简答题

1. 试析证券转让期限的限制。

【答案】依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。证券转让期限的限制主要包括以下两种类型：

(1) 对发起人所持股份的转让限制

股份有限公司的发起人发起设立后，发起人即公司的股东。但是，发起人对公司的成立及成立初期的财产稳定和组织管理有重要影响。为了避免发起人借设立公司投机牟利、损害其他股东及社会公众的利益，保证公司成立后一段时期能顺利经营。

(2) 对公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的转让限制

为了防止董事、监事、高级管理人员利用内幕消息炒作本公司股票牟利，法律有必要对董事、监事及高级管理人员选任当时所持有的股份在其任期内的转让进行适当限制。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

2. 试析证券发行的核准规则。

【答案】证券发行的核准规则包括以下几个方面的内容：

（1）审核机构

国务院证券监督管理机构设发行审核委员会，依法审核股票发行申请。

（2）核准程序

国务院证券监督管理机构依照法定条件负责核准股票发行申请。核准程序应当公开，依法接受监督。参与审核和核准股票发行申请的人员，不得与发行人有利害关系，不得直接或者间接接受发行申请人的馈赠，不得持有所核准的发行申请的股票，不得私下与发行人进行接触。国务院授权的部门对公司债券发行申请的核准，参照以上规定执行。

（3）核准时间

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起3个月内，依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定，发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内；不予核准的，应当说明理由。

（4）公告

证券发行申请经核准，发行人应当依照法律、行政法规的规定，在证券公开发行前，公告公开发行募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。发行证券的信息依法公开前，任何知情人不得公开或者泄露该信息。发行人不得在公告公开发行募集文件前发行证券。

（5）错误纠正及其法律责任

国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门对已作出的核准证券发行的决定，发现不符合法定条件或者法定程序，尚未发行证券的，应当予以撤销，停止发行。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有过错的除外；发行人的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人承担连带责任。

3. 简述证券交易所的概念及法律特征。

【答案】（1）证券交易所的概念

证券交易所是依据国家有关法律设立的，为证券集中交易提供场

所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。证券交易所既不直接买卖证券，也不决定证券价格，而只为买卖证券的当事人提供场所和各种必要的条件及服务。

（2）证券交易所的法律特征

①证券交易所一般都是依法设立的法人组织

关于交易所的设立，国际上通行三种制度，一种是以美国为代表的注册制；另一种是以英国为代表的承认制；再一种是以日本为代表的特许制。前两种制度的采用有其特殊的背景，因为英美证券市场是自然产生的，交易所成立在先，有关监管的立法在后。新兴市场国家一般均采用特许制。不论采取何种设立制度，一国的证券法总要对证券交易所的设立及运作作出明确的规定。根据我国证券法的规定，证券交易所的设立和解散，由国务院决定。由此可见，我国交易所的设立也是采取特许制。

②证券交易所是证券集中交易的场所

证券交易的场所一般分为场内交易市场和场外交易市场，证券交易所属于场内交易市场。从各国情况看，证券交易以场内交易为主，主要在证券交易所进行。证券交易所为证券交易提供必备的交易设施、通讯设备和服务等。目前，在我国证券交易所内所进行的主要是集中竞价交易和大宗交易、协议转让等非集中竞价交易。

③证券交易所是证券交易的组织者和监督者

交易所不仅提供有形的交易场所、现代化设施，而且要组织、监督证券交易活动。组织证券交易，主要包括接受申报、撮合成交、发布证券交易行情、公布证券交易信息、制定证券交易规则等。监管证券交易，主要包括实时监控证券交易、监督证券发行人履行信息披露义务、处理异常交易等。证券交易所对证券交易实行组织和监督，从而维护证券市场交易秩序，保护投资者利益。

④证券交易所是自律管理的法人

自律管理是指证券交易所出于维护证券交易市场秩序的需要，对证券市场上的证券发行人、市场交易主体以及其他市场参与人进行一线的监督管理，以维护证券市场的交易秩序，促进证券交易公平、有序地发展。证券交易所实行自律管理，弥补了政府监管的不足，有利于弥补市场失灵，维护市场秩序。但同时，证券交易所作为市场主体，也要接受政府监管部门的依法监管，其设立和解散、章程的制定和修改、总经理的任免、突发事件的处理以及制定规则等自律管理活动都要受到证监会的监管。证券交易所的这种自律监管者和被监管者的双重身份和职能，有利于其在证券市场上发挥承上启下的桥梁和纽带作用。

4. 简述证券交易所的职责范围。

【答案】证券交易所的职责范围包括：

(1) 提供证券交易的场所、设施和服务

证券交易所是证券市场第一线的组织者，为市场主体集中交易提供场所、技术等服务。

(2) 制定和修改证券交易所的业务规则

这些业务规则主要包括上市规则、交易规则、会员管理规则等。

(3) 证券发行及上市的审核，决定证券终止上市和重新上市

①关于证券发行审核。我国《证券法》第21条规定，“国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门依照法定条件负责证券发行申请的注册。证券公开发行注册的具体办法由国务院规定。按照国务院的规定，证券交易所等可以审核公开发行证券申请，判断发行人是否符合发行条件、信息披露要求，督促发行人完善信息披露内容”。这一立法正式确定了在注册制下，授权交易所对证券的公开发行申请进行审核的权力。

②关于证券上市审核、终止上市和重新上市。我国《证券法》在2005年修订时，取消了中国证监会对证券上市的行政许可，将证券上市审核权界定为证券交易所的法定职权。申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意。与此相应，证券在上市后，如终止上市或申请重新上市，也应当向交易所提出，交易所所有权做出同意与否的决定。

(4) 提供非公开发行证券转让服务

为适应证券交易所上市品种日渐丰富、种类多样的现实及完善证券交易所市场服务的职能，2017年《证券交易所管理办法》增加了“提供非公开发行证券转让服务”的新内容，为私募债等非公开发行证券的转让提供服务。

(5) 组织、监督证券交易

证券交易所负有组织和监督管理证券交易活动、维护证券市场正常运行的重要职责，主要表现在以下方面：

①因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件而影响证券交易正常进行时，为维护证券交易正常秩序和市场公平，证券交易所可以按照业务规则采取技术性停牌、临时停市等处置措施，并应当及时向证监会报告。

②对异常交易的取消权。因突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，按交易结果进行交收将对证券交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，证券交易所按照业务规则可以采取取消交易、通知证券

登记结算机构暂缓交收等措施，并应当及时向中国证监会报告并公告。

③实时监控和限制交易。《证券法》规定，证券交易所对证券交易实行实时监控，并按照中国证监会的要求，对异常的交易情况提出报告。证券交易所根据需要，可以按照业务规则对出现重大异常交易情况的证券账户的投资者限制交易，并及时报告中国证监会。同时，证券交易所应当加强对证券交易的风险监测，出现重大异常波动的，证券交易所可以按照业务规则采取限制交易、强制停牌等处置措施，并向中国证监会报告；严重影响证券市场稳定的，证券交易所可以按照业务规则采取临时停市等处置措施并公告。

④设立证券交易所风险基金。该基金用于弥补证券交易所重大经济损失，防范与证券交易所业务活动有关的重大风险事故，以保证证券交易活动正常进行。

（6）对会员进行监管

这里主要是对会员的资格、交易席位、交易单元、会员交易系统、会员业务行为的规范性等进行监督管理。会员出现违法违规行为的，证券交易所可以按照章程、业务规则的规定给予相应处罚。

（7）对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管

这方面的职责主要包括：证券交易所应当按照章程、协议以及业务规则，督促证券上市交易公司及相关信息披露义务人依法披露上市公告书、定期报告、临时报告等信息披露文件。证券交易所对信息披露文件进行审核，可以要求证券上市交易公司及相关信息披露义务人、上市保荐人、证券服务机构等做出补充说明并予以公布，发现问题应当按照有关规定及时处理，情节严重的，报告中国证监会。发行人、证券上市交易公司及相关信息披露义务人等出现违法违规行为的，证券交易所可以按照章程、协议以及业务规则的规定，采取通报批评、公开谴责、收取惩罚性违约金、向相关主管部门出具监管建议函等自律监管措施或者纪律处分。

（8）对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管

这里的证券服务机构主要是指投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等从事证券服务业务的专业机构。证券交易所有权依法对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为的合法合规性进行监管。

（9）管理和公布市场信息

证券交易所应当为组织公平的集中交易提供保障，实时公布证券交易即时行情，并按交易日制作证券市场行情表，予以公布。证券交

易即时行情的权益由证券交易所依法享有。未经证券交易所许可，任何单位和个人不得发布证券交易即时行情。

(10) 开展投资者教育和保护

保护投资者合法权益是资本市场发展的关键。证券交易所应当把保护投资者合法权益特别是中小投资者合法权益放在突出位置，从发行上市到市场监管，从风险控制到投资者教育，积极营造市场“三公”环境，努力保护投资者的合法权益。

(11) 证券监督管理机构赋予的其他职能

为确保证券交易所切实履行法定职责，《证券交易所管理办法》规定证券交易所不得直接或者间接从事：新闻出版业；发布对证券价格进行预测的文字和资料；为他人提供担保；未经中国证监会批准的其他业务。另外，证券交易所不得以任何方式转让其依法取得的设立及业务许可。

5. 我国上市公司持续信息披露的主要方式。

【答案】 (1) 发行、上市信息披露

经国务院证券监督管理机构核准依法公开发行股票，或者经国务院授权的部门核准依法公开发行公司债券，应当公告招投说明书、公司债券募集办法。依法公开发行新股或者公司债券的，还应当公告财务会计报告。

证券上市交易申请经证券交易所审核同意后，签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告证券上市的有关文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

(2) 持续信息披露

①定期报告。季报与中报，上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送记载以下内容的中期报告，并予公告。年度报告。上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起4个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送记载以下内容的年度报告，并予公告。

②临时报告。发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

6. 简述投资者权益救济措施。

【答案】资本市场的专业性、复杂性以及高风险性，使得投资者在证券交易中，容易因为对所投资证券的信息了解处于劣势，加之投资活动经验不足，常常受到侵害。因此，对投资者合法权益进行专门保护成为各国证券法立法的基本宗旨之一。投资者权益救济措施包括：

（1）投资者保护机构

我国证券市场中以自然人投资者为主的市场结构，以及投资者投资理性和经验的缺乏，决定了设立专业的投资者保护机构的重要性。目前，在中国证监会的统一部署和领导下，已经形成了“一体两翼”的投资者保护组织体系。其中，“一体”是指中国证监会下设的中国证监会投资者保护局，“两翼”分别指中国证券投资者保护基金有限责任公司和中证中小投资者服务中心有限责任公司。

①中国证监会投资者保护局作为中国证监会内设机构，其主要职责是：**a.** 负责证券期货市场投资者保护工作的统筹规划、组织指导、监督检查、考核评估；**b.** 推动建立健全投资者保护相关法律法规政策体系；**c.** 统筹协调各方力量，推动完善投资者保护的体制机制建设等工作。

②中国证券投资者保护基金有限责任公司由中国证监会负责管理，其主要职责包括：**a.** 筹集、管理和运作基金；**b.** 监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；**c.** 证券公司被撤销、关闭和破产或被中国证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；**d.** 组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作等。

③中证中小投资者服务中心有限责任公司是证券金融类公益机构，同样由中国证监会直接管理。其主要职责包括：**a.** 面向投资者开展公益性宣传和教育；**b.** 公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；**c.** 受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；**d.** 为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作等。

（2）先行赔付制度

先行赔付，是指在发生虚假陈述等案件时，在对发行人、上市公司等市场主体据以承担赔偿责任的行政处罚、司法裁判做出之前，由可能承担民事赔偿责任的连带责任人之一先行垫资向投资者承担赔偿责任，然后再由先行赔付者向未参与先行赔付的发行人、上市公司以及其他责任人进行追偿的一种措施。对于投资者而言，这一制度具有权益救济的方便快捷性。先行赔付目前主要适用于发行人因欺诈发行、虚假陈述或其他重大违法行为给投资者造成损失的案件。先行赔付的责任主体主要是发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司。实践中，往往是由保荐机构先行赔付，在先行赔付之后，其可依

法向发行人或其他连带责任人追偿。

（3）证券支持诉讼制度

证券支持诉讼，是针对涉及中小投资者众多、矛盾比较突出、社会影响较大的典型证券侵权纠纷，由投服中心以投资者保护机构的身份，根据中小投资者提出的申请，委派投服中心的公益律师或法律专业人员作为中小投资者诉讼代理人，代理中小投资者向法院起诉并参与诉讼的活动。在该制度中，投服中心作为支持机构，选择案件，委派诉讼代理人，支持权益受损的中小投资者依法诉讼维权。该制度不但有利于维护中小投资者的合法权益，而且有助于提高证券纠纷案件的司法审判质量，对维护资本市场发展起到积极效果。

（4）证券代表人诉讼制度

由于证券市场中的投资者人数众多，因某一证券违法行为造成的受害主体为不特定多数人，从而形成大规模证券纠纷。为快速、高效地解决这类纠纷，应当建立特殊的诉讼机制。

我国《民事诉讼法》对代表人诉讼有明确规定，即当事人一方人数众多的共同诉讼可以推选代表人进行诉讼，代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生效力。与此相应，我国《证券法》明确规定了证券领域的代表人诉讼制度，主要内容包括：①投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。②对于这类诉讼，人民法院可以发出公告，说明该诉讼请求的案件情况，通知投资者在一定期间向人民法院登记。人民法院做出的判决、裁定，对参加登记的投资者发生法律效力。③投资者保护机构受50名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

可见，我国现行立法对于投资者保护机构作为证券代表人诉讼的案件实行的是“默示加入、明示退出”，即投资者保护机构在接受50名以上投资者委托后，便取得证券诉讼代表人资格，其可以当然代表证券登记结算机构登记确认的投资者进行诉讼，所产生的诉讼结果对登记在册的投资者有效，除非有投资者明示反对，不愿意参与投资者保护机构作为诉讼代表人的诉讼中。该制度对于有效维护中小投资者合法权益、高效解决大规模证券纠纷具有积极作用。

五、论述题

1. 什么是证券发行核准制？什么是证券发行注册制？它们各有什么利弊？我国为什么要改证券发行核准制为证券发行注册制？

相关试题：注册制与核准制（证券发行审核）[概念题，华东政法2020年研]

【答案】我国已将证券发行核准制改为证券发行注册制，两者的概念、利弊，以及改革原因如下：

（1）证券发行核准制

①证券发行核准制是证券发行人发行证券须取得主管当局审核批准的一种制度。核准制的理论依据是：证券发行涉及公共利益和社会安全，审核机构应在公开原则基础上，考察发行者的具体情形，并由此作出是否符合发行实质条件的价值判断。

②证券发行核准制的好处是：核准制有利于新兴市场的健康发展，适合于证券市场不完善、投资服务机构的道德水准、业务水平不高、投资人缺乏经验与业务水平、缺少对信息判断的能力的地区。这些地区的风险是比较大的。

③证券发行核准制的弊端是：证券不仅须公开真实情况，还须合乎若干实质条件，并经主管当局进行审查方可发行证券，容易导致投资人产生完全依赖性，并且主管机关的意见未必百分之百准确。

（2）证券发行注册制

①证券发行注册制，又称“申报制”，是指政府对发行人发行证券，事先不作实质性审查，仅对申请文件进行形式审查，发行者在申报申请文件以后的一定时期以内，若没有被政府否定，即可以发行证券。注册制的理论依据是：证券发行只受信息公开制度的约束，证券管理机构的职责是审查信息资料的全面性、真实性、准确性和及时性，政府并不对证券自身的价值作出任何判断。投资者根据公开的信息作出选择，风险自负。投资者要求发行人承担法律责任的前提是发行人违反信息公开义务和注册制度。

②证券发行注册制的好处是：它反映了的价值观念反映了市场经济的自由性、主体活动的自主性和政府管理经济的规范性和效率性。在这种制度下，证券管理机构只对申请文件作形式审查，不涉及发行申请者及发行证券的实质条件，不对证券及其发行行为作任何价值判断，因而降低了审核工作量。申报文件提交后，经过法定期间，申请即可生效，从而免除了烦琐的授权程序。

③证券发行核准制的弊端是：证券注册不能成为投资者免受损失的保护伞，只要发行公开要素具备，则投资风险由投资者自负，注册程序不保证注册申报书和公开说明书中陈述事实的准确性。

（3）目前我国已经实行了改革，将证券发行核准制改为了注册制。相比之下，注册制的发行成本更低，效率更高，也更有利实现证

券市场的价格发现功能，同时注册制也是大多数成熟的证券场所采用的方式。我国进行改革，也是顺应了我国的国情和证券市场的发展情况。

2. 为什么要对证券市场实行必要的监管？证券监管机构如何才能做到有效监管？

【答案】证券监管是以明确证券监管的目的，通过维持公平、公正、公开的市场秩序来保护证券市场参与者合法权益的工作，并依此促进证券行业的不断发展。

（1）证券监督管理的必要性

证券市场的健康运作对于促进资金流通、发展市场经济具有重大的意义。若证券市场充满欺诈、内幕交易、操纵价格等不正当行为，则投资者不可能抱有足够的投资热情。若不对这些不正当行为加以国家干预，则证券市场就不可能继续存在，通过资金的筹措和流动促进经济的发展就必然成为一句空话。美国出现的1929年股市大崩溃，中国出现的1995年“327国债事件”，都曾给市场带来灾难性的后果。中外证券市场的实践都证明，对证券市场施以监督管理是必不可少的。

（2）有效监管的措施

①我国的证券监管机构是证券业监督管理委员会，作为政府监管机构，要明确自己的职责，依法行使职能应明确监管的依据和手段，依据《证券法》等相关法律法规以及管理办法，不能单纯地依赖于行政命令，应根据证券市场的实际情况，利用经济性手段管理经济事件；最后，应明确监管的范围，行使权力的适度，避免影响证券市场的运行效率，打破证券市场的平衡发展。

②为保障证券市场的高效、稳定、有序、顺利地运行，围绕证券监管的各项目标，证券市场的有效监管必须确立下列原则。“三公”原则即公平、公开、公正原则，这也是证券监管最基本的原则。此外，要确保投资者的信心，坚守诚实信用原则、依法管理原则。

③要采取法律手段，即国家通过立法和执法，以法律规范形式将证券市场运行中的各种行为纳入法制轨道，证券发行与交易过程中的各参与主体按法律要求规范其行为。运用法律手段管理证券市场，主要是通过立法和执法抑制和消除欺诈、垄断、操纵、内幕交易和恶性投机现象等，维护证券市场的良好运行秩序。

④要采取经济手段，政府以管理和调控证券市场（而不是其他经济目标）为主要目的，采用间接调控方式影响证券市场运行和参与主体的行为。如：金融信贷手段、税收政策和行政政策等。

⑤调整好政府管理与自律管理之间的主从关系。自律管理是政府监管的有效补充，自律管理机构本身也是政府监管框架中的一个监管对象。证券监管机构要顺应政府体制改革的要求，吸收发达国家市场化监管的成功经验，遵循成本效率原则，在监管和效率之间保持一种恰当的平衡。同时要完善证券市场监管的组织体系，建立一个具有高度独立性、权威性的证券监管机构。

3. 论证券法中的信息披露制度。

【答案】（1）信息披露制度的概念

信息披露制度，又称公示制度、公开披露制度，是上市公司为保障投资者利益、接受社会公众的监督而依照法律规定必须将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向证券管理部门和证券交易所报告，并向社会公开或公告，以便使投资者充分了解情况的制度。它既包括发行前的披露，也包括上市后的持续信息公开。

（2）信息披露制度的特征

从信息披露法律制度的主体上看，它是以发行人为主线、由多方主体共同参加的制度。从各个主体在信息披露制度中所起的作用和地位看，他们大体分为四类：

①信息披露的重要主体，它们所发布的信息往往是有关证券市场大政方针，因而也是较为重要的信息，这类主体包括证券市场的监管机构和政府有关部门。特别是证券市场的监管机构，它们在信息披露制度中既是信息披露的重要主体，也是保障信息披露的法律得以实施的执行机关，因此它们在披露制度中处于极为重要的地位。

②信息披露的一般主体，即证券发行人，它们依法承担披露义务，所披露的主要是关于自己的及与自己有关的信息，是证券市场信息的主要披露人。

③信息披露的特定主体，它们是证券市场的投资者，一般没有信息披露的义务，只在特定情况下，它们才履行披露义务。

④其他机构，如股票交易场所等自律组织、各类证券中介机构，它们制定一些市场交易规则，有时也发布极为重要的信息，如交易制度的改革等，因此也应按照有关规定履行相应职责。

（3）信息披露制度的公开内容

持续信息公开主要涉及上市公告书、年度报告、中期报告及临时报告等，而初始信息公开主要是招股说明书、配股说明书、募债说明书等。

六、案例分析题

1. 某上市公司决定通过发行新股募集资金，用以扩大生产规模。在董事会草拟的方案中有以下主要内容：本次发行面值人民币7000万元的新股，全部向社会募集；委托某证券公司独家代销，代销期为96天；为保证发行工作能够得以顺利开展，准备向证券管理机构、证券交易所的有关人员每人送1000股；同时公司考虑到受股本扩张的影响，因此预期股票利润率比同期银行利率低0.2个百分点。

请指出该方案的错误之处。

【答案】该方案有以下四个方面的错误：

（1）根据《证券法》规定，向社会公开发行的证券票面总额超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。因此，委托某证券公司独家代销是错误的。

（2）根据《证券法》规定，证券的代销包销期最长不得超过90日，故承销期为96天也是违背法律规定的。

（3）根据《证券法》规定，证券交易所、证券管理机构的工作人员，在任期或法定期限内不得直接或化名、借他人名义持有、买卖股票，也不能收受他人赠送的股票。所以，打算向证券管理机构、证券交易所的有关人员赠送1000股是违法的。

（4）根据《公司法》规定，发行新股其预期利润率不得低于同期银行存款利率，因此，比同期银行利率低0.2个百分点是错误的。

2. 赵某为某证券公司的董事，2014年3月至2015年5月，赵某多次将公司对股市的分析预测告知其妻孙某。孙某在此期间通过购买红叶客车股、金长城电脑股，获利30万余元。

问题：对赵某的行为应如何定性？

【答案】赵某的行为是内幕交易行为，应当没收其非法所得，并予以罚款。

内幕交易行为是指内幕人员利用尚未公开、可能影响证券 market 价格的证券情报。进行的非法交易行为。内幕交易行为的特点有：（1）交易行为违反证券法规，利用内幕信息进行证券交易；（2）内幕交易行为的行为人须有主观上的故意，并有获利或减损的目的；（3）内幕交易须有内幕人员直接或间接地参与或泄露内幕信息。对于内幕交易行为，可以令其承担民事赔偿责任，也可以给予行政处罚，情节严重的还应追究其刑事责任。

第九章 期货交易法

一、单项选择题

1. 下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（ ）。

- A. 中国证监会派出机构的工作人员
- B. 某市商务局
- C. 某高校教授
- D. 证券市场禁止进入者

【答案】C

【解析】

《期货交易管理条例》第25条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：①国家机关和事业单位；②国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；③证券、期货市场禁止进入者；④未能提供开户证明材料的单位和个人；⑤国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

2. 下列关于客户保证金的表述，正确的是（ ）。

- A. 期货交易所可以向客户收取保证金
- B. 客户保证金标准由期货交易所单独制定
- C. 客户保证金可用于支付期货交易手续费
- D. 客户保证金名义上属于期货公司所有

【答案】C

【解析】

《期货交易管理条例》第28条规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当与自有资金分开，专户存放。期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：①依据客户的要求支付可用资金；②为客户交存保证金，支付手续费、税款；③国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

二、多项选择题

1. 下列主体中，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易的有（ ）。

- A. 某事业单位的工作人员
- B. 中国期货业协会的工作人员
- C. 某国家机关
- D. 未能提供开户证明材料的单位

【答案】 B|C|D

【解析】

《期货交易管理条例》第25条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：①国家机关和事业单位；②国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；③证券、期货市场禁止进入者；④未能提供开户证明材料的单位和个人；⑤国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

2. 某事业单位与某期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易。关于该事业单位期货交易的表述，正确的是（ ）。

- A. 该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易
- B. 该事业单位不得进行期货交易

C. 期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易

D. 中国证监会可以对事业单位进行处罚

【答案】B|C

【解析】

《期货交易管理条例》第25条规定，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：①国家机关和事业单位；②国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；③证券、期货市场禁止进入者；④未能提供开户证明材料的单位和个人；⑤国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

三、概念题

1. 期权交易

【答案】

期权交易是指以期权合约为对象的交易，买方支付期权费获得期权。期权合约是指期权的买方有权在约定的时间或约定的时期内，按照约定的价格买进或卖出一定数量的相关资产，也可以根据需要放弃行使这一权利。期权交易的特点有：①期权交易双方权利与义务不对等，买方只有权利没有义务，卖方只有义务没有权利。②期权只有卖方缴纳保证金，买方只需支付期权费。③期权的买方最大亏损是期权费，获利是无限的，卖方最大收益是期权费，亏损是无限的。④期权是交易未来买卖某种商品的权利，到期可以执行也可以放弃。

2. 期货保证金

【答案】期货保证金是指期货市场上的交易者按期货合约价格的一定比例交纳的作为履行期货合约财力担保的资金。在我国，期货保证金（以下简称保证金）按性质与作用的不同，可分为结算准备金和交易保证金两大类：①结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。②交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类。初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金＝交易金额

×保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%~8%之间。

期货交易保证金对于保障期货市场的正常运转具有重要作用：①保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5%的保证金就可以从事100%的远期贸易，发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。②期货交易保证金为期货合约的履行提供财力担保。③保证金是交易所控制投机规模的重要手段。

四、简答题

1. 什么是期货交易的涨跌停板制度？其作用是什么？

【答案】（1）涨跌停板制度指每一交易日期货合约的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价的一定幅度，达到该幅度则自动限制价格的继续上涨或下跌。在涨跌停板制度下，前一交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板；前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限，称为跌停板。涨跌停板又叫每日价格最大波动幅度限制。其幅度有百分比和固定数量两种形式。

（2）涨跌停板制度与保证金制度相结合，对于保障期货市场的运转，稳定期货市场的秩序以及发挥期货市场的功能具有十分重要的作用，具体如下：

①涨跌停板制度为交易所、会员单位及客户的日常风险控制创造了必要的条件。涨跌停板锁定了客户及会员单位每一交易日可能新增的最大浮动盈亏和平仓盈亏，这就为交易所及会员单位设置初始保证金水平和维持保证金水平提供了客观准确的依据，从而使期货交易的保证金制度得以有效地实施。

②涨跌停板制度的实施，可以有效地减缓和抑制突发事件和过度投机行为对期货价格的冲击，给市场一定的时间来充分化解这些因素对市场所造成的影响，防止价格的狂涨暴跌，维护正常的市场秩序。

③涨跌停板制度使期货价格在更为理性的轨道上运行，从而使期货市场更好地发挥价格发现的功能。这是因为期货价格对市场信号和消息的反应有时过于灵敏，通过实施涨跌停板制度，可以延缓期货价格波幅的实现时间。

④在出现过度投机和操纵市场等异常现象时，调整涨跌停板幅度往往成为交易所控制风险的一个重要手段。

2. 简述期货交易规则的具体内容。

【答案】期货交易是特殊交易，需要遵循特殊的交易规则。为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，防范风险，保护期货交易各方的合法权益，《期货交易管理条例》规定了适用于期货交易的基本规则，主要包括以下机制：

（1）保证金制度

保证金是仅适用于狭义期货交易的概念，不适用于期权交易。在期货交易中，期货交易者需要按照其交易的期货合约价值的一定比例，向期货经营机构缴纳保证金，期货经营机构作为期货交易所的结算会员，也要按照其交易的期货合约价值的一定比例，向期货交易所缴纳期货交易保证金。保证金只能用于结算和保证履约。

（2）当日无负债结算制度

当日无负债结算制度又称每日无负债结算、逐日盯市，是指当日交易结束后，期货交易所按照当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用。对应收应付的款项实行净额一次划转，相应地增加或减少结算准备金。结算会员在期货交易所结算完成后，按照上述原则对客户、交易会员进行结算；交易会员按照上述原则对客户进行结算。

当日无负债结算的核心，是按照交易当日结算价格计算盈亏。其中所称当日结算价，是在正常交易的最后时刻确定的，用于计算期货经营机构和期货交易者账户的盈亏、追加保证及交割的发票价格。

（3）持仓限额和大户持仓报告制度

①持仓限额制度

持仓限额，是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。持仓限额制度是期货交易所为防范操纵市场价格的行为，防止期货市场过度集中于少数投资者而定的制度。期货交易者自定的持仓限额，主要是期货交易者为了控制风险而约束其雇员的措施，一般不产生对外效力。

②大户持仓报告制度

大户持仓报告制度是指会员或客户在某一合约上的持仓量，达到期货交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应当向期货交易所报告的制度。期货交易所通常是根据市场风险状况制定、公布、修订大户持仓报告标准。

（4）涨跌停板制度和熔断机制

①涨跌停板制度

涨跌停板制度是限制期货合约成交价格波动的制度，涨跌停板，又称每日价格最大波动幅度限制，是指期货合约在一个交易日中的成交价格，不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨

跌幅度，超过该范围的报价将视为无效，不能成交。

②熔断机制

熔断机制，是指当期货合约成交价格涨跌幅度达到某一比例时，按照期货交易所规定暂停交易一定时间的制度。

第十章 商事信托与投资基金法

一、单项选择题

1. 某基金管理公司在2003年曾公开发售一只名为“基金利达”的封闭式基金。该基金原定封闭期15年，现即将到期，拟转换为开放式基金继续运行。关于该基金的转换，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 须经国务院证券监督管理机构核准
- B. 转换后该基金应保持一定比例的现金或政府债券
- C. 基金份额持有人大会就该转换事宜的决定应经有效表决权的1/2以上通过
- D. 转换后基金份额持有人有权查阅或复制该基金的相关会计账簿等财务资料

【答案】B

【解析】A项，《证券投资基金法》第78条规定，按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并。第86条第4款规定，基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。据此转换基金的运作方式，需要报证监会备案而不是经证监会核准。

B项，《证券投资基金法》第68条规定，开放式基金应当保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。基金财产中应当保持的现金或者政府债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定。据此，“基金利达”由封闭式基金转换为开放式基金后，应当保持一定比例的现金或政府债券。

C项，《证券投资基金法》第86条第3款规定，基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上通过。但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。据此，转换基金运作方式应当由2/3以上的表决权通过而不是1/2以上的表决权通过。

D项,《证券投资基金法》第46条第2款规定,公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料。非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况,有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料。

2. 赢鑫投资公司业绩骄人。公司拟开展非公开募集基金业务,首期募集1000万元。李某等老客户知悉后纷纷表示支持,愿意将自己的资金继续交其运作。关于此事,下列哪一选项是正确的? ()

- A. 李某等合格投资者的人数可以超过200人
- B. 赢鑫公司可在全国性报纸上推介其业绩及拟募集的基金
- C. 赢鑫公司可用所募集的基金购买其他的基金份额
- D. 赢鑫公司就其非公开募集基金业务应向中国证监会备案

【答案】C

【解析】A项,《证券投资基金法》第87条第1款规定,非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过200人。

B项,《证券投资基金法》第91条规定,非公开募集基金,不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

C项,《证券投资基金法》第94条第2款规定,非公开募集基金财产的证券投资,包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额,以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。因此赢鑫公司可用所募集的基金购买其他的基金份额。

D项,《证券投资基金法》第94条第1款规定,非公开募集基金募集完毕,基金管理人应当向基金行业协会备案。对募集的资金总额或者基金份额持有人的人数达到规定标准的基金,基金行业协会应当向国务院证券监督管理机构报告。

3. 关于证券投资基金,下列哪一说法正确? ()

- A. 基金合同的当事人是基金管理人和基金份额持有人，基金托管人是基金合同的关系人
- B. 基金管理人和基金托管人可以是同一人
- C. 基金管理人和基金托管人可以相互投资或持股
- D. 基金托管人可以由商业银行担任

【答案】D

【解析】A项，《证券投资基金法》第3条第1款规定，基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务，依照本法在基金合同中约定。由此可知，基金管理人和基金份额持有人、基金托管人都是基金合同当事人。

BC两项，第35条规定，基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份。

D项，第32条第1款规定，基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。

二、多项选择题

1. 张某手头有一笔闲钱欲炒股，因对炒股不熟便购买了某证券投资基金。关于张某作为基金份额持有人所享有的权利，下列哪些表述是正确的？（ ）

- A. 按份额享有基金财产收益
- B. 参与分配清算后的剩余基金财产
- C. 可赎回但不能转让所持有的基金份额
- D. 可通过基金份额持有人大会来更换基金管理人

【答案】A|B|D

【解析】ABC三项，《证券投资基金法》第46条第1款规定，基金份额持有人享有下列权利：①分享基金财产收益；②参与分配清算后的剩余基金财产；③依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；④按照

规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；⑤对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；⑥对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；⑦基金合同约定的其他权利。张某有权按份额享有基金财产收益并且参与分配清算后的剩余基金财产，也可以回赎并依法转让所持有的基金份额。

D项，第47条第3项规定，基金份额持有人大会~~有权~~决定更换基金管理人、基金托管人。因此，基金份额持有人可以通过基金份额持有人大会来更换基金管理人。

2. 华新基金管理公司是信泰证券投资基金（信泰基金）的基金管理人。华新公司的下列哪些行为是不符合法律规定的？（ ）

- A. 从事证券投资时，将信泰基金的财产独立于自己固有的财产
- B. 以信泰基金的财产为公司大股东鑫鑫公司提供担保
- C. 就其管理的信泰基金与其他基金的财产，规定不同的基金收益条款
- D. 向信泰基金份额持有人承诺年收益率不低于12%

【答案】B|C|D

【解析】A项，《证券投资基金法》第5条第2款规定，基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

BCD三项，《证券投资基金法》第20条规定，公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：①将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；②不公平地对待其管理的不同基金财产；③利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；④向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；⑤侵占、挪用基金财产；⑥泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；⑦玩忽职守，不按照规定履行职责；⑧法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

3. 关于证券投资基金运用基金财产进行投资的范围，下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 可以买卖该基金管理人发行的债券
- B. 可以买卖上市交易的股票、债券
- C. 不得从事承担无限责任的投资
- D. 不得用于承销证券

【答案】B|C|D

【解析】ACD三项，《证券投资基金法》第73条第1款规定，基金财产不得用于下列投资或者活动：①承销证券；②违反规定向他人贷款或者提供担保；③从事承担无限责任的投资；④买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；⑤向其基金管理人、基金托管人出资；⑥和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。买卖该基金管理人发行的债券属于该条第5项规定的情形，承销证券与从事承担无限责任的投资分别属于该条第1、3项规定的情形。

B项，《证券投资基金法》第72条规定，基金财产应当用于下列投资：①上市交易的股票、债券；②国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。

三、概念题

1. 证券投资基金

【答案】

证券投资基金是指一种由众多不确定的投资者将不同的出资份额交给专业投资机构，由专业机构汇集起来并投资于股票或债券等有价值证券，所得的收益由投资者按出资份额分享的投资工具。证券投资基金的特征包括：①须集合分散资金用于投资，其集资的方式主要是向投资者发行“基金券”，也称股票或受益凭证，从而将分散的小额资金汇集为一个较大的基金加以投资运用。②利用信托关系组织证券投资。③证券投资基金只能投资于股票或债券等有价值证券。④证券投资收益须依法分配给投资人。

2. 开放型基金和封闭型基金

【答案】依据基金份额变现方式的不同，投资基金的种类可以分为开放型基金和封闭型基金。

(1) 开放型基金，是指资本形成不完全固定，其已发行基金可以按净资产价值赎回的一种基金形式。其特点是：基金股份的发行者有义务应受益人的请求，随时依据资产净值购回它所发行的基金，而且是见票即付。

(2) 封闭型基金，是指资本形成固定，且在一定期限内不能要求偿还的一种基金。其特点是在基金股份发行结束后即不再向投资者出售，投资者可以在证券市场上购买和出售其基金份额，但不能直接要求投资基金赎回。

(3) 二者的主要区别在于：①前者的发行规模是变化的，便于业务扩展，适应发达的金融市场；后者则固定不变，多为不发达市场所采用。②前者的定价是依据基金的净资产值，后者则取决于市场供求；③前者的投资者可将投资赎回，后者则不可。④前者的资金运用成本较高，后者相对较低。

3. 商事信托

【答案】

商事信托是指个人或法人委托以经营信托业务为其营业的信托机构进行财产经营而设立的信托。凡信托事项所涉及的法律依据在商法规定的范围之内的信托均可归属为商事信托。商事信托的类型主要包括：①集合资金信托；②企业年金信托；③信贷资产证券化信托，又称特殊目的信托；④保险资金信托。

四、简答题

1. 如何理解商事信托中的信托目的？

【答案】(1) 信托目的是设立信托的必要条件。信托目的一般表述为信托财产的主要运用方式与拟实现的具体目的结合。

(2) 信托目的必须合法。信托目的的合法性直接影响信托的合法性，但信托目的的合法性的判定是目前实践中比较困难的一个问题。利用信托规避法律、法规或监管部门的限制是实践中比较常见的做法。以企业职工通过信托持股为例，从形式上看该信托的目的是解决众多职工持股问题，但从另一方面看它可能会规避法律对公司股东人

数的限制。同样，受让股权收益权的资金信托，名义上信托目的是为投资人（受益人）谋取收益，但实质上是为资金使用方融资。实践中，除非直接违反禁止性规定或严重违法，信托目的的合法性较少受到关注。

2. 简述信托财产的范围和独立性。

【答案】（1）信托财产的范围

信托财产必须是财产或财产性权利，具有法律确定的独立的财产权的形态。财产权是指具有金钱价值的权利，凡是具有金钱价值的权利都可以成为信托财产，包括物权，准物权（如承租权、矿业权等），债权，以及无体财产权等。对于一些新型的、在法律上尚没有完全定性的权利是否可以作为信托财产，均存在着较多的争议，主要包括：

①经营权能否作为信托财产：经营权是指市场主体依法享有对企业支配其人力、物力与财力的权利。经营权作为一种财产权，具有一定的独立性和财产价值，同时具有可让与性及与所有权一定时间内的分离特征，因此可以作为信托财产。但经营权作为信托财产受该经营权本身的性质比如企业所有权以及监管政策的限制。

②股权或其他资产收益权能否作为信托财产：股权或资产作为一种财产权，以其作为信托财产设立信托不存在法律上的障碍。但不转移股权或资产信托的所有权与控制权而进行融资的方式本质上并不是信托，而是一种融资行为。因此实践中很多股权或资产收益权信托将股权或资产收益权变换为一种可投资的产品，由信托公司发行集合资金理财计划，以募集的资金购买股权或资产收益权，通过这种方式实现融资目的。此时设立信托的资产为现金而不是股权或资产收益权，对于这种形式的信托法律上没有限制。

③表决权能否作为信托财产：表决权不具有财产权的特征，也不具有独立性，不能脱离股份或股权而独立存在，单纯地以表决权为信托财产设立信托不符合信托的本义与信托法的规定。但是表决权可以存在于股权信托中，以股权信托的形式实现股东集中行使表决权的目，同时通过受益权的安排保留真实股东收益上的权利。

④将来权利和期待权能否作为信托财产：两类财产权能否成为信托财产关键看它们的现时存在性。将来权利本身现时是存在的，它的内容、范围、价值在现时是可确定的，因此可以作为信托财产；而期待权只是对将来取得财产权的一种希望或期待，未来能实现，它的内容、范围、价值在现时都是不确定的，因此它不具有财产确定性的特

征，不能成为信托财产。

（2）信托财产的独立性

信托财产的独立性是信托关系的一大特点，其对于商事信托而言意义重大。信托财产的独立性主要包括以下四个方面：

①信托财产对于委托人的独立性。委托人一旦将信托财产交付给受托人，信托生效，委托人对信托财产的所有权转移给托人。委托人对信托财产不再享有所有权，仅享有对信托的监督权及与之相关的权利。信托财产与委托人未设立信托的其他财产相区别，除特定情形外，信托财产不属于委托人的遗产或清算财产。除法律另有规定外，信托财产不得被强制执行

信托财产独立于委托人其他财产也存在例外：在委托人死亡或依法解散、依法撤销或被宣告破产时，委托人为信托的唯一受益人，信托终止，信托财产与委托人的其他财产共同为委托人的遗产或清算财产。

②信托财产对于受托人的独立性：a. 禁止将信托财产与受托人财产混同。b. 信托财产不属于受托人的遗产或清算财产。c. 信托财产产生的债权不得与受托人固有财产产生的债务相抵销，也不得与受托人管理运用、处分其他委托人的信托财产所产生债务相抵销。d. 强制执行禁止。

③信托财产对于受益人的独立性。受益人不享有占有、管理、控制信托财产的权利，仅享有受益权、监督权。受益人的债权人不能主张对信托财产的请求权，不能因受益人所负债务申请法院强制执行信托财产。

④信托财产损益的独立性。受托人按信托文件的规定谨慎、尽职地管理信托财产的前提下，在信托存续期间，受托人在处理信托过程中产生的收益和其他信托利益归于信托财产，非受托人过失或其他人过失或侵权导致的信托财产的损失由信托财产承担。

3. 与一般个人投资者或机构投资者相比，证券投资基金在运作上的优缺点是什么？

【答案】证券投资基金指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

（1）在现代金融市场中，与一般的个人投资者或机构投资者相比，证券投资基金的运作具有如下优点：

①规模较大。资金规模大是证券投资基金的一个重要特点。在美国，一只证券投资基金的规模可高达几百亿美元；在中国目前条件下，每只证券投资基金的规模一般在20亿元以上，大大高于单个工商企业、证券公司及个人的证券投资规模。

②专业运作。证券投资基金通常交给专业水平较高的管理人。在基金管理人组织中，专职证券分析人员、富有证券组合经验的专业人员和富有证券市场经验的专业操作人员协同工作，能够比较有效地克服单个工商企业、证券公司或个人在证券投资中的信息分析、市场理解及操作技能不足等缺陷，从而保障证券投资的有效性和收益水平。

③组合投资。管理人在运作中通常将资金同时投入不同种证券中，并特别注意各种证券在价格走势、市场风险、收益预期、持有时间、持有比例等方面的组合关系，适时地调整所持证券的组合状况，从而积极分散投资风险，努力为基金持有人谋取投资收益。

④较好的长期收益。管理人运用组合投资方式从事证券投资，有利于分散投资风险，保障基金持有人的收益。从长期看，证券投资基金持有人的收益率普遍高于同期银行存款利率、同期国债和同期公司债券的利率、同期股市的平均收益率。

(2) 证券投资基金在运作中也明显存在一些不足，主要表现在：

①投资领域的局限性。证券投资基金的特性决定了资金只能投资于证券，不能投资于实体经济部门或其他市场。由此，在一个确定时间内，证券投资基金的收益率有时不是各种投资（包括实体经济部门投资）中最高的。

②追逐收益的局限性。证券投资基金的主要收入来自证券的买卖价差，随着证券市场规范程度的提高和机构投资者之间竞争性的强化，证券交易的买卖价格波动有着趋于平缓的态势，管理人难以通过证券买卖价差来获得基金运作收入。

③专业分析的局限性。对各种有关证券市场的信息进行分析处理，是基金管理人的优势，但基金管理人得到的任何信息都是不完整和滞后的，在此基础上进行的分析预测均存在着不准确性和风险性。

④既得利益的局限性。在公募条件下，证券投资基金的持有人相当分散，如果社会信用制度不健全、证券市场制度和基金监管体系不完善、基金管理人重视遵守诚信原则，基金管理人很容易出现投资随意或为自身利益而大搞内幕交易、损害基金持有人权益的现象。

第十一章 破产法

一、单项选择题

1. 甲是某有限公司的工人，2016年8月2日，甲因工伤住院治疗，久治未愈，期间医疗费用、护理费等一直由该公司垫付。2017年9月，该公司向甲支付10万元赔偿金后便不再垫付其后续的医疗费用。甲认为公司支付的赔偿金额过低，于2017年10月向法院提起诉讼，要求该公司支付医疗费、护理费、伤残补助金等共计20万元。2017年11月，该公司经营不善，法院裁定受理其破产申请。对此，下列说法正确的是？（ ）

- A. 管理人可以要求甲返还医疗费
- B. 对于该公司向甲支付的赔偿金，管理人可向法院申请予以撤销
- C. 甲经过申报债权后，有权参加债权人会议
- D. 法院裁定受理某公司破产申请后，甲提起的诉讼应当中止审理

【答案】D

【解析】AB两项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》（以下简称《破产法司法解释（二）》）第16条规定，债务人对债权人进行的以下个别清偿，管理人依据企业破产法第32条的规定请求撤销的，人民法院不予支持：①

债务人为维系基本生产需要而支付水费、电费等的；②债务人支付劳动报酬、人身损害赔偿金的；③使债务人财产受益的其他个别清偿。本题中，公司虽然为甲代垫了医疗费、护理费，并支付了10万元赔偿金，但其属于《破产法司法解释（二）》第16条第（二）项规定的人身损害赔偿金范畴，故不应当被撤销，管理人当然无权要求其返还。

C项，《企业破产法》第48条规定，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工

可以向人民法院提起诉讼。故甲的债权属于劳动债权，无须进行债权申报。

D项，《企业破产法》第20条规定，人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。

2. 祺航公司向法院申请破产，法院受理并指定甲为管理人。债权人会议决定设立债权人委员会。现昊泰公司提出要受让祺航公司的全部业务与资产。甲的下列哪一做法是正确的？（ ）

- A. 代表祺航公司决定是否向昊泰公司转让业务与资产
- B. 将该转让事宜交由法院决定
- C. 提议召开债权人会议决议该转让事宜
- D. 作出是否转让的决定并将该转让事宜报告债权人委员会

【答案】D

【解析】ABD三项，《企业破产法》第25条第1款规定，管理人履行下列职责：①接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；②调查债务人财产状况，制作财产状况报告；③决定债务人的内部管理事务；④决定债务人的日常开支和其他必要开支；⑤在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；⑥管理和处分债务人的财产；⑦代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；⑧提议召开债权人会议；⑨人民法院认为管理人应当履行的其他职责。《企业破产法》第69条第1款规定，管理人实施下列行为，应当及时报告债权人委员会：①涉及土地、房屋等不动产权益的转让；②探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；③全部库存或者营业的转让；④借款；⑤设定财产担保；⑥债权和有价证券的转让；⑦履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同；⑧放弃权利；⑨担保物的取回；⑩对债权人利益有重大影响的其他财产处分行为。本题中，破产管理人有权管理和处分债务人的财产，作出决定时应当及时报告债权人委员会。破产管理人属于破产程序中的法定机构，在作出处分债务人财产的决定时并非代表债务人。法院并不决定破产人的资产转让事宜。

C项，《企业破产法》第61条第1款规定，债权人会议行使下列职权：①核查债权；②申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和

报酬；③监督管理人；④选任和更换债权人委员会成员；⑤决定继续或者停止债务人的营业；⑥通过重整计划；⑦通过和解协议；⑧通过债务人财产的管理方案；⑨通过破产财产的变价方案；⑩通过破产财产的分配方案；⑪人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权。债权人会议的职责中并不包含处分债务人财产的内容，处分债务人财产事宜由破产管理人决定。

3. 某公司经营不善，现进行破产清算。关于本案的诉讼费用，下列哪一说法是错误的？（ ）

- A. 在破产申请人未预先交纳诉讼费用时，法院应裁定不予受理破产申请
- B. 该诉讼费用可由债务人财产随时清偿
- C. 债务人财产不足时，诉讼费用应先于共益费用受清偿
- D. 债务人财产不足以清偿诉讼费用等破产费用的，破产管理人应提请法院终结破产程序

【答案】A

【解析】A项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第8条规定，破产案件的诉讼费用，应根据《企业破产法》第43条的规定，从债务人财产中拨付。相关当事人以申请人未预先交纳诉讼费用为由，对破产申请提出异议的，人民法院不予支持。即破产申请人申请企业破产清算不以预先交纳诉讼费用为前提。

BCD三项，《企业破产法》第41条第1项规定，人民法院受理破产申请后发生的破产案件的诉讼费用，为破产费用。第43条规定，破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。债务人财产不足以清偿所有破产费用和共益债务的，先行清偿破产费用。债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照比例清偿。债务人财产不足以清偿破产费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序。人民法院应当自收到请求之日起15日内裁定终结破产程序，并予以公告。

4. 甲公司严重资不抵债，因不能清偿到期债务向法院申请破产。下列哪一财产属于债务人财产？（ ）

- A. 甲公司购买的一批在途货物，但尚未支付货款
- B. 甲公司从乙公司租用的一台设备
- C. 属于甲公司但已抵押给银行的一处厂房
- D. 甲公司根据代管协议合法占有的委托人丙公司的两处房产

【答案】C

【解析】A项，《企业破产法》第39条规定，人民法院受理破产申请时，出卖人已将买卖标的物向作为买受人的债务人发运，债务人尚未收到且未付清全部价款的，出卖人可以取回在运途中的标的物。但是，管理人可以支付全部价款，请求出卖人交付标的物。该条规定了特殊取回权——出卖人取回权。甲公司购买的在途货物，尚未支付货款，仍属于出卖人，不属于债务人财产。

BD两项，《企业破产法》第38条规定，人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产，该财产的权利人可以通过管理人取回。但是，本法另有规定的除外。该条规定了一般取回权，作为取回权标的物的“不属于债务人的财产”主要包括两项：①债务人合法占有的他人财产，②债务人非法占有的他人财产。本题中，甲公司租用的设备及甲公司占有的两处房产都属于债务人甲公司合法占有的他人财产，作为财产所有人的乙公司和丙公司有权取回，因此，这都不属于债务人甲的财产。

C项，《企业破产法》第30条规定，破产申请受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产，为债务人财产。因此破产申请受理时，不论属于债务人的财产上是否有担保物权，都属于债务人财产。

5. 关于破产案件受理后、破产宣告前的程序转换，下列哪一表述是正确的？（ ）

- A. 如为债务人申请破产清算的案件，债权人可以申请和解
- B. 如为债权人申请债务人破产清算的案件，债务人可以申请重整
- C. 如为债权人申请债务人重整的案件，债务人可以申请破产清算

D. 如为债权人申请债务人破产清算的案件，债务人的出资人可以申请和解

【答案】B

【解析】AD两项，《企业破产法》第95条第1款规定，债务人可以依照本法规定，直接向人民法院申请和解；也可以在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，向人民法院申请和解。因此，只有债务人可以提起和解程序，债权人不能提起。

B项，《企业破产法》第70条规定，债务人或者债权人可以依照本法规定，直接向人民法院申请对债务人进行重整。债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人，可以向人民法院申请重整。由此可知，债权人申请破产清算的，债务人或出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人可以申请重整。

C项，根据《企业破产法》第8章，不论是债务人还是债权人提起破产重整程序，法院经审查认为符合法律规定的，裁定重整，重整期间，发生法定条件的，裁定终止重整程序，宣告债务人破产。重整程序开始后，不论是债权人还是债务人都不能申请破产清算。

6. 阳泰公司不能清偿到期债务，债权人向人民法院提出对债务人进行重整，法院裁定阳泰公司重整，下列哪一做法符合破产法规定？
()

A. 阳泰公司为继续经营向甲公司借款，并用厂房作抵押

B. 阳泰公司租用乙公司的机器设备，即使租期已至，乙公司也不得要求阳泰公司归还

C. 丙公司对阳泰公司的仓库享有抵押权，丙公司债权到期，要求实现抵押权，阳泰公司不得拒绝

D. 阳泰公司股东汪某将自己持有的阳泰公司的股份转让给刘某

【答案】A

【解析】AC两项，《企业破产法》第72条规定，自人民法院裁定债务人重整之日起至重整程序终止，为重整期间。第75条规定，在重整期

间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。在重整期间，债务人或者管理人为继续营业而借款的，可以为该借款设定担保。

B项，《企业破产法》第76条规定，债务人合法占有的他人财产，该财产的权利人在重整期间要求取回的，应当符合事先约定的条件。本题中，约定租期已至，乙公司当然可以要求返还。

D项，《企业破产法》第77条第2款规定，在重整期间，债务人的董事、监事、高级管理人员不得向第三人转让其持有的债务人的股权。但是，经人民法院同意的除外。

7. 三石商贸有限公司因管理混乱经营陷入困境，于2019年3月经法院裁定进入破产程序，瀚城律师所被指定为破产管理人。2019年5月底，经债权人会议决议，成立债权人委员会。二鸟公司与瀚城律师所接洽，准备受让三石公司全部的库存和营业事务，关于本案，下列表述错误的是（ ）。

- A. 债权人委员会应包含一名三石公司的职工代表或工会代表
- B. 瀚城律师所应将与二鸟公司的合作事宜事先制作财产管理或者变价方案并提交债权人会议通过
- C. 瀚城律师所的方案未被债权人会议通过的，其可以提交给债权人委员会进行表决
- D. 瀚城律师所在实施与二鸟公司的合作方案前，应报告债权人委员会

【答案】C

【解析】A项，《企业破产法》第67条规定，债权人会议可以决定设立债权人委员会。债权人委员会由债权人会议选任的债权人代表和一名债务人的职工代表或者工会代表组成。债权人委员会成员不得超过9人。债权人委员会成员应当经人民法院书面决定认可。债权人委员会中应当有一名债务人的职工代表或工会代表，由他们代表职工权益。

B项，《破产法司法解释（三）》第15条规定，管理人处分企业破产法第69条规定的债务人重大财产的，应当事先制作财产管理或者变价方案并提交债权人会议进行表决，债权人会议表决未通过的，管理人不得处分。管理人实施处分前，应当根据企业破产法第69条的规定，提前10日书面报告债权人委员会或者人民法院。债权人委员会可

以依照企业破产法第68条第2款的规定，要求管理人对处分行为作出相应说明或者提供有关文件依据。债权人委员会认为管理人实施的处分行为不符合债权人会议通过的财产管理或变价方案的，有权要求管理人纠正。管理人拒绝纠正的，债权人委员会可以请求人民法院作出决定。人民法院认为管理人实施的处分行为不符合债权人会议通过的财产管理或变价方案的，应当责令管理人停止处分行为。管理人应当予以纠正，或者提交债权人会议重新表决通过后实施。二鸟公司受让三石公司全部的库存和营业事务属于《企业破产法》第69条的重大资产处分，管理人需要事先制作财产管理或者变价方案并经债权人会议通过。

C项，如果债权人会议未通过管理人的方案，此处分不得进行，债权人委员会作为债权人会议的常设机关并非上级机关，不能推翻债权人会议的决议。

D项，经债权人会议通过的重大资产处分方案，管理人在实施前应向债权人委员会报告。

8. 思瑞公司不能清偿到期债务，债权人向法院申请破产清算。法院受理并指定了管理人。在宣告破产前，持股20%的股东甲认为如引进战略投资者乙公司，思瑞公司仍有生机，于是向法院申请重整。关于重整，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 如甲申请重整，必须附有乙公司的投资承诺
- B. 如债权人反对，则思瑞公司不能开始重整
- C. 如思瑞公司开始重整，则管理人应辞去职务
- D. 只要思瑞公司的重整计划草案获得法院批准，重整程序就终止

【答案】D

【解析】A项，《企业破产法》第70条第2款规定，债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人，可以向人民法院申请重整。据此可知，申请重整不要求必须附加投资人的投资承诺。

B项，《企业破产法》第71条规定，人民法院经审查认为重整申请符合本法规定的，应当裁定债务人重整，并予以公告。法院可以独

立裁断是否启动重整程序，不需要债权人同意。

C项，在债务人没有提出自行营业申请，或者其自行营业申请未获法院批准的情况下，仍然由管理人负责重整期间债务人财产管理和营业事务。

D项，《企业破产法》第86条第2款规定，自重整计划通过之日起10日内，债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。人民法院经审查认为符合本法规定的，应当自收到申请之日起30日内裁定批准，终止重整程序，并予以公告。据此，在法院批准重整计划后，重整程序即终止。

9. 关于破产重整的申请与重整期间，下列哪一表述是正确的？
()

- A. 只有在破产清算申请受理后，债务人才能向法院提出重整申请
- B. 重整期间为法院裁定债务人重整之日起至重整计划执行完毕时
- C. 在重整期间，经债务人申请并经法院批准，债务人可在管理人监督下自行管理财产和营业事务
- D. 在重整期间，就债务人所承租的房屋，即使租期已届至，出租人也不得请求返还

【答案】C

【解析】A项，《企业破产法》第70条规定，债务人或者债权人可以依照本法规定，直接向人民法院申请对债务人进行重整。债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本10%以上的出资人，可以向人民法院申请重整。据此，破产清算申请并不是债务人提出重整申请的必经程序，债务人可以直接向人民法院提出重整申请。

B项，《企业破产法》第72条规定，自人民法院裁定债务人重整之日起至重整程序终止，为重整期间。重整期间的终止时间为“重整程序终止”而非“重整计划执行完毕时”。根据《企业破产法》第88条的规定，重整计划草案未获得通过且未依照规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。《企业破产法》第93条第1款规定，债务人不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定

终止重整计划的执行，并宣告债务人破产。所以，重整计划不能执行完毕时，重整期间到人民法院裁定终止重整计划时止，重整程序终止。

C项，《企业破产法》第89条规定，重整计划由债务人负责执行。人民法院裁定批准重整计划后，已接管财产和营业事务的管理人应当向债务人移交财产和营业事务。第90条规定，自人民法院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。在监督期内，债务人应当向管理人报告重整计划执行情况和债务人财务状况。因此，经债务人申请并经法院批准，债务人可在管理人监督下自行管理财产和营业事务。

D项，《民法典》第733条规定，租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。《企业破产法》第38条规定，人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产，该财产的权利人可以通过管理人取回。但是，本法另有规定的除外。无论是在破产重整期间还是破产清算期间，只要租赁合同到期，出租人都有权利要求承租人返还租赁物。就出租人的取回权而言，破产重整与破产清算程序并无区别，法律并未特别限制出租人的取回权。

10. 在某公司破产案件中，债权人会议经出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的60%，就若干事项形成决议。该决议所涉下列哪一事项不符合《企业破产法》的规定？（ ）

- A. 选举8名债权人代表与1名职工代表组成债权人委员会
- B. 通过债务人财产的管理方案
- C. 申请法院更换管理人
- D. 通过和解协议

【答案】D

【解析】A项，《企业破产法》第67条第1款规定，债权人会议可以决定设立债权人委员会。债权人委员会由债权人会议选任的债权人代表和1名债务人的职工代表或者工会代表组成。债权人委员会成员不得超过9人。

B项,《企业破产法》第61条第1款第2项规定,债权人会议行使职权之一为:通过债务人财产的管理方案。《企业破产法》第64条第1款规定,债权人会议的决议,由出席会议的有表决权的债权人过半数通过,并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的1/2以上。但是,本法另有规定的除外。本题中,债权人会议决定经过有表决权的债权人过半数通过,并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的60%,超过1/2,因此,该债权人会议形成的该决议在内容上及程序上都符合法律规定。

C项,《企业破产法》第61条第1款第2项规定,债权人会议行使职权之一为:申请人民法院更换管理人,审查管理人的费用和报酬。同理,该债权人会议形成的该决议在内容上及程序上都符合法律规定。

D项,《企业破产法》第97条规定,债权人会议通过和解协议的决议,由出席会议的有表决权的债权人过半数同意,并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的2/3以上。本题中,出席会议的有表决权的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的60%,低于2/3,因此该决议不符合《企业破产法》的规定。

二、多项选择题

1. 2018年12月,胜利房地产开发公司为开发东方家园小区,向建设银行贷款2000万元,约定两年后清偿。全友公司对此贷款提供连带责任担保。2019年5月,胜利房地产公司开发的楼盘销售不利导致资金链断裂,不能清偿到期债务,被法院受理破产。2个月后,全友公司业务不景气也被法院受理破产,下列说法正确的有()。

- A. 当胜利公司被受理破产时,全友公司应向建设银行清偿债务后再向胜利公司追偿
- B. 当胜利公司被受理破产时,全友公司可用其将来求偿权申报债权
- C. 当全友公司被受理破产后,建设银行可分别向胜利公司和全友公司申报金额债权
- D. 当全友公司对建设银行进行破产分配后,不可向胜利公司追偿

【答案】B|C|D

【解析】AB两项，《企业破产法》第51条第2款规定，债务人的保证人或者其他连带债务人尚未代替债务人清偿债务的，以其对债务人的将来求偿权申报债权。但是，债权人已经向管理人申报全部债权的除外。胜利公司被受理破产后，全友公司尚未承担保证责任清偿建设银行贷款时，也可以用将来求偿权申报债权。

CD两项，《破产法司法解释（三）》第5条规定，债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权。债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额。保证人履行保证责任后不再享有求偿权。建设银行对胜利公司享有债权，可向其申报破产债权。建设银行对全友公司享有保证债权，可向其申报破产债权。胜利公司和全友公司分别对建设银行进行破产分配彼此不干扰。因为二者均破产，所以保证人承担保证责任后，不追偿。

2. 2017年3月2日，甲有限公司因资不抵债进入破产重整程序。乙公司因向甲公司提供商品，对甲公司享有100万元到期债权，但乙公司因业务繁忙在债权申报期间并未申报债权。2018年1月，甲公司重整计划执行完毕，全体普通债权人的清偿比例为45%。下列说法正确的是？
()

- A. 对乙公司的债权，甲公司无须承担偿还义务
- B. 对乙公司的债权，参考甲公司重整方案，按同性质债权等比例清偿
- C. 乙公司的债权由甲公司全额清偿
- D. 针对乙公司的债权，重整方案对乙公司也具有法律效力

【答案】BD

【解析】ABC三项，《企业破产法》第92条第2款规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。由此可知，乙公司作为甲公司的债权人未在债权申报期间申报债权，只是在重整计划执行期间不得行使权利，甲公司仍然要承担偿还义务，在甲公司重整计划执行完毕后，可依据甲公司的重整方案，

按同性质债权等比例清偿。

D项,《企业破产法》第92条第1款规定,经人民法院裁定批准的重整计划,对债务人和全体债权人均有约束力。由此可知,甲公司的重整方案对债权人乙公司也具有法律效力。

3. 舜泰公司因资产不足以清偿全部到期债务,法院裁定其重整。管理人为维持公司运行,向齐某借款20万元支付水电费和保安费,约定如1年内还清就不计利息。1年后舜泰公司未还款,还因不能执行重整计划被法院宣告破产。关于齐某的债权,下列哪些选项是正确的?

()

- A. 与舜泰公司的其他债权同等受偿
- B. 应从舜泰公司的财产中随时清偿
- C. 齐某只能主张返还借款本金20万元
- D. 齐某可主张返还本金20万元和逾期还款的利息

【答案】B|C

【解析】AB两项,《企业破产法》第42条第4项规定,人民法院受理破产申请后发生的为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务为共益债务。第43条第1款规定,破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。企业重整期间发生的债务为共益债务,从债务人的财产中随时清偿,而不是列为破产债权与其他债权同等受偿。

CD两项,《企业破产法》第46条第2款规定,附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。1年后舜泰公司未还款,从而开始计算逾期利息,但又由于被宣告破产从而停止计息,相关的逾期利息事实上并未产生,所以齐某不能要求舜泰公司支付逾期利息。

4. 法院受理了利捷公司的破产申请。管理人甲发现,利捷公司与翰扬公司之间的债权债务关系较为复杂。下列哪些说法是正确的?

()

- A. 翰扬公司的某一项债权有房产抵押,可在破产受理后行使抵押权

- B. 翰扬公司与利捷公司有一合同未履行完毕，甲可解除该合同
- C. 翰扬公司曾租给利捷公司的一套设备被损毁，侵权人之前向利捷公司支付了赔偿金，翰扬公司不能主张取回该笔赔偿金
- D. 茹洁公司对利捷公司负有债务，在破产受理后茹洁公司受让了翰扬公司的一项债权，因此茹洁公司无须再向利捷公司履行等额的债务

【答案】B|C

【解析】A项，《企业破产法》第109条规定，对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。《企业破产法》第48条第1款规定，债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权。《企业破产法》第49条规定，债权人申报债权时，应当书面说明债权的数额和有无财产担保，并提交有关证据。申报的债权是连带债权的，应当说明。据此，债务人破产之后，债权人享有的担保物权不受影响，破产法上称之为别除权。需要注意的是，别除权的行使受到破产程序的限制，至少要进行债权申报和债权确认之后，方能行使别除权。本题中，翰扬公司就其享有抵押权的债权可以行使抵押权，但必须经过破产债权申报和确认之后方能行使，而非在破产受理后直接行使。

B项《企业破产法》第18条第1款规定，人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起2个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起30日内未答复的，视为解除合同。

C项，《企业破产法》第38条规定，人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产，该财产的权利人可以通过管理人取回。但是，本法另有规定的除外。在此，取回权的客体是特定的动产或者不动产，但货币本身具有占有即所有的特征，因此对货币不能行使取回权，而应当将该不当得利返还请求权作为破产债权进行申报。

D项，《企业破产法》第40条第1项规定，债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。但是，债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的，不得抵销。据此，利捷公司的债务人茹洁公司在破产受理之后取得的对利捷公司的债权不能与其对利捷公司的债务进行抵销。

5. A公司因经营不善，资产已不足以清偿全部债务，经申请进入破产还债程序。关于破产债权的申报，下列哪些表述是正确的？（ ）

- A. 甲对A公司的债权虽未到期，仍可以申报
- B. 乙对A公司的债权因附有条件，故不能申报
- C. 丙对A公司的债权虽然诉讼未决，但丙仍可以申报
- D. 职工丁对A公司的伤残补助请求权，应予以申报

【答案】A|C

【解析】A项，《企业破产法》第46条第1款规定，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。甲对A公司的未到期债权在破产申请受理时视为到期，可以申报。

BC两项，《企业破产法》第47条规定，附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权，债权人可以申报。乙对A公司附有条件的债权和丙对A公司诉讼未决的债权均可以申报。破产债权的申报原则就是最大限度保护债权人的利益。

D项，《企业破产法》第48条第2款规定，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起诉讼。据此，职工丁对A公司的伤残补助请求权不必申报。

6. 甲企业被债权人申请宣告破产，法院受理了案件，以下哪些说法不正确？（ ）

- A. 甲企业在破产申请受理前，拖欠乙公司货款10万元数年未还，甲企业在破产申请受理后，偿还了乙公司欠款，乙公司不知道甲企业已被申请宣告破产，甲企业的清偿有效
- B. 甲企业在破产申请受理后，向供电公司支付了电费，供电公司知道甲企业被宣告破产，该支付无效

C. 甲企业作为丙公司的保证人，丙公司的债务到期不还，债权人将丙公司和甲企业列为共同被告起诉到法院，乙法院受理了案件，尚未开庭，在戊法院受理破产申请后，乙法院应将该案件移送到戊法院

D. 丙法院审理王某起诉丁公司侵权的案件，甲企业作为无独立请求权的第三人参加了诉讼，在戊法院受理破产申请后，丙法院应继续审理案件

【答案】A|B|C|D

【解析】A项，《企业破产法》第16条规定，人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。因此，不论债权人是否知道债务人被申请宣告破产，债务人对部分债权人的清偿无效。

B项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（二）》第16条规定，债务人对债权人进行的以下个别清偿，管理人依据企业破产法第32条的规定请求撤销的，人民法院不予支持：①债务人为维系基本生产需要而支付水费、电费等的；②债务人支付劳动报酬、人身损害赔偿金的；③使债务人财产受益的其他个别清偿。据此，水电费的个别清偿有效。

CD两项，依照《企业破产法》第20、21条，人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止，在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。有关债务人的民事诉讼只能向受理破产申请的人民法院提起。

7. 古道西风有限公司被裁定进入破产程序，根据《破产法司法解释（三）》，下列选项正确的是（ ）。

A. 债权人会议的决议超出债权人会议的职权范围，损害债权人利益，债权人有权申请撤销

B. 债权人会议的决议内容违法，损害债权人利益，债权人有权申请撤销

C. 人民法院只能裁定撤销全部事项决议，责令债权人会议依法重新作出决议

D. 债权人申请撤销债权人会议决议的，可以提出口头或者书面申请

【答案】A|B

【解析】AB两项，根据《破产法司法解释（三）》第12条第1款规定，债权人会议的决议具有以下情形之一，损害债权人利益，债权人申请撤销的，人民法院应予支持：①债权人会议的召开违反法定程序；②债权人会议的表决违反法定程序；③债权人会议的决议内容违法；④债权人会议的决议超出债权人会议的职权范围。

C项，根据《破产法司法解释（三）》第12条第2款规定，人民法院可以裁定撤销全部或者部分事项决议，责令债权人会议依法重新作出决议。

D项，根据《破产法司法解释（三）》第12条第3款规定，债权人申请撤销债权人会议决议的，应当提出书面申请。债权人会议采取通信、网络投票等非现场方式进行表决的，债权人申请撤销的期限自债权人收到通知之日起算。

8. 某法院于2018年5月10日裁定受理摩斯单车公司破产案。管理人清理财产发现，公司厂房已经抵押给债权人丁某；公司于2018年3月6日偿还债权人郭某100万元以取回当时急用的质押物；有一台市价80万元的机器设备质押于债权人陈某处，以为120万元欠款做担保；付某欠公司60万元，在2018年5月25日从公司债权人冯某处以50万元的价格受让60万元的债权。关于本案，下列选项错误的是（ ）。

- A. 厂房属于债务人财产
- B. 管理人有权请求撤销公司偿还郭某100万元的行为
- C. 管理人可以清偿陈某120万元以取回机器设备
- D. 付某可以向管理人主张抵销60万元

【答案】B|C|D

【解析】A项，债务人已依法设定担保物权的特定财产，人民法院应当认定为债务人财产。

B项，《企业破产法》第32条规定，人民法院受理破产申请前6个月内，债务人有本法第2条第1款规定的情形，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。但是，个别清偿使债务人

财产受益的除外。公司偿还郭某100万元的行为虽然发生在法院受理破产申请前6个月，但目的在于取回当时急用的质押物，可以理解为使债务人财产受益。

C项，《企业破产法》第37条规定，人民法院受理破产申请后，管理人可以通过清偿债务或者提供为债权人接受的担保，取回质物、留置物。前款规定的债务清偿或者替代担保，在质物或者留置物的价值低于被担保的债权额时，以该质物或者留置物当时的市场价值为限。由此可知，管理人可以清偿陈某的债权以取回机器设备，但以质物的市场价值80万元为限。

D项，《企业破产法》第40条规定，债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。但是债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的，不得抵销。

三、不定项选择题

1. 甲、乙和远达公司共同出资设立了恒泰圣都有限责任公司，甲出资20%，乙出资10%，远达公司出资70%，远达公司的总经理徐铮任恒泰圣都公司的董事长，公司成立后，经其他股东同意，乙将5%的股份转让给徐铮。恒泰圣都公司成立后一直经营困难，长期拖欠金河公司货款，金河公司向人民法院申请宣告恒泰圣都公司破产，法院受理了申请，并指定文胜律师事务所为管理人。恒泰圣都公司向法院提出重整申请，法院经审查后，裁定重整，并确定重整期间恒泰圣都公司自行管理和营业。重整计划通过，恒泰圣都公司在履行重整计划期间，有隐匿财产行为，经金河公司请求，法院裁定终止重整程序，宣告恒泰圣都公司破产。

1). 除恒泰圣都公司外，有权提出重整申请的主体包括（ ）。

- A. 金河公司
- B. 文胜律师事务所
- C. 远达公司
- D. 乙

【答案】C

【解析】

《企业破产法》第70条第2款规定，债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人，可以向人民法院申请重整。本题中，甲出资20%，乙出资10%，远达公司出资70%，有权提出重整申请的主体是远达公司。

2). 关于重整计划草案，下列说法正确的是（ ）。

- A. 恒泰圣都公司拟定
- B. 文胜律师事务所拟定
- C. 应同时向法院和债权人会议提交
- D. 有财产担保债权的债权人和普通债权的债权人应分组表决

【答案】A|C|D

【解析】AB两项，《企业破产法》第80条第1款规定，债务人自行管理财产和营业事务的，由债务人制作重整计划草案。在本题中，法院确定重整期间由恒泰圣都公司自行管理和营业。因此，重整计划草案应由恒泰圣都公司拟定。

C项，《企业破产法》第79条第1款规定，债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起6个月内，同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。

D项，《企业破产法》第82条规定，下列各类债权的债权人参加讨论重整计划草案的债权人会议，依照下列债权分类，分组对重整计划草案进行表决：①对债务人的特定财产享有担保权的债权；②债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；③债务人所欠税款；④普通债权。人民法院在必要时可以决定在普通债权组中设小额债权组对重整计划草案进行表决。

3). 关于重整计划的通过和批准，下列说法正确的是（ ）。

- A. 出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且所代表的债权额占无财产担保债权总额的1/2以上，方为该组通过草案
- B. 应设出资人组，对重整计划草案进行表决
- C. 各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过
- D. 部分表决组未通过的，经协商可以再表决一次，如又未通过，经恒泰圣都公司申请，法院可强行批准重整计划

【答案】C|D

【解析】A项，《企业破产法》第84条第2款规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的2/3以上的，即为该组通过重整计划草案。

B项，《企业破产法》第85条第2款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。由此可知，只有重整计划草案涉及出资人权益调整的，应当设出资人组，否则不应设。

C项，《企业破产法》第86条第1款规定，各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。

D项，《企业破产法》第87条规定第2款规定，未通过重整计划草案的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计划草案，但重整计划草案符合条件的，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案。

4). 重整期间，下列做法不合法的是（ ）。

- A. 恒泰圣都公司欠途胜汽车修理厂修理费10万元，途胜厂留置了恒泰圣都公司的汽车一辆，重整计划批准后，途胜厂将汽车拍卖，清偿了自己的债权
- B. 恒泰圣都公司向A市城市信用合作社借款，并以厂房作为抵押
- C. 徐铮将自己持有的恒泰圣都公司股份转让给甲
- D. 恒泰圣都公司向远达公司等股东支付红利共计10万元

【答案】A|C|D

【解析】AB两项，《企业破产法》第75条规定，在重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。但是，担保物有损坏或者价值明显减少的可能，足以危害担保权人权利的，担保权人可以向人民法院请求恢复行使担保权。在重整期间，债务人或者管理人为继续营业而借款的，可以为该借款设定担保。

CD两项，《企业破产法》第77条规定，在重整期间，债务人的出资人不得请求投资收益分配。在重整期间，债务人的董事、监事、高级管理人员不得向第三人转让其持有的债务人的股权。但是，经人民法院同意的除外。

5). 重整计划中金河公司承诺放弃50%的债权，重整计划批准后恒泰圣都公司向债权人之一兴康公司清偿全部债务，下列说法正确的是（ ）。

- A. 金河公司的承诺失效
- B. 兴康公司所受的清偿有效
- C. A市城市信用合作社的抵押权有效
- D. 以上都对

【答案】A|B|C|D

【解析】AB两项，《企业破产法》第93条第2款规定，人民法院裁定终止重整计划执行的，债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。

C项，《企业破产法》第93条第1款、第4款规定，债务人不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产。有本条第一款规定情形的，为重整计划的执行提供的担保继续有效。

四、概念题

1. 破产共益债务

【答案】

破产共益债务是指在破产程序进行中，为全体债权人利益或为程序进行之必需而对破产财团产生的一切请求权的统称。共益债务的特征有：①是在破产程序终结前因破产程序的开始和进行而应支付的费用和产生的请求权。②是以破产财团即全部破产财产作为支付和清偿对象，以破产管理人作为权利行使的相对人。③多因破产管理人的行为而产生。④依破产程序进行的需要及实际开支的多少，而随时、足额拨付或优先于破产债权获得清偿。

2. 破产法上的抵销权与债法上的抵销权

【答案】（1）破产法上的抵销权，是指在破产宣告时，与破产人互负债务的债权人可不依破产程序，而以其对破产人的债权抵销其对破产人所负债务的权利。

（2）债法上的抵销权是指二人互负债务，各以其债权充当债务之履行，而使其债务与对方债务在对等额度内相互消灭的权利。破产抵销权的基础是债的抵销原理，是债法中的抵销权在债务人破产情形下的扩张适用。

（3）二者存在一定差异：①破产抵销权的行使主体只能是破产债权人。②破产抵销权不受债务种类和履行期限的限制。③破产债权人主张抵销的债务，只能成立于破产宣告前，破产人受破产宣告后，破产人所有的对外债权都属于破产财产，是全体破产债权人受偿的保障。

五、简答题

1. 简述我国《企业破产法》对破产追回权的规定。

【答案】我国《企业破产法》规定，破产追回权存在于以下情形：

（1）破产管理人行使破产撤销权而应取得的债务人的财产。这是行使破产撤销权的当然后果，否则破产撤销权的行使将无意义。

（2）破产管理人主张债务人实施的行为无效而应取得的债务人的财产。涉及债务人财产的下列行为无效：

①为逃避债务而隐匿、转移财产的。

②虚构债务或者承认不真实的债务的。

（3）人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，破产管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。

（4）债务人的董事、监事和高级管理人员利用职权从企业获取的非正常收入和侵占的企业财产，管理人应当追回。

①对非正常收入的追回

非正常收入，主要指董事、经理或者其他负责人通过控制、操纵公司的董事会以及利用公司规则漏洞或模糊之处，给自己过高的薪酬、奖金或者期权计划等，目的是攫取企业财产。这种侵害在企业正常经营的情况下，是对股东利益的侵害，但在企业进入破产程序之后，则构成对债权人利益的侵害。因此，破产管理人作为债权人利益的总代表，有权对这部分财产予以追回。

②对被侵占的企业财产的追回

侵占企业财产是企业管理层有关人员利用职务之便将原属于企业的财产据为己有的行为，是指企业的董事、经理、监事、会计等利用自己在职务上主管或者管理、经手本单位财务的方便条件，侵占企业财产的行为。此处所谓侵占的企业财产，不仅包括企业登记在册的财产，也包括企业隐匿的财产（如“小金库”）以及交易收取尚未入库等账外财产。

2. 破产取回权与别除权的区别。

【答案】（1）破产取回权系指破产管理人占有不属于破产财团之他人财产，财产之权利人得不依破产程序，直接对该项财产行使权利，从破产财团取回其财产之权利。取回权并非破产法所创设，而是由所有权的效力引申出的权利，只是因其在破产程序中的行使特点，而称之为取回权。

（2）破产别除权是指债权人因债权设有担保物权，而就破产人的特定担保财产在破产程序中享有的优先受偿权利。我国《企业破产法》规定，破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利。别除权是由破产人特定财产上已存在的担保物权之排他性优先效力沿袭而来，亦非破产法所创设。别除权的名称，是针对这种权利在破产程序中行使的特点而命名的。

（3）二者的区别主要是其原权利不同，即取回权是由所有权引申出的权利，而别除权是由担保物权的排他性效力引申而来。

3. 简述债权人会议的职权。

【答案】我国《企业破产法》第61条明确规定，债权人会议行使下列职权：

（1）核查债权

在债权人会议上，所有的债权证明材料都要向全体债权人出示，供所有债权人查阅。

（2）申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬

对于法院任命的管理人，债权人会议享有申请更换权。对于债权人会议的申请，人民法院如果同意，将解任原管理人，另行指定管理人，但债权人会议不得直接自行选任管理人。

债权人有权监督破产费用的支付，以防止因不合理增加的开支而损害债权人的清偿利益。

（3）监督管理人

债权人会议有权通过以下方式对管理人行使监督权利：

①有权随时调查债务人财产的状况，并有权随时要求管理人报告其所管理的财产的情况。

②监督管理人处置债务人财产的行为。

③管理人应当列席债权人会议，不能拒绝列席债权人会议。

④债权人会议对管理人的监督，还应当体现在事后救济上。债权人会议认为管理人的行为违背债权人利益的，可以请求人民法院对管理人的行为予以撤销。

（4）选任和更换债权人委员会成员

债权人会议选任和撤换债权人委员会成员的自主权，必须受到法律和人民法院的一定约束。

（5）决定继续或者停止债务人的营业

（6）通过重整计划

（7）通过和解协议

和解协议是清偿债务的协议，一般要求债权人作出适当让步，放弃部分债权，因而和解协议必须由债权人会议决议。

（8）通过债务人财产的管理方案

管理人接受人民法院的指定，开始履行职责后，应尽快制定出对债务人财产的管理方案。

（9）通过破产财产的变价方案

破产清算中，要对破产人的财产进行分配，必须实现破产债权的等质化和破产财产的等质化，以保证破产分配的公正和合理，破产财产的等质化。

（10）通过破产财产的分配方案

破产财产的分配是指按各债权人的应受偿顺序和应受偿比例将破产财产在债权人之间进行分配的程序，是整个破产清算程序的终点。

破产分配是与债权人利益最为密切相关的事项，必须经过债权人

会议的审议。

(11) 人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权
债权人会议应当将所议事项的决议作成会议记录。

4. 简述债权人会议的决议规则。

【答案】(1) 关于债权人会议的决议规则，理论上分析可有三类划分：①以同意的债权人所代表的债权额的多数或者绝对多数可决；②以人数和债权额双重多数为标准；③以出席会议的人数的多数同意为已足。

可以看出，采用人数和债权额双重标准进行表决对保护债权人的全体利益更为周全，因为单采人数标准，虽能保障多数债权人的利益却未必符合少数大额债权人的利益；而单采债权额标准则又反过来可能损害多数小额债权人的利益。

(2) 我国关于债权人会议决议规则的法律规定

《企业破产法》第64条规定，债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的1/2以上。但本法另有规定的除外。

基于债务人财产的管理方案和破产财产的变价方案、分配方案等在特定情况下可能并无太多的选择余地，故而《企业破产法》对这些方案的决议规定了特殊的方法。按照规定，债务人财产的管理方案以及破产财产的变价方案，经债权人会议表决未通过的，由人民法院裁定；破产财产的分配方案，经债权人会议二次表决仍未通过的，由人民法院裁定。

前述两项裁定，人民法院可以在债权人会议上宣布或者另行通知债权人。债权人对人民法院就债务人财产的管理方案、破产财产的变价方案作出的裁定不服的，或者债权额占无财产担保债权总额1/2以上的债权人对人民法院就破产财产的分配方案作出的裁定不服的，可以自裁定宣布之日或者收到通知之日起15日内向该人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。

5. 简述债权人委员会的性质及职权。

【答案】(1) 债权人委员会的性质

债权人委员会是遵循债权人的共同意志，代表债权人会议监督管理人行为以及破产程序的合法、公正进行，处理破产程序中的有关事项的常设监督机构。债权人委员会有助于保护全体债权人的利益，保

障债权人会议职能的有效执行，并在债权人会议闭会期间对破产程序进行日常必要的监督。可见，债权人委员会是破产程序中的破产监督人。

按照《企业破产法》的规定，债权人会议可以决定设立债权人委员会。债权人委员会由债权人会议选任的债权人代表和1名债务人的职工代表或者工会代表组成。债权人委员会成员不得超过9人。债权人委员会成员应当经人民法院书面决定认可。

（2）债权人委员会的职权

债权人委员会行使下列职权：①监督债务人财产的管理和处分；②监督破产财产的分配；③提议召开债权人会议；④债权人会议委托的其他职权。同时，破产管理人实施那些对债权人利益有重大影响的财产处分行为时，应当及时报告债权人委员会。

债权人委员会执行职务时，有权要求管理人、债务人的有关人员对其职权范围内的事务作出说明或者提供有关文件。管理人、债务人的有关人员违反《企业破产法》规定拒绝接受监督的，债权人委员会有权就监督事项请求人民法院作出决定；人民法院应当在5日内作出决定。

六、论述题

1. 如何理解我国《企业破产法》关于不同破产程序之间转换的规定？

【答案】尽管法律未对破产程序之间的转换作明确规定，但基于不同破产程序所具有的特殊制度价值以及《企业破产法》的规定，可对不同破产程序之间的转换作如下理解：

（1）在破产清算程序进行过程中，相关申请权人可申请将破产清算程序转换为破产重整程序或破产和解程序。

（2）在破产和解程序进行过程中，重整申请权人不能申请将和解程序转换为重整程序。我国《企业破产法》将提出重整申请的时间明确限定为“宣告债务人破产前”，事实上已排除了破产和解协议生效后申请重整的权利，因为和解协议生效将导致破产清算程序终结，从而无从将破产清算程序转换为破产重整程序。至于破产和解程序启动后和解协议生效前能否将破产程序转换为破产重整程序，尽管缺乏《企业破产法》的明确规定，但鉴于破产和解程序与破产重整程序的基本功能相同且前者已被受理，故仍应排除重整程序的适用。

（3）在破产重整程序进行过程中，和解申请权人也不能申请将重整程序转换为和解程序。我国《企业破产法》未对此作明确规定，但

由于重整程序一般具有优先适用效力，且二者具有基本相同的制度价值，而在当事人的申请下法院已受理了重整程序，故应排除和解程序的适用。

（4）在破产清算程序中，若债务人已被宣告破产，则不能将破产程序转换为破产重整程序或破产和解程序。这是因为在宣告破产后，将随即对破产财产进行变价和分配，已不具备将破产程序转换为破产重整程序或破产和解程序的条件。

2. 论破产管理人制度。

【答案】（1）破产管理人的概念

破产管理人是指依照破产法规定，在破产重整、破产和解和破产清算程序中负责债务人财产管理和其他事项的机构或个人。

（2）破产管理人的法律地位

越来越多的学者开始接受“破产财团代表说”。关于破产管理人的法律地位主要存在三种观点：一是代理说；二是职务说；三是财团代表说。财团代表说是主流观点。破产财团代表说，是指债务人财产因破产程序的开始或者破产宣告裁定的作出而成为以破产预防或破产清算为目的而独立存在的财产，这些财产整体人格化则形成破产财团，破产管理人是这种人格化财产的代表机关。

（3）破产管理人的任职资格与选任方式

①破产管理人的任职资格

各国并无特别的限制。凡有行为能力者，无论其是否为债权人均可选任，但基于破产清算人系专司管理和清算事务，故以会计师、律师或其他通晓计算、经营、法律、经贸知识的机构或人员为宜。原则上，个人担任管理人的，应当参加执业责任保险。

②破产管理人的选任方式

我国《企业破产法》第24条规定，管理人可以由有关部门、机构的人员组成的清算组或者依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构担任。人民法院根据债务人的实际情况，可以在征询有关社会中介机构的意见后，指定该机构具备相关专业知识和取得执业资格的人员担任管理人。

有下列情形之一的，不得担任管理人：a. 因故意犯罪受过刑事处罚；b. 曾被吊销相关专业执业证书；c. 与本案有利害关系；d. 人民法院认为不宜担任管理人的其他情形。个人担任管理人的，应当参加执业责任保险。

（4）破产管理人的职责与监督

①破产管理人的职责

《企业破产法》规定，破产管理人的职责包括：a. 接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；b. 调查债务人财产状况，制作财产状况报告；c. 决定债务人的内部管理事务；d. 决定债务人的日常开支和其他必要开支；e. 在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；f. 管理和处分债务人的财产；g. 代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；h. 提议召开债权人会议；i. 人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

《企业破产法》同时规定，在第一次债权人会议召开之前，管理人决定继续或者停止债务人的营业或者实施《企业破产法》第69条规定的下列行为之一的，应当经人民法院许可：a. 涉及土地、房屋等不动产权益的转让；b. 探矿权、采矿权、知识产权等财产权的转让；c. 全部库存或者营业的转让；d. 借款；e. 设定财产担保；f. 债权和有价证券的转让；g. 履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同；h. 放弃权利；i. 担保物的取回；第十，对债权人利益有重大影响的其他财产处分行为。

②破产管理人的监督

对于破产管理人的一般监督，我国《企业破产法》第23条规定：“管理人依照本法规定执行职务，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人应当列席债权人会议，向债权人会议报告职务执行情况，并回答询问。”该法第61条还把“监督管理人”列为债权人会议的职权之一。

为更有效地实现对管理人以及破产管理事务的监督，我国2006年《企业破产法》专门规定了“债权人委员会”制度。按照规定，债权人会议可以决定设立债权人委员会。